GRAN CONCURSOS

DIREITO CONSTITUCIONAL

Teoria da Constituição

Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250513563985

ARAGONÊ FERNANDES

Juiz de Direito do TJDFT. Foi promotor de Justiça do MPDFT. Foi assessor de ministros em Tribunais Superiores. Aprovado em diversos concursos. Professor de Direito Constitucional exclusivo do Gran. Coordenador da Gran Pós. Autor de obras jurídicas. Fundador do Canal Sai Pobreza. Palestrante.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 4
Teoria da Constituição 5
1. O Direito Constitucional 5
1.1. Conceito e Objeto de Constituição 6
1.2. Classificação (Tipologia) das Constituições 9
1.3. O Papel da Constituição no Ordenamento Jurídico 19
1.4. Elementos das Constituições 20
1.5. Bloco de Constitucionalidade 23
1.6. Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo 24
1.7. Princípios e Regras 30
1.8. Poder Constituinte 35
1.9. Princípio da Hierarquia das Normas – a Ideia da Supremacia da Constituição 56
1.10. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais 63
1.11. Hermenêutica Constitucional 72
1.12. Histórico das Constituições Brasileiras 83
1.13. Conceitos que Você Precisa Saber 90
Questões de Concurso 96
Gabarito 102
Gabarito Comentado 103

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

A **Teoria da Constituição** engloba alguns assuntos esparsos, passando pelo **conceito**, **classificações (tipologias)** e **elementos das constituições**. Além disso, costumam ser cobrados em prova os assuntos relacionados ao **poder constituinte** e à **eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais**.

Em outros editais, especialmente para o pessoal do juridiquês, a **hermenêutica constitucional**, com os seus métodos e princípios de interpretação, é visita frequente.

Também na área do juridiquês vemos conceitos relevantes como a distinção entre princípios e regras, entre teorias substancialistas e procedimentalistas. Há igualmente a necessidade de tratarmos sobre o constitucionalismo e sobre o neoconstitucionalismo.

Menos comum é a exigência de conhecimentos ligados ao histórico das constituições brasileiras. Seja como for, uma dose de cultura não atrapalha ninguém, além de servir para afastar eventuais dúvidas.

Há ainda a necessidade de o candidato conhecer a estrutura piramidal de hierarquia das normas, que culmina com a supremacia da constituição.

Nós veremos cada um desses pontos, sempre de forma simples e didática, mas sem perder a essência daquilo que é necessário para você fazer uma boa prova.

Ah, aqui o uso da Doutrina será mais recorrente do que em outros pontos, viu?! Porém, fique tranquilo, pois não farei aquelas transcrições enormes, que mais confundem do que ajudam.

A ideia, repito, é ir direto ao ponto! Então, sem mais conversa, vamos lá!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO

1. O DIREITO CONSTITUCIONAL

De forma prática, vou fixar algumas balizas, relacionadas à **natureza**, **conceito**, **objeto** e **fontes** do direito constitucional.

Quanto à **natureza**, não há dúvidas de que o direito constitucional se insere dentro do Direito Público. Todos os ramos do Direito precisam se compatibilizar com a ordem constitucional, funcionando o direito constitucional como um tronco de onde se original as outras áreas do Direito.

A bem da verdade, a dicotomia entre direito público e privado, embora ainda existente, é fragilizada no proeminente cenário constitucional moderno.

É por isso que se tem, por exemplo, em direito civil-constitucional. Nessa visão, o direito privado sofre uma releitura, devendo respeitar direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Não é à toa que hoje se fala na eficácia privada dos direitos fundamentais (aplicação nas relações entre particulares).

José Afonso da Silva traz o **conceito de direito constitucional** como sendo **o ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado**. Ele prossegue dizendo que o Direito Constitucional é a ciência positiva das constituições.[1]

Outro grande mestre, J. H. Meirelles Teixeira define o direito constitucional como o conjunto de princípios e normas que regulam a existência do Estado moderno, na sua estrutura e no seu funcionamento, o modo de exercício e os limites de sua soberania, seus fins e interesses fundamentais.[2]

Maurice Hauriou ensina que o **objeto do direito constitucional** é a constituição política do Estado. Sendo mais detalhista, Dirley da Cunha Junior indica como objeto o conhecimento científico e sistematizado da organização fundamental do Estado, por meio da investigação e do estudo dos princípios e regras constitucionais relativos à forma de Estado, à forma e ao sistema de governo, ao modo de aquisição e exercício do poder, à composição e funcionamento de seus órgãos, aos limites de sua atuação e aos direitos e garantias fundamentais.[3]

São diversas as **fontes do direito constitucional**. Podemos citar **a Constituição**, principal fonte formal, além dos **tratados internacionais de direitos humanos aprovados sob a sistemática do § 3º do artigo 5º** – dois turnos de votação, em cada Casa do Congresso, obtendo 3/5 de votos.

---

[1] SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. p. 36.

[2] TEIXEIRA, J. H. Meirelles. *Curso de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 37.

[3] CUNHA JÚNIOR, Dirley. *Curso de direito constitucional*. 12ª edição. Salvador: JusPodivm. 2018. p. 43.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Há também a **jurisprudência**, em especial, do Supremo Tribunal Federal, já que a Corte tem papel de suma importância na jurisdição constitucional.

Flávio Martins destaca que a **doutrina** constitucional não só interpreta o conteúdo das leis constitucionais, como também cria, inova e estabelece novos parâmetros constitucionais, transformando a realidade.[4]

Paulo Gustavo Gonet Branco defende que o **costume** é fonte complementar, mas não primária do direito constitucional. Ele diferencia o costume *contra legem*, que deve ser repelido, do costume *secundum legem* (conforma um entendimento possível do texto, podendo ensejar mutação constitucional) e o *praeter legem* (supre lacuna), esses dois últimos admitidos. O autor ainda cita que o próprio STF já confirmou a validade dos costumes, quando declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que limitava a substituição do governador pelo vice-governador somente nas ausências por mais de 15 dias. Pesou o costume no cenário federal, de substituição mesmo em períodos breves (STF, ADI n. 644).[5]

1.1. CONCEITO E OBJETO DE CONSTITUIÇÃO

Se você for olhar bem, em cada livro de Doutrina haverá um conceito de Constituição "à moda da casa". Em outras palavras, a conceituação de Constituição trará variações relacionadas ao entendimento do autor sobre o tema.

Eu diria que **a Constituição é a norma de maior hierarquia em um ordenamento jurídico**, que **organiza o Estado e os seus Poderes, além de tratar dos direitos e garantias individuais**.

Segundo José Afonso da Silva, "as Constituições têm por **objeto** estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo e aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais".[6]

Aliás, hoje em dia, diante do movimento do **Neoconstitucionalismo**, **a pessoa humana é colocada no centro do sistema**, em uma posição de grande destaque. Não é por outra razão que você ouve tanto falar em dignidade da pessoa humana, que se apresenta como metaprincípio.

O jurista alemão **Konrad Hesse** explica que a Constituição deve ser entendida como a ordem jurídica fundamental de uma comunidade. Por ter status de norma jurídica, ela seria dotada de **força normativa** suficiente para vincular e impor os seus comandos.[7]

---

[4] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 178.

[5] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional.*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 59.

[6] SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. p. 45.

[7] HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sério A. Fabris, 1991. p. 19.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Dito isso, não tenho dúvidas de que nas provas o ponto mais exigido dentro do conceito de Constituição é a forma como o Direito Constitucional se inter-relaciona com outras ciências, principalmente a Sociologia, a Filosofia e a Política.

Em virtude disso, existem diversos **sentidos/concepções** para se conceituar a Constituição.

Vou apresentar cada um deles e logo depois vou fazer uma espécie de tabela identificando o sentido, nome do autor e expressão chave para identificar. De antemão, já adianto que o Examinador vai trocar um com o outro, tentando induzi-lo a erro.

1.1.1. SENTIDO SOCIOLÓGICO DE CONSTITUIÇÃO

Dentro do **sentido sociológico**, o professor **Ferdinand Lassalle** defende que uma Constituição só seria legítima se representasse a vontade popular, refletindo a **somatória dos fatores reais de poder numa sociedade**. Caso isso não aconteça, a Constituição não passaria de uma '**folha de papel**'.

Para você ter uma ideia, certa vez eu estava fazendo uma aula de especialização, e o professor mostrou-nos um livro, no qual a capa trazia uma daquelas Constituições brasileiras clássicas, no modelo em que é divulgada pela Câmara e pelo Senado.

Então, ele perguntou a nós, alunos: "O que é isso?" Claro que todos respondemos que era uma Constituição. Foi daí que ele folheou, e não havia nada escrito nas páginas do "recheio". Em outras palavras, ele colou a capa da Constituição em folhas em branco.

De novo ele perguntou: "O que é isso?". Ele seguiu respondendo que a nossa resposta, no sentido de aquilo ser a Constituição, decorreria do fato de aceitarmos a Constituição como resultado da somatória dos fatores reais de poder numa sociedade.

Se isso não ocorresse, ou seja, se não entendêssemos a legitimidade daquele livro, ele não passaria de uma 'folha de papel' como tantas outras.

1.1.2. SENTIDO POLÍTICO DE CONSTITUIÇÃO

Esse é ainda mais fácil: no **sentido político**, **Carl Schmitt** conceitua Constituição como **a decisão política fundamental**. Segundo o autor, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência.

Um ponto importante: Carl Schitt **diferencia Constituição de leis constitucionais**. A Constituição disporia somente sobre as matérias de grande relevância jurídica, sobre as decisões políticas fundamentais, tais como organização do Estado, princípio democrático e os direitos fundamentais. As outras normas presentes na Constituição seriam somente leis constitucionais.

Falando em outras palavras, Constituição seria aquilo que realmente merece estar na norma mais importante. O resto, que lá está, mas não tem a mesma importância, seria apenas uma lei constitucional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Se você reparar bem, parece muito com a classificação das constituições segundo o conteúdo. Isso porque as 'leis constitucionais' seriam Constituição em aspecto formal, enquanto a Constituição seria apenas o filé mignon, o aspecto material.

1.1.3. SENTIDO JURÍDICO DE CONSTITUIÇÃO

Fechando a trinca dos conceitos mais cobrados nas provas, no **sentido jurídico**, **Hans Kelsen** diz que **a Constituição estaria no mundo do dever ser** (como as coisas deveriam ser)**, e não no mundo do ser** (mundo real, como as coisas são), caracterizada como fruto da vontade racional do homem, e não das leis naturais.

Ela seria uma **norma pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico.** Não é por outra razão que uma grande obra de Kelsen é chamada de **Teoria Pura do Direito**.

Kelsen se contrapunha às ideias de Lassale, por entender que a Constituição, por si, tinha eficácia jurídica, não precisando encontrar ressonância nos fatores reais de poder em uma sociedade.

Ele apresentava as seguintes vertentes a respeito da Constituição:

- **Sentido lógico-jurídico:** norma fundamental hipotética, pressuposto de validade da Constituição.
- **Sentido jurídico-positivo:** norma suprema, fundamento de validade das demais normas.

1.1.4. SENTIDO NORMATIVO DE CONSTITUIÇÃO

Desenvolvida por **Konrad Hesse**, essa concepção teve, segundo Marcelo Novelino[8], relevante papel na **superação** do modelo de constituição como um documento essencialmente político, predominante na primeira metade do século XX.

Hesse também contrariou a tese defendida por Lassale, dizendo que **nem sempre os fatores reais de poder de uma sociedade prevaleceriam sobre a Constituição normativa**.

Exatamente por conta de sua força normativa, a Constituição seria capaz de imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Assim, a Constituição até poderia não realizar as coisas sozinha, mas poderia impor tarefas.

Ela (a Constituição) deve ser entendida como a ordem jurídica fundamental de uma comunidade. E, por ter status de norma jurídica, seria dotada de **força normativa** suficiente para vincular e impor os seus comandos.[9]

Novelino ainda cita **o reconhecimento definitivo da força normativa das Constituições como uma das principais conquistas do constitucionalismo contemporâneo**.

---

[8] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 97.

[9] HESSE, Konrad. *A força normativa da Constituição*. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sério A. Fabris, 1991. p. 19.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.1.5. SENTIDO CULTURALISTA DE CONSTITUIÇÃO

Aqui está um conceito-sentido menos cobrado pelas Bancas, mas que é apresentado por um brasileiro.

É o seguinte: no **conceito culturalista**, desenvolvido por **J. H. Meirelles Teixeira**, a Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que sobre ela pode influir.

A concepção culturalista levaria ao conceito de '**Constituição Total**', por apresentar "na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos".[10]

Pronto! Agora que já mostrei a você os conceitos/sentidos principais para as provas, veja o seguinte quadro esquemático:

SENTIDO	PENSADOR	EXPRESSÃO IDENTIFICADORA
Sociológico	**Ferdinand Lassale**	A Constituição precisa refletir a **somatória dos fatores reais de poder**. Do contrário, não passaria de uma **folha de papel**.
Político	**Carl Schmitt**	Constituição seria a **decisão política fundamental** do país. Pensador diferencia Constituição (conteúdo verdadeiramente constitucional) de leis constitucionais (está na Constituição, mas o conteúdo não é constitucional).
Jurídico	**Hans Kelsen**	**Constituição é norma pura**, sem interferência da filosofia, sociologia ou ciência política. Constituição reside no mundo do dever ser, e não do ser. Contraposição às ideias de Lassale. **Sentido lógico-jurídico:** norma fundamental hipotética, pressuposto de validade da Constituição. **Sentido jurídico-positivo:** norma suprema, fundamento de validade das demais normas.
Normativo	**Konrad Hesse**	Por ter status de norma jurídica, **Constituição seria dotada de força normativa** suficiente para vincular e impor os seus comandos.
Culturalista	**J. H. Meirelles Teixeira**	Constituição é produto de um **fato cultural**, produzido pela sociedade e que sobre ela pode influir. A concepção culturalista levaria ao conceito de **Constituição Total** (abrange aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos).

1.2. CLASSIFICAÇÃO (TIPOLOGIA) DAS CONSTITUIÇÕES

As constituições podem ser classificadas de várias maneiras, a depender do critério utilizado. Aliás, você verá que muitas vezes um conceito quer dizer a mesma coisa que outro, só que verificados por outro ângulo.

[10] TEIXEIRA, J. H. Meirelles. *Curso de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 58-59.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Quer um exemplo: em regra, as Constituições mais enxutas (quanto à extensão, sintéticas) tratarão apenas daqueles pontos essencialmente constitucionais (quanto ao conteúdo, material).

Em sentido oposto, aquelas mais detalhadas e longas (quanto à extensão, analíticas ou prolixas) trarão muita coisa que sequer deveria estar no texto constitucional (quanto ao conteúdo, formal). É o que acontece com a Constituição brasileira, que tem até e a definição de onde fica um Colégio específico...

São incontáveis as classificações doutrinárias. Eu não tentaria esgotá-las. Meu intuito, você bem sabe, é prepará-lo para a prova. Pensando nisso, vou trabalhar como as classificações mais importantes, destacando o quanto elas caem.

Ah, em cada classificação eu apontarei onde se encaixa a nossa Constituição atual, ok?

a) Quanto à origem: ponto muito cobrado nas provas. A ideia aqui é saber se a Constituição nasceu democraticamente ou não. **A Constituição brasileira atual é promulgada**.

QUANTO À ORIGEM	
Promulgada	Fruto do trabalho de uma **Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo**. Ex.: brasileiras de 1891, 1934 e de 1946.
Outorgada	**Imposta** pelo governante, **não contando com a participação popular**. Ex.: Brasileiras de 1824, 1937, 1967/1969.
Cesarista	Também chamada de Bonapartista. Embora seja outorgada, nela **há participação popular** por meio de referendo. No entanto, **essa participação não é democrática**, pois apenas ratifica a vontade do detentor do poder. Ex.: Constituição chilena, do ditador Alberto Pinochet.
Pactuada	Também chamada de Dualista. Origina-se de um **compromisso firmado entre o rei e o Poder Legislativo**. Nesse caso, o monarca se sujeita aos esquemas constitucionais (monarquia limitada). Ex.: Magna Carta de 1215.

ATENÇÃO

A Magna Carta do Rei João Sem Terra (Inglaterra, 1.215) é importante por três pontos principais: ***1º)*** É nela que surge o Habeas Corpus, principal remédio constitucional; ***2º)*** É nela que também surge o devido processo legal, princípio mais importante do direito processual; e ***3º)*** Ela ainda inaugura uma classificação da Constituição, baseada no pacto entre duas forças (Rei + Legislativo).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Quanto à forma: aqui é bem mais simples. **A Constituição brasileira atual é escrita**.

QUANTO À FORMA	
Escrita	Também chamada de instrumental. Composta por um conjunto de **regras organizadas** em um único documento. Ex.: brasileiras.
Costumeira	Não escrita, é composta por textos esparsos, baseando-se nos usos, costumes, jurisprudência. Ex.: inglesa.

c) Quanto ao modo de elaboração: essa é uma das queridinhas das Bancas examinadoras. Logo, **é importante você ficar de olho**! **A Constituição brasileira atual é dogmática**.

QUANTO AO MODO DE ELABORAÇÃO	
Dogmática	Sempre escrita, é **elaborada em um dado momento**, por um órgão constituinte, segundo dogmas ou ideias. Ex.: CF/1988.
Histórica	Também chamada costumeira. Resulta da **lenta formação histórica**, das tradições de uma sociedade. Ex.: Constituição inglesa.

d) Quanto à extensão: em português bem claro, as Constituições podem ser grandes, falando demais, ou pequenas, dizendo o mínimo necessário. Nossa Constituição tem 250 artigos e já sofreu cerca de 100 emendas, exatamente por ser extensa (prolixa, analítica). A dos EUA contém pouquíssimos artigos, mesmo já contando com mais de 200 anos. **A Constituição brasileira atual é analítica.**

QUANTO À EXTENSÃO	
Analítica	Também chamada de dirigente. **É extensa, prolixa**, descendo às minúcias. Normalmente, traz regras que deveriam estar na legislação infraconstitucional. Ex.: CF/1988.
Sintética	Também chamada de negativa. Traz apenas **princípios essenciais**, que se ajustam com o tempo. Normalmente dura mais tempo. Ex.: americana.

e) Quanto ao conteúdo: Vou pedir para você lembrar algo que eu disse lá nos conceitos de Constituição. Para ser mais específico, no sentido político, Carl Shmitt diferenciava Constituição de leis constitucionais.

Pois é, essa distinção casa bem aqui. É classificada como "material" a Constituição que versa apenas sobre matérias realmente constitucionais, como Organização do Estado e dos Poderes, além dos Direitos e Garantias Fundamentais.

A doutrina ensina que **a constituição material é concebida em sentido amplo e em sentido estrito**. No primeiro caso, ela se identifica com a organização total do Estado, com regime político. Por sua vez, em sentido estrito, a constituição material consagra as normas,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

inseridas ou não num documento escrito, que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Ou seja, pode-se falar em constituição material mesmo nas constituições históricas.

Por outro lado, quando o texto abrigasse muita 'perfumaria', muitos 'extras', ela seria classificada como "formal". Quer um exemplo? O artigo 242 da Constituição se preocupou em dizer que o Colégio Pedro II fica no Rio de Janeiro. Ora, imagine a quantidade de escolas públicas em nosso país. Pense aí se isso realmente precisaria estar dentro da Constituição. Sem dúvidas, **a Constituição brasileira atual é formal**.

QUANTO AO CONTEÚDO	
Material	Também chamada de substancial. No seu texto **só há matéria realmente constitucional**. Ex.: americana.
Formal	**Toda regra** contida no texto é considerada constitucional. Ex.: CF/1988.

ATENÇÃO

Com a inserção do § 3º, no artigo 5º, da Constituição, mesmo algumas normas que estão **fora** do texto constitucional (tratados internacionais que tratam de direitos humanos aprovados sob o rito das emendas à constituição) são considerados como norma constitucional.

f) Quanto à estabilidade ou possibilidade de alteração ou alterabilidade: viu a variação de nomes desta classificação? Pois vá se acostumando a todos eles, uma vez que são frequentadores assíduos das provas de concurso dos mais diferentes níveis de dificuldade. **A Constituição brasileira atual é <u>rígida</u>**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUANTO À ESTABILIDADE (OU ALTERABILIDADE)	
Imutável	Nela, **veda-se qualquer alteração**. A imutabilidade pode ser absoluta ou relativa (certo período). A **brasileira de 1824** só previa possibilidade de modificação **após quatro anos** de sua existência.
Super-rígida	**Posição minoritária**, defendida por Alexandre de Moraes. Para ele, a brasileira seria mais do que rígida, por conta das cláusulas pétreas.
Rígida	Exige **processo legislativo mais complexo de alteração**, se comparadas às demais espécies normativas.
Flexível	**Não possui processo legislativo mais rigoroso** em comparação às normas infraconstitucionais.
Semirrígida	**Para algumas matérias** se exige processo legislativo mais complexo; para outras, não. Ex.: brasileira de 1824 (passado o período de imutabilidade, tornou-se semirrígida).
Fixa	Também chamada de silenciosa. Só pode ser modificada pelo mesmo poder que a criou. Não preveem procedimentos para a modificação de seu texto. Ex.: espanhola de 1876.

g) Quanto ao conteúdo ideológico: fique de olho para não confundir com a classificação aí de baixo... **A Constituição brasileira atual é <u>social (dirigente)</u>**.

QUANTO AO CONTEÚDO IDEOLÓGICO	
Liberal	Também chamada de negativa. Preocupa-se exclusivamente em limitar a atuação do Estado. Veicula direitos fundamentais de 1ª dimensão.
Social	Também chamada de dirigente. Incorpora também direitos de 2ª dimensão. Direciona as ações governamentais.

h) Quanto à ideologia: repare que aqui a preocupação não se o texto constitucional trata ou não das diferentes gerações/dimensões de direitos fundamentais. O enfoque principal é definir se há – ou não – mais de uma ideologia na elaboração da Constituição. **A Constituição brasileira atual é <u>eclética</u>**.

QUANTO À IDEOLOGIA	
Ortodoxa	Reflete um só pensamento ideológico. Ex.: chinesa.
Eclética	Também chamada de compromissória. É fruto da conjunção entre as diferentes ideologias de um Estado. Ex.: brasileira.

i) Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico): <u>todo cuidado aqui é pouco</u>! Esta classificação 'chove' nos concursos para carreiras de ponta. Aliás, de poucos anos para cá ela se popularizou e tem caído em muitos concursos para analista (nível superior) e até para técnico (nível médio).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Segundo seu idealizador, o professor Karl Lowestein, haveria uma espécie de gradação, comparando o respeito à Constituição pelos detentores do poder.

Não sei como você pensará, mas em minha cabeça é como se tivéssemos uma escada com três degraus. No primeiro (lá em baixo) está a Constituição "semântica", na qual **não há** correspondência com a realidade. Canotilho, renomado professor Português, a chama de "Constituição de fachada".

Seguindo, no próximo degrau (o do meio) teríamos as Constituições nominais ou nominalistas. Elas teriam um bom texto, mas não haveria a correspondência com "o mundo real".

Por fim, você verá que o terceiro degrau contempla o modelo ideal de Constituição, que é a normativa. Nela, há plena correspondência entre a vida real e o mundo do dever ser.

Aqui, mais um ponto de tensão: na doutrina, alguns nomes de peso falam que a Constituição brasileira atual é – *ou pretende ser* – normativa, enquanto outros defendem que ela seja nominal ou nominalista.

Sendo muito honesto com você que está estudando por meio de meus PDFs, **para mim** *a Constituição brasileira é nominal/nominalista*, na medida em que, embora a CF realmente tenha boas intenções, não há uma perfeita correspondência entre seu texto e o mundo real.

Ainda sobre o tema, é importante lembrar as palavras de Bernardo Gonçalves Fernandes, segundo o qual "Loewestein busca o que a Constituição realmente é em um momento histórico". Esse mesmo autor cita as Constituições brasileiras de 1934, 1946 e de 1988 como exemplos de nominais. Por outro lado, as de 1937, de 1967 e de 1969 seriam semânticas. Ele ainda cita as Constituições americana de 1787; alemã de 1949 e francesa de 1958 como normativas.[11]

De todo modo, estou preparando você para fazer provas e o que eu penso não é o que será cobrado. Após uma reunião entre os professores do time do Gran na cadeira de Direito Constitucional, prevaleceu a orientação de que a nossa Constituição atual seria normativa.

Há ainda um detalhe que não pode passar em branco e foi lembrado por Flávio Martins: é que **o próprio Karl Lowestein aponta o constitucionalismo brasileiro como exemplo normativo**, ao lado da Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, México e Costa Rica. Isso, claro, mesmo diante de interrupções ocasionais.[12]

Pesou também nesse sentido o que foi cobrado pelas bancas Cespe, Iades, Quadrix e UEG nas últimas vezes em que o tema foi explorado.

Enfim, sem sofrimento, marque que a Constituição brasileira atual é normativa.

---

[11] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 51.

[12] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 244.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUANTO À CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE (CRITÉRIO ONTOLÓGICO)	
Normativa	Nela há correspondência entre a teoria e prática. Haveria o respeito do texto pelos detentores do poder. Seria **o modelo ideal de Constituição**. Seriam exemplos de Constituição normativa, segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, a Constituição americana de 1787, a Constituição alemã de 1949 e a Constituição francesa de 1958. **Nas provas, prevalece a ideia de que a brasileira de 1988 seria normativa**.
Nominal	Também chamada de nominalista. A Constituição seria um **documento político, sem força normativa**, pois os detentores do Poder não respeitariam seu texto. Seria uma carta de intenções. Bernardo Gonçalves Fernandes e Marcelo Novelino estão entre aqueles que defendem ser nominal (e não normativa) a Constituição de 1988. Repito: **nas provas** tem prevalecido a orientação de que a brasileira atual seria normativa.
Semântica	Usada pelos detentores do poder como **instrumento para seus propósitos de dominação da sociedade**. Canotilho conceitua esse modelo como **'Constituição de Fachada'**. Ex.: brasileira de 1937.

ATENÇÃO

Há outra classificação doutrinária, segundo a qual uma Constituição também pode ser chamada de semântica. Nessa vertente, o texto não seria dotado de clareza, exigindo o uso de outros métodos de interpretação que não apenas o gramatical.

Abrindo um parêntese, seguindo essa lógica, todas as Constituições seriam semânticas, pois a necessidade de utilização dos mais variados métodos de interpretação é própria do sistema normativo. Seja como for, é uma classificação doutrinária que pode ser perguntada a você. Então, é bom conhecer...

j) Quanto à finalidade: <u>outra classificação que "está na moda"</u>. Explico: a classificação que você vê agora, antes praticamente esquecida, voltou a ser perguntada – e com força! – pelos Examinadores. **A Constituição brasileira atual é <u>dirigente</u>** (*repare que é o mesmo nome dado à classificação quanto ao conteúdo ideológico*).

QUANTO À FINALIDADE	
Garantia	É uma Constituição negativa. Traz **apenas a limitação dos poderes estatais** (direitos de 1ª dimensão).
Balanço	Espelha **certo período político**, findo o qual é formulado um novo texto constitucional para o período seguinte. Ex.: Constituições da antiga União Soviética.
Dirigente	Possui **texto extenso**. Conta com normas programáticas, direcionando a atuação dos órgãos estatais. Elenca direitos sociais (2ª dimensão).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

k) Quanto aos sistemas: pouco cobrada, mas você precisa saber. **A Constituição brasileira atual é principiológica**.

QUANTO AOS SISTEMAS	
Principiológica	Tem como **base fundamental os princípios** constitucionais. Podem existir regras, mas predominam os princípios. Ex.: brasileira.
Preceitual	Tem como **critério básico as regras** constitucionais, dando ênfase a elas, embora também possua princípios. Ex.: mexicana de 1917.

l) Quanto à unidade documental: mais uma que é pouco cobrada, mas você precisa saber, pois seguro morreu de velho. **A Constituição brasileira atual é orgânica/unitextual/codificada**.

QUANTO À UNIDADE DOCUMENTAL	
Orgânica	Também chamada de codificada. Ela é escrita e sistematizada em um único documento. Ex.: brasileira.
Inorgânica	Também chamada de legal. Não se verifica a unidade textual. É formada por vários documentos. Ex.: israelense.

m) Quanto à origem de sua decretação: em regra, a Constituição é criada e aplicada no mesmo País. Ocorre que há casos (raros) de Constituições criadas em um País, mas para ser aplicada em outro. **A Constituição brasileira atual é autoconstituição ou homoconstituição**.

QUANTO À ORIGEM DE SUA DECRETAÇÃO	
Homoconstituição	Também chamada de autoconstituição. Ela é redigida e aplicada no mesmo país. É a regra no mundo e também no Brasil.
Heteroconstituição	São Constituições que surgem por imposição de outros Estados. Exemplo: as Nações Unidas impuseram as Constituições da Namíbia (1990) e do Camboja (1993). Ainda são citadas as Constituições da Albânia, do Chipre, da Bósnia-Herzegovina etc.

n) Quanto à função: as Constituições podem ser provisórias ou definitivas. As provisórias (ou pré-Constituições) também recebem o nome de Constituições Revolucionárias e trariam normas estruturando o poder político no intervalo entre um e outro regime, estabelecendo o modo de eliminação e erradicação do regime anterior. Por outro lado, Jorge Miranda diz que as Constituições definitivas (ou duração indefinida para o futuro) são aquelas que pretendem ser o produto final do processo constituinte[13]. **A Constituição brasileira atual é definitiva**.

[13] MIRANDA, Jorge. *Manual de direito constitucional*. 5. ed. Coimbra. 2003. Tomo II, p. 108.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUANTO À FUNÇÃO	
Provisória	Também chamadas de Constituições revolucionárias ou pré-constituição. Trazem normas estruturando o poder político no intervalo entre um e outro regime.
Definitiva	São aquelas que pretendem ser o produto final do processo constituinte. Ex.: Constituição de 1988.

Mas há outras classificações que de vez em quando "dão o ar da graça" nas provas.

Exemplificando, fala-se em **Constituição.com** ou em **Crowdsourcing** para as Constituições elaboradas pelos governantes tendo como ponto de partida a opinião popular colhida em redes sociais sobre temas relevantes.

Ainda, as **Constituições em Branco** seriam aquelas em que não há limitações explícitas ao poder de emenda. Nelas, a reforma estaria subordinada à discricionariedade do governante.

A **Constituição Suave (ou dúctil)**, citada por Gustavo Zagrebelsky, seria aquela que não conta com exageros ou preceitos impossíveis de serem realizados.

Carlos Ari Sundfeld chama a **Constituição** de 1988 de "**Chapa-Branca**", porque traz regras, em sua maioria, criadas para atender o *lobby* de entidades estatais e paraestatais e de seus membros. Ele defende, então, que as normas constitucionais têm a intenção principal de tutelar privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes e dirigentes do setor público[14].

Por sua vez, tem um conceito que você deve ficar atento(a), pois foi cobrado, por exemplo, nas provas de Juiz de Direito do TJ do Ceará (2018) e de Procurador do MP de Contas do Pará (2019), ambas organizadas pelo CESPE/CEBRASPE: é a chamada **Constituição Ubíqua**.

Tratada por Daniel Sarmento[15], a ubiquidade constitucional explicita que a referência a normas e valores constitucionais é um elemento onipresente no direito brasileiro pós-Constituição de 1988. Essa inflação de assuntos no texto constitucional seria uma marca das constituições analíticas, que faz com que qualquer disciplina jurídica encontre um ponto de contato com a Constituição (pan-constitucionalização). O caráter detalhista da Constituição incorporaria uma infinidade de valores substanciais, princípios abstratos e normas concretas em seu programa normativo. Desse modo, a **Constituição Ubíqua é onipresente**, uma vez que qualquer disciplina jurídica encontra ponto de contato com a Constituição.

Poderia ser falado em **valores contraditórios** (como já cobrado em prova), na medida em que há confluência de diversos núcleos de poder atuando na formulação.

---

[14] SUNFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. *Jornal Carta Forense*. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/direito-administrativo-para-ceticos/10817>.

[15] SARMENTO, Daniel. Ubiquidade constitucional: os dois lados da moeda. *In*: _____. *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Lumen *Juris*, 2006. p. 167-205.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Aliás, lá no direito penal a gente aprende o mnemônico **LUTA** para lembrar que em relação ao **L**ugar do crime o CP usa o critério da **U**biquidade e quanto ao **T**empo do crime se adotou a teoria da **A**tividade.

Aceitar que o crime foi cometido no lugar da ação/omissão ou onde se produziu/deveria se produzir o resultado é um tanto quanto contraditório, não?

Eu citei a prova do TJ/CE, não foi? Ela trouxe mais uma pérola, que é o conceito de **Constituição Subconstitucional**, que é citado na doutrina brasileira pelo Professor Uadi Lammêgo Bulos, que, por sua vez, reporta ao alemão Hild Krüger.

O autor brasileiro afirma que Krüger ensinou que as constituições só devem trazer aquilo que interessa à sociedade como um todo, sem detalhamentos inúteis, e que a praxe de inserir assuntos infindáveis nas Constituições geraria um totalitarismo constitucional.

Em suas palavras, Constituição seria somente aquilo que diz respeito à comunidade, à nação e ao sistema político e que todo o restante não se pode considerar constituição do Estado, no sentido exato da palavra, porque foi fruto dos interesses de certos grupos, que, num determinado estágio de evolução do País, acreditaram que o simples ato de se consagrar autorizações constitucionais seria o bastante para o cumprimento de todas as promessas formuladas.

É exatamente dentro desse contexto que Krüger explica o excesso de temas constitucionalizados formam as Constituições Subconstitucionais ou, simplesmente, Subconstituições.

Assim, as Subconstituições seriam um conjunto de normas que, mesmo elevadas formalmente ao patamar constitucional, não são verdadeiramente, porque encontram-se limitadas nos seus objetivos (**https://jus.com.br/artigos/11798/vinte-anos-da-constituicao-de-1988**).

Soraya Lunardi e Dimitri Dimoulis citam que a Constituição de 1988 seria **Liberal-Patrimonialista**, uma vez que, apesar de conter certas aparências e proclamações, "objetiva preponderantemente garantir os direitos individuais, preservando fortes garantias ao direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia".[16] Os direitos sociais mencionados na Constituição seriam dotados de caráter de proclamação programática, e não de norma densa e vinculante como ocorre com os direitos individuais e patrimoniais.

RESUMO DA ÓPERA: a Constituição brasileira de 1988 é **promulgada** (origem); **escrita** (forma); **dogmática** (modo de elaboração); **analítica** (extensão); **formal** (conteúdo); **rígida** (estabilidade); **social** (conteúdo ideológico); **eclética** (ideologia); **normativa** (correspondência

[16] LUNARDI, Soraya; DIMOULIS, Dimitri. Teorias explicativas da Constituição brasileira. *In*: *Resiliência Constitucional: compromisso maximizador, consensualismo político e desenvolvimento gradual*. São Paulo: Direito GV, 2013. p. 12.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

com realidade); **dirigente** (finalidade); **principiológica** (sistemas); **orgânica** (unidade de documentação); **autoconstituição** (modo de decretação); e **definitiva** (função).

O PULO DO GATO

A CONSTITUIÇÃO É PEDRA (**P**romulgada, **E**scrita, **D**ogmática, **R**ígida e **A**nalítica).

1.3. O PAPEL DA CONSTITUIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO

O Professor Virgílio Afonso da Silva[17], filho de José Afonso da Silva, critica as classificações tradicionalmente feitas pela doutrina por entender que elas possuem pouca utilidade prática.

Em substituição, ele propõe a análise sobre qual seria o papel da Constituição, a sua função em um ordenamento jurídico. Nesse cenário, é analisada a liberdade de conformação atribuída ao legislador, aos cidadãos e à autonomia privada.

Aqui, é importante ver que a doutrina brasileira soma às orientações de Virgílio Afonso aquilo que Gustavo Zagrebelsksy nomina de Constituição dúctil, maleável, suave.

Vejamos cada uma delas.

1.3.1. CONSTITUIÇÃO-LEI

Nesse contexto, a Constituição é tida como um conjunto de normas como qualquer outro, sem supremacia em relação às demais leis e normas do país. Ela serviria como diretriz, com função indicativa, para a atuação legislativa.

Entender a Constituição como uma norma como qualquer outra se choca com a ideia de constituição rígida, modelo adotado pelo Brasil.

1.3.2. CONSTITUIÇÃO-FUNDAMENTO (CONSTITUIÇÃO-TOTAL)

Se no item anterior a Constituição era vista como um conjunto de normas como qualquer outro, na Constituição-total haveria pouco espaço para o legislador, para os cidadãos e para a autonomia privada.

Isso porque a Constituição seria fundamento, lei fundamental, de toda a vida social. Virgílio defende que a atividade legislativa seria mero instrumento de realização da constituição e

[17] SILVA, Virgílio Afonso. *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*. São Paulo: Malheiros, 2005.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

critica a amplitude das normas de repetição (ou reprodução) obrigatória, o que deixa pouca margem de autonomia para as Constituições Estaduais.

1.3.3. CONSTITUIÇÃO-MOLDURA (CONSTITUIÇÃO-QUADRO)

Você viu dois extremos até aqui. Mas, como se sabe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra...

É em tal contexto que surge a Constituição-moldura, balizando a atuação do legislador, servindo como um limite. A moldura estaria sem tela e sem vidro.

Caberia à jurisdição constitucional a tarefa de controlar se o legislador agiu ou não dentro dos limites impostos pela Constituição. Haveria, assim, um espaço para a ser preenchido pela oportunidade política.

1.3.4. CONSTITUIÇÃO DÚCTIL (CONSTITUIÇÃO SUAVE)

O jurista italiano Gustavo Zagrebelsky é seu idealizador. Bernardo Gonçalves Fernandes pontua que nas sociedades atuais o papel das Constituições não deve ser a realização de um projeto predeterminado de vida, cabendo-lhe apenas a tarefa de assegurar condições possíveis para uma vida comum, sem promover um engessamento, um modelo único.

É daí que surge a razão do uso da palavra suave (dúctil, leve, maleável) na medida em que a Constituição teria por objetivo acompanhar a descentralização do Estado e a partir daí, refletiria o pluralismo ideológico, moral, político e econômico existente nas sociedades.

Ainda de acordo com Bernardo Fernandes, a concepção de Zagrebelksy se aproximaria à teoria discursiva do direito e da democracia de Jünger Habermas, jurista alemão que trabalha a perspectiva de constitucionalismo procedimental do Estado Democrático de Direito.[18]

Em resumo, a constituição seria o ponto de convergência, e não o ponto de partida.

1.4. ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

Aqui está o tipo de assunto que, se cair alguma questão, você não pode perder. Isso porque o assunto é curto, simples e dá pra ir direto ao ponto.

Ou seja, uma lida rápida garante o acerto.

Vamos lá!

[18] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 48.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A classificação que cai em prova (de todas as Bancas) foi idealizada pelo Professor José Afonso da Silva – ele também é o pai da classificação tradicional da Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais.

Para o autor[19], existem **cinco categorias de elementos**. Veja:

1.4.1. ELEMENTOS ORGÂNICOS

São as normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder.

EXEMPLO

Título III – Organização do Estado; Título IV – Organização dos Poderes.

> **DICA**
> Os elementos **orgânicos tratam da Organização do Estado e da Organização dos Poderes.** *Olhando assim, fica mais mole do que sopa de minhoca...*

1.4.2. ELEMENTOS LIMITATIVOS

Muito cobrados em provas! **Os elementos limitativos limitam a ação dos poderes estatais**, estabelecendo balizas do Estado de Direito e consubstanciando o rol dos direitos fundamentais.

EXEMPLO

Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Para você lembrar mais fácil, os direitos e garantias do artigo 5º da Constituição estão dentro da 1ª geração/dimensão dos direitos fundamentais, surgida para proteger os cidadãos contra o Estado. Em outras palavras, **eles impõem limites ao Estado**. Daí o nome!

1.4.3. ELEMENTOS SOCIOIDEOLÓGICOS

Acredito que este seja o campeão nas provas! Então, fique de olhos bem abertos!

É o seguinte: **os elementos socioideológicos são ligados aos Direitos Sociais (artigos 6º a 11) e à Ordem Social (artigos 193 a 232).**

Enquanto os elementos limitativos estão mais próximos da 1ª geração/dimensão dos direitos fundamentais, os elementos socioideológicos se ligam à 2ª geração/dimensão.

[19] SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 44-45.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

E é na 2ª geração/dimensão que nasce a ideia de atuação positiva do Estado, que atuará dentro da ideia do *welfare state* ou Estado do bem-estar social, que ganhou força principalmente no período posterior à Primeira Guerra Mundial.

1.4.4. ELEMENTOS DE ESTABILIZAÇÃO CONSTITUCIONAL

Essa parte aqui é mais chatinha de lembrar, mas também sem grande complexidade.

Pense comigo: quando estamos numa situação de grave perturbação, precisamos de instrumentos para restabelecer a ordem social. É aí que entram, por exemplo, as figuras do Estado de Sítio e do Estado de Defesa.

Nesse mesmo balaio aí eu colocaria a Intervenção, tanto federal quanto estadual. Isso porque a característica central de uma Federação é a autonomia dos Entes Federados. A intervenção, medida extrema, mexe diretamente com a autonomia. Ou seja, ela deve ser usada de modo excepcional.

Insere-se também nos elementos de estabilização a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), o que pode causar certa estranheza numa primeira análise.

Mas se você pensar bem, a ADI existe para retirar do ordenamento normas que sejam inconstitucionais. Dito de outro modo, ela (a norma inconstitucional) estará desestabilizando o sistema normativo vigente. É esse o motivo de colocação da ADI no rol dos elementos de estabilização.

1.4.5. ELEMENTOS FORMAIS DE APLICABILIDADE

No último grupo você vai colocar as perfumarias do começo e do final da Constituição. Ou seja, **coloque aí nos elementos formais de aplicabilidade o Preâmbulo** (vem antes do texto constitucional) **e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT** –, que aparece depois do artigo 250 da Constituição.

Para fechar, acrescente o **artigo 5º, § 1º, da Constituição**, segundo o qual "**as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata**".

Repito mais uma vez: **prestando atenção apenas às palavras você acertaria o item**, pois **é elemento formal de aplicabilidade o dispositivo que fala em aplicação imediata dos direitos fundamentais**.

Sistematizando:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Elementos	Conteúdo
Orgânicos	Regulam a estrutura do Estado e do Poder. Ex.: Títulos III e IV - Organização do Estado e Organização dos Poderes.
Limitativos	Limitam a ação dos poderes estatais. Ex.: Título II – Direitos e Garantias Fundamentais.
Socioideológicos	Está ligado aos direitos sociais (artigos 6º a 11) e à Ordem Social (artigos 193 a 232). Direitos de 2ª geração/dimensão.
Estabilização constitucional	Usados em situação de grave perturbação. Ex.: estado de defesa e estado de sítio. A ADI também entra aqui, porque serve para tirar normas inconstitucionais do sistema.
Formais de aplicabilidade	Engloba o preâmbulo, o ADCT e o artigo 5º, § 1º.

1.5. BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE

Primeira coisa que surge é a necessidade de definirmos o que seria o bloco de constitucionalidade.

Nesse cenário, podemos afirmar que ele seria a junção entre as normas materialmente constitucionais, que estão fora da CF, com o texto formal da Constituição.

Bernardo Gonçalves Fernandes cita que poderiam ser incluídos no conceito de bloco de constitucionalidade as normas infraconstitucionais materialmente constitucionais, os costumes jurídico-constitucionais e as jurisprudências constitucionais[20].

Uadi Lammêgo Bulos cita que o bloco de constitucionalidade é o conjunto de normas e princípios extraídos da Constituição, que serve de paradigma para o Poder Judiciário averiguar a constitucionalidade das leis. Também é conhecido como parâmetro constitucional, pois por seu intermédio as Cortes Supremas, a exemplo do nosso STF, afeririam a parametricidade constitucional das leis e atos normativos perante a CF.[21]

Flávio Martins, por sua vez, defende que "para saber se uma lei é constitucional ou não, devemos fazer uma análise de compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com: a) o texto constitucional; b) os princípios decorrentes da Constituição, implícitos ou expressos; c) os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados no Direito brasileiro com força de norma constitucional".[22]

Mas fique atento, porque **o STF adota o conceito restrito do bloco de constitucionalidade**, segundo o qual servem de parâmetro para a análise de compatibilidade de leis ou atos

[20] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional.* 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 57.

[21] BULOS, Uadi Lammêgo. *Curso de direito constitucional.* São Paulo: Saraiva, 2006. p. 98-99.

[22] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 487.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

normativos em relação à nossa Constituição o próprio texto e os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados no rito previsto pelo § 3º do artigo 5º da CF.

1.6. CONSTITUCIONALISMO E NEOCONSTITUCIONALISMO

1.6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Não se pode falar em **neo**constitucionalismo sem antes definir o que vem a ser o constitucionalismo. Segundo Canotilho, "constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo".[23]

Já Uadi Lammêgo Bulos diz que o constitucionalismo pode ser visualizado sob diferentes enfoques, não possuindo uma conceituação fechada, unívoca. Ele ressalta que o termo constitucionalismo tem dois significados diferentes: **em sentido amplo**, significa o fenômeno relacionado ao fato de todo Estado possuir uma Constituição em qualquer época da humanidade, independentemente do regime político adotado ou do perfil jurídico que se lhe pretenda atribuir. Por outro lado, **em sentido estrito**, significa a técnica jurídica de tutela das liberdades, surgida nos fins do século XVIII, que possibilitou aos cidadãos o exercício, com base em Constituições escritas, dos seus direitos e garantias fundamentais, sem que o Estado lhes pudesse oprimir pelo uso da força e do arbítrio.[24]

Seguindo em frente, Pedro Lenza[25] divide a evolução histórica da Europa em quatro grandes eras **(também chamadas de ciclos)**, a saber, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, pontuando em cada um desses momentos os movimentos constitucionais.

Nesse contexto, fundado nas análises feitas por Karl Loewestein, Lenza aponta que entre os hebreus, ainda que timidamente, teria surgido o constitucionalismo. Naquele Estado teocrático foi assegurada aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos.

Avançando para a Idade Média, temos um grande marco para o direito constitucional, com a elaboração da Magna Carta de 1.215, também chamada de Carta do Rei João Sem Terra. Para parte da doutrina, esse documento consagraria a origem do princípio do devido processo legal e também da garantia do *habeas corpus*.

---

[23] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 51.

[24] BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição federal anotada*. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 7.

[25] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 50-51.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Na Idade Moderna, era comum a elaboração dos pactos e forais ou cartas de franquia, documentos que almejavam resguardar direitos individuais. Nessa toada, surgem o *Habeas Corpus Act* (1679) e o *Bill of Rights* (1689).

Os dois marcos históricos mais relevantes do constitucionalismo moderno foram as Constituições norte-americana de 1787 e a francesa de 1789, sendo esta última marcadamente influenciada pelos pensadores do Iluminismo.

As inspirações liberais predominantes na época da Revolução Francesa acabaram levando a uma profunda desigualdade social, com a concentração de renda nas mãos de poucos, aprofundando a luta de classes.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, cresceu a necessidade de uma maior intervenção do Estado, com a implementação de políticas públicas e a preservação de direitos sociais.

Nascia, aí, a segunda geração/dimensão de direitos fundamentais, centrada na política do Bem-Estar Social (*welfare state*). Esses novos ideais foram consagrados explicitamente nas Constituições do México (1917) e da Alemanha (1919), influenciadas em parte pela Encíclica *Rerum Novarum*, escrita pelo Papa Leão XIII no ano de 1891.

Ainda dentro do constitucionalismo contemporâneo, surgem os direitos de terceira e de quarta gerações/dimensões, entendidos aqueles como os transindividuais, calcados na fraternidade, na solidariedade.

Paulo Bonavides[26] defende que a quarta dimensão decorreria da influência da globalização política na esfera jurídica. Haveria uma universalização dos direitos fundamentais.

Além disso, haveria também a atenção a questões ligadas à área da engenharia genética, que poderiam colocar em risco a própria existência da raça humana, relacionadas ao estudo da bioética, biodireito.

Pedro Lenza destaca, de outro giro, que o constitucionalismo do futuro terá de trabalhar na consolidação dos direitos de terceira geração/dimensão, "incorporando à ideia de constitucionalismo social os valores do constitucionalismo fraternal e de solidariedade, avançando e estabelecendo um equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e alguns excessos do contemporâneo".[27]

Embasado na doutrina do professor argentino José Roberto Dromi, Marcelo Novelino pontua que "o constitucionalismo do futuro está no equilíbrio entre as concepções dominantes do constitucionalismo moderno e os excessos praticados no constitucionalismo contemporâneo".[28] Ele ainda aponta alguns valores fundamentais que devem permear as Constituições daqui para a frente: verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade.

---

[26] BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 524-526.

[27] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 53.

[28] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 60.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A título ilustrativo, o valor verdade excluiria das constituições promessas impossíveis de serem realizadas.

1.6.2. O NEOCONSTITUCIONALISMO

Muito se fala na doutrina acerca do **neoconstitucionalismo**, que consistiria em um movimento que **busca reaproximar do direito da ética e da moral**.[29]

Bernardo Gonçalves Fernandes pontua que a expressão neoconstitucionalismo representa um novo constitucionalismo, de cunho contemporâneo, que chegou ao Brasil oriundo da doutrina constitucional espanhola e italiana, não sendo fruto da tradição alemã ou norteamericana.[30]

Com propriedade, Luís Roberto Barroso acentua que o neoconstitucionalismo estaria fundado em **três relevantes marcos**, quais sejam, o **histórico**, o **filosófico** e o **teórico**.[31]

Com efeito, na visão desse professor, o **marco histórico** do novo direito constitucional, na Europa continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália. Em nosso país, o grande ponto de transformação foi a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar.

Já o **marco filosófico** do novo direito constitucional seria o pós-positivismo, que consagra a confluência das duas grandes correntes de pensamento – o jusnaturalismo e o positivismo.

No tocante ao **marco teórico**, Barroso cita três grandes transformações, responsáveis, a seu ver, pela subversão do conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional, a saber, "a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional".[32]

Avançando, Paulo Gustavo Gonet Branco afirma ser possível falar que o momento atual do constitucionalismo seria marcado pela superação da supremacia do Parlamento, prevalecendo a superioridade da Constituição sobre todos os poderes por ela constituídos.[33]

Bernardo Gonçalves Fernandes adverte que as perspectivas tidas como neoconstitucionalistas não são uníssonas, havendo, ao contrário, uma profunda divergência o que levaria à existência de neoconstitucionalismos.[34]

---

[29] Por essa razão, Dimitri Dimoulis aponta que o chamado neoconstitucionalismo é apenas uma "designação alternativa da corrente da teoria do direito conhecida como moralismo jurídico".

[30] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 58.

[31] BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito constitucional no Brasil. *JusNavigandi*, Teresina, ano 10, n. 851, 1º nov. 2005. Disponível em: <**http://jus.com.br/revista/texto/7547**>.

[32] BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito constitucional no Brasil. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 851, 1º nov. 2005. Disponível em: <**http://jus.com.br/revista/texto/7547**>.

[33] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 53.

[34] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 3. ed. 2ª tir. Rio de Janeiro: Lumen *Juris*, 2011. p. 34.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa diferença conceitual deriva da pluralidade de pensadores, como bem acentua Daniel Sarmento. Para ele, os adeptos do neoconstitucionalismo buscam embasamento no pensamento de juristas que se filiam a linhas bastante heterogêneas, como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Peter Härbele, Gustavo Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli e Carlos Santiago Nino, e nenhum destes se define hoje, ou já se definiu, no passado, como neoconstitucionalista.[35]

Fundado, pois, em uma gama de princípios constitucionais, dentre os quais desponta o princípio da solidariedade, **o constitucionalismo pós-moderno propõe uma releitura moral da Constituição**.

Dirley da Cunha Júnior aponta que o movimento do neoconstitucionalismo provocou uma mudança de postura dos textos constitucionais do pós-guerra. Em suas palavras, "se no passado as Constituições se limitavam a estabelecer os fundamentos da organização do Estado e do Poder, as Constituições do pós-guerra inovaram com a incorporação explícita em seus textos de valores (especialmente associados à promoção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais) e opções políticas gerais (como a redução das desigualdades sociais e específicas (como a obrigação de o Estado prestar serviços na área de educação e saúde)".[36]

Sei que você viu aí atrás que o Professor Luís Roberto Barroso indica o pós-positivismo como marco filosófico do neoconstitucionalismo. Acontece que Bernardo Gonçalves Fernandes leciona que o neoconstitucionalismo não poderia ser confundido com o pós-positivismo. Isso porque, embora haja pontos convergentes, eles não seriam sinônimos.[37]

Falando sobre isso, Marcelo Novelino explicita que o pós-positivismo tem pretensão de universalidade, buscando desempenhar papel de teoria geral do direito, sendo aplicável a qualquer tipo de ordenamento jurídico. Por outro lado, o neoconstitucionalismo teria pretensões mais específicas, consistindo numa teoria desenvolvida para explicar as complexidades que envolvem um modelo específico de organização político-jurídica.

Novelino ainda vai além, dizendo que as abordagens pós-positivistas pressuporiam uma conexão entre direito e moral, ao passo que as abordagens neoconstitucionalistas reconheceriam que existe uma conexão entre as duas esferas em determinados modelos constitucionais.[38]

Avançando, o neoconstitucionalismo se apresenta como uma terceira via, representada pela tentativa de superação do positivismo e do jusnaturalismo, por meio de uma conciliação entre as premissas fundamentais das duas correntes.

---

[35] SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. *Leituras complementares de direito constitucional – Teoria da Constituição*. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 33.

[36] CUNHA JÚNIOR, Dirley. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. Salvador: JusPodivm. 2011. p. 41.

[37] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional.* 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 63.

[38] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 67.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Tem como características a importância dada aos valores e a elevação dos princípios à categoria de normas jurídicas. A norma é gênero, do qual são espécies os princípios e regras.

Propõe-se, também, uma **postura ativa do Magistrado**, no que se convencionou chamar de **ativismo ou construtivismo judicial**.

Com isso, o Juiz não poderia permanecer agindo de forma passiva. Deveria, ao contrário, atuar ativamente, viabilizando **a implementação de políticas públicas**, determinando, por exemplo, que o Estado forneça certos medicamentos não disponíveis na rede pública, ou, ainda, assegurando leitos em UTIs.

O tema ganhou novo capítulo quando, em junho de 2023, o STF fixou parâmetros para a intervenção do Judiciário em políticas públicas (RE 684.612).

Confira:

> 1. **A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas** voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, **não viola o princípio da separação dos poderes**.
> 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
> 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Deve-se lembrar, ainda, que o constitucionalismo moderno encontra, como uma de suas origens, a **teoria tridimensional do Direito** (fato – valor – norma) de Miguel Reale.

Aproveitando que estamos com a mão na cumbuca, melhor falar sobre o **Novo Constitucionalismo Plurinacional da América Latina**[39]. Para começo de conversa, há variações na nomenclatura, falando-se em constitucionalismo democrático latino-americano, em constitucionalismo indígena ou andino.

Seja lá como for, nele se dá ênfase à ideia de romper com os constitucionalismos tradicionais, que deixavam de lado a cultura dos povos tradicionais – em especial, indígenas e negros –, para valorizar a identidade e diversidade desses povos.

Busca-se, assim, a efetiva participação popular dos povos historicamente excluídos com meios de democracia direta. Esse movimento plurinacional foi visto nas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). No campo internacional, pode-se mencionar a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas (2007).

[39] Cf. SANTOS, Eduardo dos. Manual de direito constitucional. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2025, pág. 119.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Há críticas ao neoconstitucionalismo, principalmente na primordial importância dada ao Poder Judiciário, que estaria se sobrepondo ao Legislativo (ferindo, destarte, a teoria dos freios e contrapesos).

Lênio Streck fala em um **panconstitucionalismo**, movimento caracterizado pela constitucionalização em excesso, com a inclusão, na Constituição, de um grande plexo de matérias que deveriam ser reguladas pelo legislador. Esse é o caso do tratamento atinente a infância e adolescência, sistema tributário, direitos econômicos e empresariais etc.[40]

Fredie Didier sustenta que "os abusos e incompreensões revelam-se basicamente em uma postura de supervalorização dessas 'novidades': a) supervalorizam-se as normas-princípio em detrimento das normas-regra, como se aquelas sempre devessem preponderar em relação a essas e como se o sistema devesse ter mais normas-princípio do que normas-regra, ignorando o importantíssimo papel que as regras exercem no sistema jurídico: reduzir a complexidade do sistema e garantir segurança jurídica; b) supervaloriza-se o Poder Judiciário em detrimento do Poder Legislativo, em grave prejuízo à democracia e à separação dos poderes; c) supervaloriza-se a ponderação em detrimento da subsunção, olvidando que a subsunção é método bem adequado à aplicação das normas-regra, de resto as espécies normativas mais abundantes no sistema".[41]

Em interessante artigo sobre o tema, Humberto Ávila diz que se existe um modo peculiar de teorização e aplicação do Direito Constitucional, pouco importa a sua denominação, baseado num modelo normativo, ('da regra ao princípio'), metodológico ('da subsunção à ponderação'), axiológico ('da justiça geral à justiça particular') e organizacional ('do Poder Legislativo ao Poder Judiciário'), mas esse modelo não foi adotado, não deve ser adotado, nem é necessariamente bom que o seja, é preciso repensá-lo com urgência. Nada, absolutamente nada é mais premente do que rever a aplicação desse movimento que se convencionou chamar de 'neoconstitucionalismo' no Brasil.[42]

Ele prossegue, afirmando que "o 'neoconstitucionalismo', baseado nas mudanças antes mencionadas, aplicado no Brasil, está mais para o que se poderia denominar, provocativamente, de uma espécie de 'não constitucionalismo': um movimento ou uma ideologia que barulhentamente proclama a supervalorização da Constituição enquanto silenciosamente promove a sua desvalorização".[43]

---

[40] STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivistas. *Revista Eletrônica – Novos Estudos Jurídicos*, v. 14, n. 2, p. 3-26, 2º quadrimestre de 2009.

[41] DIDIER, Fredie. *Curso de direito processual civil*. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. v. 1, p. 27.

[42] ÁVILA, Humberto. 'Neoconstitucionalismo': entre a 'ciência do direito' e o 'direito da ciência'. *Revista eletrônica de Direito do Estado (REDE)*, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, janeiro/fevereiro/março 2009. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br.asp>.

[43] ÁVILA, Humberto. 'Neoconstitucionalismo': entre a 'ciência do direito' e o 'direito da ciência'. *Revista eletrônica de Direito do Estado (REDE)*, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, janeiro/fevereiro/março 2009. Disponível em:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mas vai além, porque o movimento do neoconstitucionalismo traz a reboque o do **neoprocessualismo**, que é, segundo Fred Didier, a fase atual do processo civil brasileiro.

O autor baiano menciona que o uso desse termo pode ser útil para caracterizar o estágio dos estudos sobre o direito processual. Ele ainda menciona que no Rio Grande do Sul essa fase do processo brasileiro seria conceituada como **formalismo-valorativo**. Este, por sua vez, pautar-se-ia pelo "reforço dos aspectos éticos do processo, com especial destaque para a afirmação do princípio da cooperação (...), que é decorrência dos princípios do devido processo legal e da boa-fé processual".[44]

É certo que, como todo novo movimento jurídico, podemos destacar que o neoconstitucionalismo não se apresenta livre a (justas) críticas. Mas, também é certo que ele representa um importante avanço, que servirá para dar maior concretude aos valores constitucionais e, se bem sopesado, não acarretará rachaduras à salutar estrutura da separação dos Poderes. Ao contrário, facilitará a consolidação das conquistas sociais.

1.7. PRINCÍPIOS E REGRAS

De saída, é importante lembrar que tanto princípios quanto regras pertencem a um gênero maior: ambos são normas jurídicas e **não** há hierarquia entre eles, porque temos que ter em mente a ideia da unidade da Constituição.[45]

Paulo Gustavo Gonet Branco prescreve que ambos descrevem algo que deve ser, "ambos se valem de categorias deontológicas comuns às normas – o mandado (determina-se algo), a permissão (faculta-se algo) e a proibição (veda-se algo)".[46]

Humberto Ávila cita outra espécie de norma, intitulada de **postulados normativos**.[47] Eles seriam **metanormas**, definidos como **deveres de segundo grau**.

Os postulados viriam para estabelecer a estrutura de aplicação e prescreveriam modos de raciocínio e argumentação relativo a outras normas.

Um dos postulados por ele mencionados seria o da proporcionalidade, que funcionaria como uma condição de possibilidade do raciocínio com princípios. O interessante é ver que Ávila chama a proporcionalidade de postulado, enquanto a doutrina majoritária a nomina

<www.direitodoestado.com.br.asp>.

[44] DIDIER, Fredie. *Curso de direito processual civil*. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. v. 1, p. 28.

[45] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 165.

[46] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional.* 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 72.

[47] ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.* 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. Aqui, um conselho deste velho concurseiro... leia o livro teoria dos princípios. Ele é fininho, mas de uma sabedoria incomum. Vai ajudar você nas provas objetivas e também nas demais fases do seu concurso. Fica a dica!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

como princípio, embora Bernardo Gonçalves Fernandes prefira intitulá-la de regra da proporcionalidade.

Pode-se apontar **dois tipos de postulados**: **específicos** (igualdade, razoabilidade e proporcionalidade) **e inespecíficos** (ponderação, concordância prática e proibição de excesso).

Ainda de acordo com Ávila, **um sistema não poderia ser formado apenas por princípios ou por regras**, porque, no primeiro caso ele seria excessivamente flexível, sem guias claros de comportamento. Por outro lado, caso houvesse somente regras, ele seria excessivamente rígido, formalista, sem dar espaço a soluções adaptadas ao caso concreto.

Avançando, vou reunir algumas diferenciações mais usuais em relação a regras e princípios, para depois trazer o raciocínio de alguns juristas mundiais que são expoentes no assunto.

Nesse sentido, quanto ao **critério da generalidade e abstração**, princípios seriam mais abstratos, na medida em que funcionariam como premissas aplicáveis a situações heterogêneas, enquanto as regras seriam mais concretas, restringindo-se a situações homogêneas, uma vez que parte do mesmo pressuposto fático.

Já no **critério da determinabilidade dos casos de aplicação**, os princípios seriam normas que demandam a mediação concretizadora por parte do legislador, do julgador ou da Administração. Por outro lado, as regras estariam aptas a serem aplicadas de forma imediata.

Canotilho[48] ensina que **os princípios teriam caráter multifuncional**, ao contrário das regras, uma vez que desempenhariam função argumentativa. Isso acontece porque eles são mais abrangentes que as regras, constituindo-se como instrumentos úteis para se desvendar a verdadeira razão de uma regra ou de outro princípio.

Usando o exemplo de que se valeu Paulo Gonet[49], o princípio da igualdade baliza o princípio da acessibilidade de todos aos cargos públicos. Este, por sua vez, legitima a regra que exige o concurso público para preenchimento desses cargos.

Mas tem um porém: nós podemos ter choque entre duas regras, entre dois princípios ou entre um princípio e uma regra. Nesse caso, o que fazer?

A doutrina, de modo geral, invoca os ensinamentos trazidos por Ronald Dworkin e por Robert Alexy. Em acréscimo, quero trazer para você as teses da superabilidade e da derrotabilidade.

Vamos ver esses pontos agora.

1.7.1. VISÃO DE RONALD DWORKIN E DE ROBERT ALEXY

Segundo Dworkin, haveria três espécies de normas: regras, diretrizes políticas e princípios.

---

[48] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 167.

[49] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 72.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em sua visão, **as regras devem ser aplicáveis no tudo ou nada**, ou seja, "se os fatos que uma regra estipula ocorrem, então ou a regra é válida, e a solução que dela resulta deve ser aceita, ou não é válida, e não contribuirá em nada para a decisão".[50]

E, havendo choque entre as regras, o intérprete deveria se valer de critérios clássicos de solução de antinomias, a saber, critérios hierárquico, da especialidade e cronológico.

Por sua vez, **os princípios teriam uma dimensão inexistente nas regras, que é a questão do peso**. Assim, um princípio poderia interferir no outro, **devendo resolver-se o conflito fazendo a ponderação do peso de cada um**.

Mas lembre-se que na ponderação dos princípios, não há uma fórmula predeterminada que diga que o princípio X sempre valerá mais que o Y. Desse modo, no recorrente confronto entre a liberdade de expressão e a intimidade/privacidade, cada um pode preponderar a depender da situação concreta.

Como consequência, não haveria uma mensuração exata, devendo ser aferida a importância de cada um dos princípios naquela situação. Para Dworkin, os princípios captariam os valores morais de determinada comunidade e os tornariam elementos próprios do discurso jurídico. A sua aplicação muitas vezes seria útil na solução dos casos difíceis (hard cases), servindo como base de sustentação argumentativa para a fundamentação.

Já as diretrizes políticas indicadas por Dworkin veiculam normas de objetivos a serem alcançados, a partir da promoção de melhorias econômicas, políticas ou sociais. Marcelo Novelino cita como exemplo a busca por erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, constante no artigo 3º da Constituição brasileira.[51] Ele ainda destaca que o próprio Dworkin reconhece a fragilidade da diferenciação entre as diretrizes políticas e os princípios interpretados como normas enunciadoras de objetivos sociais.

Avançando para a conceituação feita por **Robert Alexy**, haveria uma **diferença qualitativa entre princípios e as regras**, não havendo ele eles somente uma variação de grau. Em sua ótica, os princípios seriam "normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes". Por isso, eles se apresentariam como **mandados de otimização**.[52]

Ainda segundo Alexy, deveriam ser considerados dois aspectos centrais, a saber, a possibilidade de satisfação em variados graus e a medida dessa satisfação dependeria não apenas de possibilidades fáticas, mas também de possibilidades jurídicas. Estas, por sua vez, seriam determinadas por outros princípios ou por regras opostas, servindo de ponto de partida para as decisões.

---

[50] DWORKIN, Ronald. *Talking rights seriouly.* Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1978. p. 24.

[51] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 120.

[52] ALEXY, Robert. *Teoria de los derechos fundaementales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. p. 81.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O jurista alemão acrescenta que os princípios devem ser aplicados e satisfeitos no mais intenso grau que for possível, ao passo que as regras determinariam algo. Em suas palavras, "sendo uma regra é válida, então há de se fazer exatamente o que ela exige, sem mais ou menos".[53] Isso porque a regra se apresenta como um mandamento definitivo.

Havendo a colisão de princípios e de regras, a solução se daria de modo distinto: colidindo duas regras, uma delas deve ser tomada como cláusula de exceção da outra ou é declarado que uma delas não é válida. Usando o seu exemplo, a regra que fala que os alunos só podem sair da sala de aula ao final do horário pode ser excepcionada pela que diz que, ouvido o sinal de incêndio, todos deveriam deixar imediatamente o local.

Já na colisão entre princípios deveria ser apurado o peso, fazendo-se a ponderação para descobrir naquela situação concreta qual teria prevalência sobre o outro. Por óbvio, como a análise é feita caso a caso, noutra situação o princípio que cedeu espaço na situação anterior pode vir a prevalecer.

Fique atento(a) a um ponto: embora haja pontos de interseção, os pensamentos de Dworkin e de Alexy não se confundem.

Virgílio Afonso da Silva expõe a distinção, dizendo que "não só **as teses de ambos os autores não são idênticas – a própria ideia de otimização não está presente nas obras de Dworkin –, como também a possibilidade de única resposta correta é rejeitada expressamente pela teoria dos princípios na forma defendida por Alexy**.[54]

É, meu(minha) amigo(a) concurseiro(a), mas como tudo pode piorar, já há doutrinadores que defendem que a aplicação do esquema do "tudo ou nada", surgido para as regras, também poderia ser encaixada no choque entre princípios. E mais: as regras também poderiam passar por juízo de ponderação. Durma com um barulho desses...

1.7.2. SUPERABILIDADE OU DERROTABILIDADE DAS REGRAS

Um alerta inicial: nas provas, você pode encontrar os termos superabilidade (usado, por exemplo, por Humberto Ávila), derrotabilidade (mencionado por outros grandes autores), ou ainda *defenseability*, que é a derrotabilidade em inglês.

Já que falei em Humberto Ávila, ele diz que **as regras devem ser obedecidas não somente por existirem e terem sido editadas por uma autoridade competente**. Ao contrário, elas devem ser obedecidas, de um lado, porque **sua obediência é boa e**, de outro lado, porque ela **produz efeitos relativos a valores prestigiados pelo próprio ordenamento jurídico, como segurança, paz e igualdade**. Ele acrescente que, ao contrário do que a atual exaltação dos princípios possa fazer pensar, as regras não são normas de segunda

[53] ALEXY, Robert. *Teoria de los derechos fundaementales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. p. 87.

[54] SILVA, Virgílio Afonso. *A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 121.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

categoria, desempenhando uma função de grande importância. As regras têm características importantes como previsibilidade, eficiência e solução equânime dos conflitos sociais.[55]

Sei que nossa ideia aqui é fazer você passar na prova e ser chamado o quanto antes.

Pensando nisso, resolvi colocar aqui a explicação feita por Marcelo Novelino, por entender que ela resume bem o tema e será útil para você se sair bem nos mais variados níveis de prova.

Ele fala o seguinte: "nos conflitos com princípios, o afastamento de regras somente deve ocorrer nos casos de inconstitucionalidade, de manifesta injustiça ou em situações excepcionalíssimas que, por escaparem da normalidade, não poderiam ter sido ordinariamente previstas pelo legislador. **A não aplicação das regras válidas ante as circunstâncias específicas do caso concreto é conhecida como derrotabilidade (ou superabilidade)**".[56]

Desse modo, o princípio há de ter tamanho peso (força) que justificará nós relativizarmos outro princípio, o da segurança jurídica, para superar (derrotar) uma regra escrita. Novelino acrescenta que a ponderação seria feita não entre uma regra e um princípio, mas entre princípios que fornecem razões favoráveis e contrárias à aplicação da regra naquele cargo específico.

1.7.3. PANPRINCIPIOLOGISMO

O professor Lênio Streck, com a precisão que lhe é peculiar, indica que o **panprincipiologismo** é um fenômeno que vem tomando conta do direito.[57]

Ele cita a existência de uma usina de produção de princípios sem normatividade, exemplificando com os princípios "da cooperação processual", da "proibição do atalhamento constitucional", do "deduzido e do dedutível", da "proibição do desvio de poder constituinte", da "parcelaridade", da "verticalização das coligações partidárias", "da felicidade", entre outros.

É certo que o modelo constitucional por nós adotado é classificado, quanto aos sistemas, como uma Constituição principiológica, em detrimento do modelo preceitual, vigente no México.

Assim, a existência de um grande leque de princípios é natural, mas não a sua vulgarização. É aí que reside a crítica do doutrinador. Em sua obra *Verdade e Consenso*, é feito um apanhado com mais de quarenta princípios. Segundo ele, esses princípios são construídos de forma voluntarista por juristas descomprometidos, em sua maioria, com a deontologia do direito.

---

[55] ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos*. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 112-114.

[56] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. edição. Salvador: JusPodivm, 2017, pág. 129.

[57] STRECK, Lênio Luiz. *O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto.* Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2012-mar-22/senso-incomum-pan-principiologismo-sorriso-lagarto>.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.8. PODER CONSTITUINTE

Os estudos relativos ao Poder Constituinte surgem a partir do **abade** Emmanuel Joseph **Sieyès**. Ele escreveu uma obra clássica, intitulada "O que é o terceiro Estado?" (*Qu'est-ce que Le tiers État?*), na qual apontava que **o titular do poder constituinte é a nação**. No entanto, Pedro Lenza adverte que a doutrina moderna indica **o povo como titular do poder constituinte**.[58]

Aliás, não é por outra razão que o artigo 1º da Constituição de 1988 fala que **todo Poder emana do povo**. Usando também o artigo 1º, é importante distinguir **titularidade x exercício do poder**.

Com efeito, seguindo a concepção moderna, tem-se que o titular do poder é o povo, mas normalmente ele (o poder) é exercido por meio dos representantes eleitos (democracia representativa). Em situações excepcionais, a Constituição prevê ferramentas de exercício direto do poder pelo povo, quais sejam, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei.

Somando as duas formas de exercício do poder, tem-se no Brasil a chamada democracia mista ou semidireta.

Voltando, o Poder Constituinte pode ser conceituado como o **poder de elaborar ou atualizar uma Constituição**, mediante a supressão, modificação ou acréscimo de normas constitucionais.

Costuma-se dividir o poder constituinte em originário e derivado. Para parte da doutrina, há também o chamado **poder constituinte difuso e o supranacional**.

Vamos trabalhar com cada um deles.

Antes, porém, eu queria comentar com você o conceito de **Hiato Constitucional**, desenvolvido por Ivo Dantas.[59]

Segundo o autor, o hiato constitucional aconteceria diante de um **divórcio entre o conteúdo da Constituição Política e a realidade social**. Em outras palavras, **o que está posto na Magna Carta não condiz com a realidade dos fatos**. Isso geraria uma interrupção dos processos e de fluxos constitucionais. O hiato se situa **entre a ruptura constitucional e a reconstitucionalização**.

Podemos verificar o hiato constitucional diante das **(i)** mutações constitucionais (vistas a seguir, significando a mudança na interpretação da norma sem alteração de texto); **(ii)** reforma constitucional, viabilizada por emendas à Constituição; **(iii)** reformulação democrática, por meio de processo democrático, mediante Assembleia Nacional Constituinte; e **(iv)** implantação de hiato autoritário, como tivemos no AI-5.

Avançando, Bernardo Gonçalves Fernandes[60] cita a existência de **três agrupamentos** (**ou momentos**) **teóricos** relacionados à abordagem dogmático-constitucional incidente sobre o Poder Constituinte.

---

[58] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 205.

[59] DANTAS, Ivo. *Constituição Federal Teoria e Prática*. Minas Gerais: Renovar, 1996. p. 18.

[60] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. 10. ed. *Curso de direito constitucional*. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 119 e seguintes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Versão clássica: oriunda dos pensadores Duguit, Burdeau, Carré de Malberg e Esmein. Nela, o poder constituinte seria **o poder de fato, não jurídico**, responsável pela criação de uma nova ordem jurídica por meio de novo texto constitucional. A titularidade seria da nação, dado o compartilhamento de elementos como língua, tradições, religião etc. É um poder **ilimitado e incondicionado**.

b) Versão moderna: nascida a partir do século XX e responsável por **transferir a titularidade do poder constituinte da nação para o povo**. Há preocupação em diferenciar procedimentos democráticos dos não democráticos. Incorpora elementos de democracia direta, como plebiscito e referendo.

c) Leitura contemporânea: realizada a partir dos pressupostos teóricos trazidos por **Jünger Habermas** em sua teoria discursiva do direito e da democracia. Bernardo Gonçalves Fernandes elenca o trabalho dos juristas Marcelo Cattoni e Álvaro Cruz, ligando a noção de poder constituinte ao Patriotismo Constitucional.

Aliás, o conceito de **Patriotismo Constitucional** está ligado ao abandono do nacionalismo arcaico (carregado de xenofobia), passando a desenvolver o **reconhecimento inclusivo**, de união entre cidadãos, mesmo que sejam diferentes étnica e culturalmente.

Bernardo pontua que nas sociedades plurais a identidade coletiva está mais ligada à convivência sob os mesmos valores do Estado democrático de direito e menos a questões como homogeneidade cultural.

Outro grande estudioso do tema, Álvaro Ricardo de Souza Cruz defende que o **sistema de direitos** decorrente do patriotismo constitucional garantiria as autonomias pública e privada dos cidadãos, abarcando uma cultura política pluralista.[61]

1.8.1. PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO (PCO)

Também é chamado de **inicial, inaugural, de primeiro grau, genuíno ou primário**. Ele seria o poder de **criar uma Constituição**, quando o Estado é novo (poder constituinte originário **histórico ou fundacional**), ou quando uma Constituição é **substituída por outra**, em um Estado já existente (poder constituinte **revolucionário**).

Olhando para a realidade brasileira, a Constituição de **1824** se encaixa como PCO **histórico**, enquanto todas as demais, inclusive a **1988**, seriam PCO **revolucionário**.

Daí você me pergunta:

Qual revolução que houve em 1988?

Explico. Quando se fala em revolução, não é um conflito armado, uma guerra, embora isso às vezes isso realmente aconteça.

[61] SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo de. Poder Constituinte e patriotismo constitucional. *In*: GALUPP, Marcelo Campos. *O Brasil que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito.* Belo Horizonte: PUC Minas, 2006. p. 90.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A revolução é que a norma de maior envergadura foi modificada, o que vai gerar uma grande transformação no esquema normativo daquele país. Afinal, nova "Pirâmide de Kelsen" nasce, sendo que as normas posteriores deverão passar por controle de constitucionalidade, enquanto as anteriores se submeterão a juízo de recepção/revogação.

Ou seja, todo o panorama jurídico é revisto. Daí se falar em poder revolucionário. A importância direta disso nas provas? Aí vai um exemplo: **não existe direito adquirido perante uma nova Constituição**. Isso porque uma das características, a seguir apresentadas é que o PCO é ilimitado juridicamente.

Há também a divisão entre PCO material e formal. Veja:

Poder Constituinte Originário Material	Poder Constituinte Originário Formal
É o próprio movimento que rompe com a ordem política, fazendo nascer a nova Constituição.	É a forma que se apresenta essa força revolucionária. Nas Constituições promulgadas, seria a Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo.

Talvez em suas provas (objetiva, subjetiva ou até mesmo a oral) você se depare com o **questionamento se a Constituição de 1988 seria mesmo manifestação do PCO**.

Isso se deve ao fato de a convocação da Assembleia Nacional Constituinte ter acontecido por meio da **EC n. 26/1985**, proposta pelo então Presidente José Sarney. Ele havia elaborado um anteprojeto a partir dos trabalhos da chamada **Comissão Afonso Arinos**, composta por grandes personalidades da época. Porém, esse anteprojeto não chegou a ser apresentado ao Congresso, ante a manifestação de contrariedade de Ulysses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte.

Outra objeção colocada seria o fato de o trabalho ter sido feito por **parlamentares não eleitos exclusivamente** para elaborar a nova Constituição. Tem mais: o poder constituído poderia convocar a manifestação do poder constituinte?

Seja como for, **esse entendimento é minoritário**. Quando o assunto foi discutido no STF, o ministro Gilmar Mendes pontuou que o Congresso Nacional de 1985 atuou como um poder constituinte especial, pois colocou no mesmo texto a convocação da constituinte e suas condições de realização. Seria, pois, um peculiar ato constitucional, não tendo natureza própria de emenda constitucional. Ao contrário, deveria ser considerado um ato político que rompeu com a Constituição anterior, dela não fazendo parte, material ou formalmente (STF, ADPF n. 153).

Assim, para as provas **prevalece a orientação de que a Constituição de 1988 é fruto legítimo e autêntico do poder constituinte originário**, rompendo com a ordem constitucional anterior, fruto do regime militar.

Avançando, o PCO não é temporário e não se esgota quando a nova Constituição é redigida. Ao contrário, ele é um **poder latente e permanente**. Talvez fique mais fácil encaixar esses conceitos quando você lembrar a frase "o gigante acordou". É que o gigante é o povo, que estava adormecido (latente).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O grande problema é que o PCO é perigoso... como você viu, ele não respeita direito adquirido, cláusulas pétreas. Dentro do cenário de violência em que vivemos atualmente, se for feita uma nova Constituição não é nada difícil que movimentos mais rigorosos acabem emplacando a pena de morte em casos mais amplos, a prisão perpétua, a drástica redução da maioridade penal, uma redução significativa de direitos e garantias etc.

Segundo Gilmar Mendes e Paulo Branco, o PCO "está apto para se manifestar a qualquer momento".[62]

Podem ser enumeradas as seguintes **características**:

- **inicial**: instaura uma **nova** ordem jurídica, rompendo com a ordem jurídica anterior;
- **autônomo**: a estruturação da nova Constituição será determinada autonomamente, por quem exercer o poder constituinte originário;
- **incondicionado e soberano**: não tem de se submeter a qualquer forma prefixada de manifestação;
- **ilimitado juridicamente**: ele não tem de respeitar os limites postos na Constituição anterior. É exatamente daí que vem a afirmação segundo a qual **não se pode invocar direito adquirido à época da Constituição anterior perante o novo texto constitucional**.

O pensamento de Sieyès, ao indicar o caráter ilimitado, se justificava na tentativa de se contrapor ao Estado absolutista, o qual conferia amplos poderes aos governantes. Era necessário contrapor-se à teoria do poder divino e ao direito divino dos governantes.

Contudo, é importante lembrar que principalmente para a corrente **jusnaturalista** – que se contrapõe ao juspositivismo –, **o PCO encontraria limites de ordem cultural, social, espiritual, ética** etc.

Sieyès também entendia pela necessidade de se respeitar o direito natural, na medida em que ele é anterior ao Estado e ao próprio poder e, portanto, está acima de tudo.

Embora você tenha visto o caráter ilimitado sob o ponto de vista jurídico, a Doutrina mais moderna vem apontando para a necessidade de respeitar as conquistas sociais e políticas daquela Nação, proibindo-se que haja um grande retrocesso social (efeito cliquet).

Jorge Miranda – o mesmo doutrinador português que cita a possibilidade de inconstitucionalidade de normas originárias – aponta três tipos de limites ao PCO. Veja:

- **Limites Transcendentes**: aqui, começo com uma provocação: procure na Constituição de 1988 a menção a samba, carnaval ou futebol. Você certamente não encontrará. Então, será que uma nova manifestação do PCO poderia acabar com esses valores em nosso país? Segundo a doutrina, não, na medida em que eles pertencem à própria essência de nossa sociedade. Assim, os limites transcendentes constituiriam valores éticos superiores (ex.: proibição de preconceito religioso) e valores integrantes da consciência coletiva.

[62] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 200.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Limites Imanentes**: seriam elementos integrantes do próprio conceito de Estado. Não poderia o constituinte originário desmembrar o país para formar outro ou mesmo acabar com o país.
- **Limites Heterônomos**: por fim, haveria limites heterônomos, traçados na órbita internacional. Eles seriam aplicáveis apenas a países integrantes de comunidades internacionais, como a União Europeia.

1.8.1.1. GRAUS DE RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL: MÍNIMO, MÉDIO OU MÁXIMO

Quando a Constituição entra em vigor, deve ser buscado saber como ficarão os fatos anteriores a ela. É aí que surge a discussão sobre graus de retroatividade máximo, médio ou mínimo.

De antemão, destaco que **o STF entende que as normas constitucionais fruto da manifestação do PCO têm**, em regra, a chamada **retroatividade mínima**. Isso significa dizer que **elas serão aplicadas a fatos que venham a ocorrer após a sua promulgação, mesmo que relativos a negócios firmados no passado**.

Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco,

> a não ser quando diz o contrário, tem aplicação sobre situações constituídas antes da sua vigência, exatamente sobre os efeitos que o ato praticado no passado tenderia a produzir sob a vigência da nova norma constitucional.[63]

Contudo, é importante lembrar que as normas editadas pelo Constituinte Originário poderão fugir à regra que vimos aí em cima, possuindo eficácia retroativa média (alcançando prestações vencidas anteriormente a essas normas e não pagas) ou retroatividade máxima (atingindo fatos consumados no passado). Ah, mas para operar retroatividade diferente da mínima deveria haver previsão expressa do próprio PCO.

Agora fique atento a um ponto: você lembra que o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição assegura o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada?

Pois é, então, vou sistematizar as informações:

- **não** existe a invocação de direito adquirido **frente ao PCO**;
- o legislador ordinário e o PCD (reformador, revisor e decorrente) precisam respeitar o direito adquirido.

Repito: **em regra**, **as normas constitucionais têm retroatividade mínima**.

Veja agora a sistematização que preparei para você:

[63] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 116.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Graus de retroatividade da norma constitucional		
Mínimo	**Médio**	**Máximo**
Normas serão aplicadas a fatos que venham a ocorrer após a sua promulgação, mesmo que relativos a negócios firmados no passado.	Normas alcançam prestações vencidas anteriormente a essas normas e não pagas.	Normas atingem fatos consumados no passado.
Observação: só com manifestação expressa do PCO as normas terão retroatividade média ou máxima.		

1.8.2. PODER CONSTITUINTE DERIVADO (PCD)

Parte da doutrina entende que a expressão Poder Constituinte deveria ser usada apenas para o Originário.

Dentro dessa premissa, tendo em vista que o Poder Constituinte Derivado é criado pelo Originário, mais correto seria chamá-lo de Poder Constituído (criatura), deixando a expressão Constituinte para o criador.

Seja como for, nas provas aparecem as duas expressões (Constituinte Derivado e Constituído), devendo você ficar atento para o fato de serem sinônimas. Aliás, ainda pode aparecer em sua prova Poder Instituído, Secundário, de 2º Grau ou Remanescente.

Sua característica principal é ser criado pelo Poder Constituinte Originário. Ao contrário do Originário, que é ilimitado (juridicamente), incondicionado, autônomo e inicial, o Poder Constituinte Derivado obedece a certos **limites** impostos pelo PCO. Por essa razão, é correto dizer que **o PCD é limitado e condicionado**.

O constituinte derivado se subdivide em três: **decorrente, revisor** e **reformador**. Confira:

Reformador	Revisor	Decorrente
EC	**ECR**	**CE/LODF**
Emendas à Constituição. Previstas no artigo 60 da CF. Ainda podem ser promulgadas.	**Emendas Constitucionais de Revisão**. Eram previstas no artigo 3º do ADCT. Não podem mais ser feitas.	São as **Constituições Estaduais e a LODF. Lei orgânica municipal fica de fora**.

Vou falar um pouco sobre cada um deles, **lembrando que principalmente o decorrente e o reformador são os queridinhos nas bancas examinadoras**.

1.8.2.1. PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE

É a possibilidade que os **Estados-membros** têm, em virtude de sua autonomia político-administrativa, de se auto-organizarem por meio de suas respectivas **Constituições Estaduais**, sempre **respeitando os princípios** colocados na Constituição (art. 25).

Quais seriam os princípios que os Estados deveriam respeitar na elaboração de suas constituições?

De acordo com Uadi Lammêgo Bulos[64], seriam três espécies de princípios:

[64] BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 506-509.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a) Princípios constitucionais sensíveis

São aqueles previstos no artigo 34, inciso VII, da Constituição. Eles recebem esse nome, porque, se forem violados, autorizam a decretação de intervenção federal.

Ela – a intervenção – é uma medida extrema dentro de uma Federação, forma de Estado que tem por premissa a autonomia dos entes que a compõem. A intervenção acaba vulnerando a autonomia.

b) Princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios)

Para o citado autor, "são aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do Poder Constituinte Decorrente. Por isso mesmo, funcionam como balizas reguladoras da capacidade de auto-organização dos Estados". Eles se subdividem em:

I – limites explícitos vedatórios ou mandatórios: proíbem os estados de praticar atos ou procedimentos contrários aos fixados pelo Constituinte Originário (Ex.: artigo 19), **ou impõem restrições** à liberdade de organização.

EXEMPLO

Art. 18, § 4º.

II – Limites inerentes: implícitos ou tácitos, vedariam qualquer possibilidade de invasão de competência por parte dos estados-membros.

III – Limites decorrentes: assim chamados por decorrerem das disposições expressas.

EXEMPLO

Necessidade de se respeitar a dignidade da pessoa humana, o princípio republicano e o da legalidade.

Alertamos os estudantes que, para o STF, a norma prevista no art. 57, § 4º, da Constituição, que trata da proibição de recondução dos parlamentares para as Mesas das Casas Legislativas (Câmara, Senado e Congresso) **não** é norma de repetição obrigatória, pois não se enquadra entre os princípios constitucionais estabelecidos.

Em consequência, pode a Constituição Estadual autorizar a reeleição para cargos na Mesa diretora mesmo dentro da mesma legislatura (STF, ADI 793).

Você viu aí uma norma que não é de repetição obrigatória, certo?

Então, vamos para outra em sentido inverso. É o seguinte: o artigo 50, § 2º, da CF, prevê que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a **Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República**. Consta, ainda, que a recusa ou o não atendimento importará em crime de responsabilidade.

Pois é, mas a Constituição do estado de São Paulo estendia essa exigência de prestar informações **também ao Procurador-Geral de Justiça (PGJ)**, chefe do Ministério Público.

Ao julgar o caso, o STF entendeu ser **incompatível** com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do Legislativo local **e o rol de**

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

autoridades submetidas à solicitação de informações. Confirmou-se, assim, que o artigo 50 da CF seria uma norma de repetição obrigatória, sem a possibilidade de ampliação na esfera estadual (STF, ADI n. 5.289).

c) Princípios constitucionais extensíveis

Ainda segundo o autor,

> são aqueles que integram a estrutura da federação brasileira, relacionando-se, por exemplo, com a forma de investidura em cargos eletivos (artigo 77), o processo legislativo (arts. 59 e ss), os orçamentos (arts. 165 e ss), os preceitos ligados à Administração Pública (arts. 37 e ss).

Existe Poder Constituinte Derivado Decorrente nos Municípios e no DF?

É certo que o **poder constituinte derivado decorrente não foi estendido aos Municípios** (politicamente organizados por lei orgânica). Isso porque a lei orgânica do município se submete a um **duplo grau de imposição legislativa**, devendo ser compatível com a Constituição Federal e com a Estadual.

Eles estariam, além disso, no terceiro grau de Federação – o primeiro é formado pela União e o segundo pelos Estados e pelo DF.

Nos dizeres da Professora Noêmia Porto,

> o poder constituinte derivado decorrente deve ser de segundo grau, tal como acontece com o poder revisor e poder reformador, isto é, encontrar sua fonte de legitimidade direta da Constituição Federal. No caso dos **Municípios**, porém, se descortina um **poder de terceiro grau**, porque mantém relação de subordinação com o poder constituinte estadual e o federal.[65]

Não é por outra razão que o confronto entre uma lei municipal x lei orgânica municipal é chamado de **controle de legalidade**, e **não** de constitucionalidade.

Vou tratar agora do Distrito Federal. É certo que ele também é regido por lei orgânica, assim como acontece com os Municípios.

No entanto, nos dizeres do STF, "o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios (STF, ADI 3.756).

A doutrina fala que ela seria uma verdadeira "Constituição distrital".

Acrescento, ainda, que o confronto entre uma lei distrital x lei orgânica distrital configura inegável **controle de constitucionalidade**.

Aliás, o TJDFT pode realizar o controle de constitucionalidade tanto na via difusa quanto na concentrada, funcionando como o Guardião da LODF.

Mais: o Governador do DF e a Mesa da CLDF figuram entre os legitimados para a propositura das ferramentas do controle concentrado (ADI, ADO, ADC e ADPF) perante o STF.

---

[65] PORTO, Noêmia. T*emas relevantes de direito constitucional: poder constituinte*. Brasília: Fortium, 2005. p. 55-56.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Enfim, há um leque de argumentos para entender a LODF como materialização do poder constituinte derivado decorrente.

E esse cenário não se modifica mesmo diante do fato de a autonomia do DF ser parcialmente tutelada pela União – é da União a tarefa de organizar e manter o TJDFT, o MPDFT, a PCDF, a PMDF e o CBMDF.

Na doutrina, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior[66] dizem que pelo **critério funcional** a Lei Orgânica do Distrito Federal teria a mesma função das **Constituições Estaduais**, consubstanciando expressão do Poder Constituinte Derivado Decorrente.

Em resumo, você pode levar a informação de que **o DF e os estados possuem poder constituinte derivado decorrente. Tal poder, entretanto, não foi estendido aos municípios**.

Sistematizando para facilitar sua compreensão:

Princípios a serem observados por Constituições Estaduais		
Sensíveis	**Estabelecidos** (organizatórios)	**Extensíveis**
Previstos no artigo 34, VII. Sua violação autoriza a intervenção federal. Ex.: forma republicana de governo.	Limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do Poder Constituinte Decorrente. Ex.: artigo 18, § 4º (fixa regras para formação de novos municípios).	Normas que devem ser repetidas pelo Constituinte Estadual. Ex.: artigo 37 (princípios da Administração).

1.8.2.2. PODER CONSTITUINTE DERIVADO REVISOR (ECR)

O PCD Revisor só existe hoje para cair em prova... é que ele não pode mais ser colocado em prática, estando com sua **eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada**. **Vamos lá, então, pois o nosso negócio é fazer prova!**

O art. 3º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) determinou que, **após pelo menos cinco anos** da promulgação da Constituição, fosse feita uma **revisão** no texto constitucional.

A primeira coisa que você tem que observar é que as emendas constitucionais de Revisão (**ECR**) só poderiam ser feitas em uma oportunidade, que já se esgotou – por isso se fala em eficácia exaurida.

Além disso, há certo consenso de que os Parlamentares "queimaram o cartucho" antes da hora, pois a Constituição previa o procedimento após **pelo menos cinco anos**. Ou seja, poderiam ter promulgado as ECR após seis, sete, oito anos...

Muitos doutrinadores dizem que o PCD Revisor tinha sua razão de ser no Plebiscito realizado em **21/4/1993**, quando a população foi chamada para decidir se queria alterar a forma (República x Monarquia) e o sistema de governo (Presidencialismo x Parlamentarismo).

[66] ARAÚJO, Luiz Alberto Davi; NUNES JR., Vidal Serrano. *Direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 13-14.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A razão para essa associação é simples: **tivesse ocorrido alguma das mudanças propostas, seria necessária uma significativa revisão da Constituição**. Não é à toa que **o PCD Revisor recebe o nome "recall constitucional"**.

Avançando, essa revisão seria feita em **sessão unicameral** (é **diferente** de sessão **conjunta**), pelo voto de **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional e teria por objeto atualizar e adequar a CF/1988 à realidade da época.

ATENÇÃO

Para se fazer as emendas de revisão (**ECR**), o **rito** era bem **mais simples** do que as emendas à Constituição (EC): só bastava uma votação em sessão unicameral e o quórum de aprovação era de maioria absoluta.

Ah, sobre as ECR também incidiam as limitações materiais (cláusulas pétreas). Além disso, o próprio STF deixou claro que a janela aberta já se fechou e que as ECR não podem mais ser promulgadas, bem como as que foram editadas – **seis**, todas em 1994 – estão sujeitas a controle judicial (STF, ADI n. 981).

1.8.2.3. PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR (EC)

As ECs são alterações feitas pelo **Poder Constituinte Derivado Reformador** ao trabalho feito pelo Poder Constituinte Originário. Elas podem fazer acréscimos, supressões ou modificações do texto constitucional.

Como todas as espécies do PCD (Decorrente, Revisor e Refomador), elas apresentam algumas **limitações**, fixadas pelo Poder Constituinte Originário.

As limitações, por sua vez, **se desdobram em explícitas** (limitações procedimentais, materiais e circunstanciais), previstas no art. 60 da Constituição, **e implícitas**, extraídas da orientação doutrinária e jurisprudencial.

Vamos falar sobre elas?

1.8.2.3.1. LIMITAÇÕES AO PODER DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

É certo que **o Poder Constituinte Originário é ilimitado juridicamente.** Já o Constituinte Derivado, como eu disse algumas linhas atrás, sofre limitações impostas pelo Originário.

a) Limitações circunstanciais

Em determinadas **circunstâncias**, relacionadas à instabilidade política, **não** poderá haver emenda à Constituição. São elas:

- intervenção federal;
- estado de defesa; e
- estado de sítio.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

b) Limitações procedimentais

Elas podem ser chamadas de limitações formais ou procedimentais. O certo é que para se aprovar uma EC, exige-se um processo muito mais rigoroso do que aquele necessário para a aprovação dos demais atos normativos.

Com efeito, a proposta precisa passar nas duas Casas do Congresso, sendo que em ambas ocorrerão dois turnos de votação, exigindo-se, em cada um deles, a aprovação de 3/5 dos membros – se o examinador colocar o percentual de 60% também está certo.

Fique atento(a), pois **o quórum de 3/5 deve ser respeitado pelas Constituições Estaduais**. Por conta disso, declarou-se a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam o quórum de 2/3 ou 4/5 para a modificação da Constituição daqueles Estados. Tal exigência acabaria engessando a CE (STF, ADI n. 486 e 6.453).

Outra coisa: o STF entende que **a Constituição não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação** para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 60, § 2º). Assim, ficaria a cargo do Legislativo a definição do momento em que a matéria estaria 'madura' para nova votação (STF, ADI 4.425).

Se houver o descumprimento desse procedimento rigoroso, a EC sofrerá de **vício formal** de inconstitucionalidade.

Foi o que aconteceu com uma parte da EC 19/98, que introduziu a **Reforma Administrativa**.

Um dos pontos dessa EC, que alterava o artigo 39 da Constituição, permitindo à Administração Direta a contratação de servidores por outros regimes jurídicos que não o da Lei 8.112/90, foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado.

Na Casa Revisora, houve emenda substancial, o que obrigava o retorno da proposta para a Câmara, com o intuito de se chegar a um consenso. Acontece que nesse retorno, uma das votações na Câmara foi feita por meio de destaques julgados em quorum de maioria absoluta – inferior ao de maioria qualificada.

Não deu outra! A EC n. 19/1998, quanto ao artigo 39 da Constituição, teve sua eficácia suspensa pelo STF (STF, ADI-MC 2.135).

Outra coisa: a proposta de emenda rejeitada em uma sessão legislativa não poderá ser reapresentada na mesma sessão, dentro da chamada **irrepetibilidade absoluta**.

Você vai se lembrar que ao comentar a deliberação parlamentar, diferenciei a irrepetibilidade relativa, incidente sobre a LO e a LC, da irrepetibilidade absoluta, aplicável às ECs e às MPs.

Naquela ocasião, chamei sua atenção para um ponto muito cobrado nas provas: **que a irrepetibilidade vale para a mesma sessão legislativa**, e **não para a mesma legislatura** (período de quatro anos).

Outra coisa: embora o assunto seja pra lá de controverso, a doutrina e a jurisprudência apontam para a possibilidade de se relativizar a irrepetibilidade absoluta.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Isso aconteceria dentro das emendas à Constituição, quando, apresentada a PEC, ela for objeto de alterações, passando a tramitar como substitutivo.

Nesse contexto, sendo votada a "PEC filha" (substitutivo), e havendo a sua rejeição, nada impediria a reapresentação, **na mesma sessão legislativa**, da "PEC mãe" (original).

O STF entende que o que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo que é uma subespécie do projeto originalmente proposto (STF, MS 22.503).

De todo modo, nunca se esqueça de uma coisa: **você deve prestar atenção ao comando da questão!** Se não houver o direcionamento para a situação excepcional que acabei de explicar, a resposta esperada é a regra. Ou seja, no sentido de **não** poder ser reapresentada na mesma sessão a PEC rejeitada naquela sessão legislativa.

c) Limitações materiais

Todo concurseiro já ouviu falar nas **cláusulas pétreas**! Pois bem, chegou a hora de tratamos delas, que estão previstas no artigo 60, § 4º, da Constituição – ao menos as explícitas.

Uma primeira, mas importante observação é no sentido de que **as cláusulas pétreas podem sofrer modificação**. Quer um exemplo?

O artigo 5º foi alterado pela EC 45/04, que **inseriu** três novos direitos ao seu já extenso rol: 1) princípio da razoável duração do processo; 2) adesão ao Tribunal Penal Internacional – TPI; e 3) equiparação dos tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em dois turnos, três quintos de votos em cada Casa do Congresso Nacional às ECs.

Seguindo, o que a Constituição não permite é que as cláusulas pétreas sejam abolidas, retiradas. Mais do que isso: **se proíbe que as matérias sejam objeto de deliberação**.

Sabe o que isso significa?

É que nós podemos '**cortar o mal pela raiz**', **barrando a própria tramitação da EC que venha a violar uma cláusula pétrea**. Para isso, **abre-se a excepcional possibilidade de controle preventivo jurisdicional de constitucionalidade**, viabilizado apenas e **tão-somente aos parlamentares**, por meio de **mandado de segurança a ser impetrado no STF** (STF, MS 32.033).

Professor, mas o MS não é o remédio utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por HC ou HD?

Isso mesmo. Nesse caso, **os parlamentares possuiriam o direito líquido e certo ao devido processo legislativo**.

Está bem, mas eu falei demais e ainda não mostrei a você quais são as tais cláusulas pétreas, né?! Então, vamos lá: **não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir:**

I – a forma federativa de Estado;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Não se permite o direito de secessão (separação), pois a característica central de uma Federação é a **união indissolúvel** de seus membros.

Aliás, ideias separatistas autorizam o uso da intervenção federal, por violar um dos princípios sensíveis de nossa Constituição – artigo 34, VII.

Ainda dentro do tema, **alguns Estados questionaram a lei federal que fixou o piso nacional** para profissionais da educação. Em outras palavras, uma lei editada pela União estabeleceu o valor mínimo que os Estados, o DF e os Municípios deveriam pagar aos seus professores.

Ao julgar o caso, o STF entendeu que **não haveria ofensa à forma federativa de Estado** (STF, ADI 4.167).

II – o voto direto, secreto, universal e periódico;

A primeira coisa a pontuar é que **a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea**. Para que o voto passe a ser facultativo, bastaria a promulgação de EC nesse sentido.

Seguindo, foi com base no voto secreto que se **declarou a inconstitucionalidade de lei federal a qual previa a utilização de impressoras junto às urnas eletrônicas**.

A ideia da lei era permitir um maior controle sobre a segurança das urnas, diante dos questionamentos acerca de possíveis fraudes. Previa-se que, por amostragem, o resultado de algumas urnas eletrônicas seria confrontado com os votos impressos, depositados num coletor junto à própria impressora.

Contudo, prevaleceu a ideia segundo a qual o voto impresso acabava permitindo a possibilidade de acesso humano aos votos já depositados nas urnas, sob o pretexto, por exemplo, de corrigir algum defeito na impressora (STF, ADI 4.543).

Ah, fique atento, pois o **voto secreto** é assegurado nas **eleições diretas**. **Nas eleições indiretas, poderia o voto ser aberto**. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Estado de Tocantins, que teve de realizar eleições indiretas, sendo a escolha do novo Governador e do Vice a cargo da Assembleia Legislativa (STF, ADI 4.298).

III – a separação dos Poderes;

Esta é a cláusula pétrea campeã nas provas de concursos! Em vários julgados, o STF afirma a violação ao princípio da separação de Poderes. Vou passar tudo o que você precisa saber sobre o tema, ok?

A CF/1988, em seu art. 2º, diz que os poderes são **independentes e harmônicos**. Isso quer dizer que 'um não é maior que o outro', ou seja, cada um pode controlar (frear) a atuação do outro.

EXEMPLO

O presidente da República encaminha um projeto de lei prevendo a criação de novo tributo. O Congresso Nacional (Legislativo) pode aprovar a proposta, criando a lei, ou rejeitá-la, arquivando. Havendo a sanção, promulgação e publicação, nada impede que o Judiciário a declare inconstitucional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Outro exemplo clássico em provas é o processo de escolha de Ministros do STF (Judiciário). O presidente da República (Executivo) indica um nome, que deve ser submetido à aprovação por maioria absoluta dos Senadores (Legislativo).

Esse sistema em que cada poder fiscaliza a atuação do outro é a chamada **teoria dos freios e contrapesos** (no direito norte-americano, é chamado *check and balances* ou *checks and counterchecks*).

Ah, mas fique atento a um ponto: não há violação à separação dos Poderes quando o Judiciário impõe à administração pública (Executivo) obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Ou seja, mesmo sendo o Executivo o gestor dos recursos para o sistema prisional, pode o Judiciário determinar a realização de obras emergenciais nos presídios (STF RE n. 592.581).

Ainda relacionado ao caos do sistema carcerário, foi determinado que não poderia haver o contingenciamento (bloqueio) de verbas destinadas ao FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional), de modo a diminuir os problemas estruturais encontrados (STF, ADPF n. 347).

Um ponto que desassossega o amigo concurseiro é o **posicionamento constitucional do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas**.

Nenhuma dessas instituições está em relação de subordinação aos Poderes acima citados.

O **Tribunal de Contas da União** atua como **auxiliar** do Congresso Nacional, mas mantém **independência** e ausência de subordinação hierárquica (STF, ADI 4.190).

Quanto ao **Ministério Público**, igualmente, fala-se em independência e inexistência de subordinação.

Mas, sem dúvidas, **o julgado do STF mais cobrado em provas de concursos quando se fala em separação dos poderes diz respeito à Defensoria Pública**. O caso envolvia um ato de Governador de Estado que, ao receber o orçamento encaminhado pela Defensoria local **dentro dos limites da LDO**, promoveu cortes. Além disso, ele ainda inseriu a instituição **dentro da estrutura da Secretaria de Justiça**, subordinada ao Executivo (STF, ADPF 307).

Analisando o que fez o Governador, o STF entendeu que **houve dupla violação à autonomia da Defensoria Pública**. O Tribunal ainda se posicionou no sentido de que a autonomia da Defensoria Pública seria um preceito fundamental de nossa Constituição.

Em resumo, podemos afirmar que a **Defensoria Pública**, o **Ministério Público** e o **Tribunal de Contas são dotados de autonomia administrativa, funcional e orçamentária**, não se subordinando ao Executivo ou a qualquer outro Poder.

Eu citei uma polêmica envolvendo a Defensoria Pública e o Executivo, certo? Porém, outra briga também muito grande envolveu o Judiciário – mais especificamente a Justiça do Trabalho e o Poder Legislativo.

Deixe-me explicar...

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Há alguns anos, o orçamento da Justiça do Trabalho, encaminhado no projeto de lei orçamentária, sofreu um grande corte nos valores ao chegar ao Legislativo.

Então, a ANAMATRA, que é a entidade de classe que representa os magistrados trabalhistas, foi ao STF alegando violação ao princípio da separação dos Poderes, porque o corte inviabilizaria o regular funcionamento do serviço.

No STF, o pedido não foi atendido, sendo a ação julgada improcedente. Ao final, ainda foi firmada a seguinte tese:

> **JURISPRUDÊNCIA**
> Salvo em situações graves e excepcionais, **não cabe ao Poder Judiciário**, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, **interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública**, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal (STF, ADI n. 5.468).

Como diria meu pai, "pau que dá em Chico também dá em Francisco..."

Em outro julgado, o STF disse que **não ofende** os princípios da separação e da harmonia entre os Poderes do Estado **a decisão que**, em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal, **determinou**, **sem prévia autorização** da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, **a coleta de dados telemáticos nas dependências dessa Casa Legislativa** (STF, AC n. 4.005).

Outra coisa: cuidado para não escorregar numa casca de banana... é que embora exista o Conselho **Nacional** de Justiça (CNJ), com representantes vindos de dentro e de fora do Judiciário, o STF firmou a compreensão segundo a qual **é inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário** do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades (STF, Súmula n. 649).

Ei, mas você está lembrando que a separação de Poderes é uma das cláusulas pétreas previstas lá no § 4º do artigo 60 da Constituição?

Aliás, quando o assunto é cláusula pétrea, essa é a campeã nas provas de concursos. Então, que tal vermos outros julgados bastante exigidos? Afinal, este material nasceu deliberadamente voltado para preparar você para resolver as questões dos mais variados graus de dificuldade.

Vamos lá?

Antes, porém, um alerta: na maioria das vezes, o defeito está no fato de se exigir a participação do Legislativo em um assunto que seria próprio aos outros Poderes. Veja:

1) viola a separação de Poderes lei estadual que condiciona todas as desapropriações feitas a prévia aprovação do Legislativo. O defeito aqui seria o fato de essa tarefa – desapropriar – caber ao Executivo (STF, ADI n. 106);

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

2) viola a separação de Poderes lei estadual que exija a sabatina de nomes de lista tríplice ao cargo de Procurador-Geral de Justiça (PGJ). A razão da inconstitucionalidade nesse caso consiste na ausência de previsão da sabatina na Constituição Federal. E, na escolha do PGJ, o Chefe do Executivo já fica restringido por conta da lista tríplice, elaborada pelo próprio MP (STF, ADI n. 3.888);

3) no mesmo sentido do item anterior, também seria inconstitucional norma estadual que previsse a aprovação, pela Assembleia Legislativa, dos integrantes da lista tríplice do quinto constitucional para preenchimento de vaga de Desembargador do TJ (STF, ADI n. 4.150);

4) viola a separação de Poderes lei estadual que preveja sabatina do Legislativo para os integrantes de Diretorias das entidades da Administração Indireta (empresas públicas e sociedades de economia mista). A exceção ficaria por conta das autarquias e das fundações públicas, pois, em relação a elas, a Constituição Federal prevê a aprovação do Senado. Assim, em simetria, a Constituição Estadual também poderia prever (STF, ADI n. 2.225);

5) viola a separação de Poderes **a convocação de Magistrado, por CPIs**, para prestar esclarecimentos sobre ato jurisdicional praticado. Como você sabe, contra decisão judicial cabe recurso, e não CPI (STF, HC n. 86.581).

IV – os direitos e garantias **individuais**.

Dentro da expressão "direitos e garantias **individuais**", segundo o STF, estariam os artigos **5º** (direitos e deveres individuais e coletivos); **16** (princípio da anterioridade eleitoral); e **150** (limitações ao poder de tributar).

Cuidado para uma pegadinha comum nas provas: trocar direitos e garantias **individuais** por **fundamentais**. ***Onde estaria o erro?***

Direitos e garantias **fundamentais** compreendem todo o Título II da Constituição – artigos 5º a 17. E, **não são cláusulas pétreas** os **direitos sociais**, de **nacionalidade** etc.

Foi com base nessa cláusula pétrea que se afirmou a **inconstitucionalidade** da EC n. 52/**2006** na parte em que permitia a aplicação da referida emenda às eleições daquele ano.

É que o teor da emenda alterava o processo eleitoral, devendo ser aplicado apenas às eleições que ocorressem um ano após a entrada em vigor da norma (STF, ADI 3.685).

Está bem! Você viu as cláusulas pétreas **explícitas**. Será que haveria outras, implícitas no texto constitucional?

A doutrina entende que **sim**!

Ilustrativamente, Gilmar Mendes e Paulo Gonet, no seu Curso de Direito Constitucional citam os **Princípios Fundamentais (artigos 1º a 4º) como cláusulas pétreas implícitas**. Isso faz bastante sentido, uma vez que eles abrem a Constituição, servindo como parâmetro para outros dispositivos do texto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Além das cláusulas pétreas previstas no texto da Constituição (artigo 60, § 4º), a doutrina entende haver outras implícitas, como é o caso dos Princípios Fundamentais.

d) Limitações implícitas

Ao lado das limitações circunstanciais, materiais e procedimentais, a doutrina lista também as limitações implícitas.

Entre elas estaria **impossibilidade** de **alteração** do **titular** do **poder constituinte**.

Além disso, **não** se **permitiria** a chamada **dupla revisão**, instituto constituído da seguinte forma: **num primeiro momento**, seriam extraídas as regras constitucionais nas quais constam as proibições.

A título de exemplo, seria revogada a norma prevista no art. 60, § 4º, I, 'e' – prevê a forma federativa de Estado; **num segundo momento**, outra emenda constitucional diria que o estado unitário seria adotado no Brasil.

Ou seja: seria uma forma de disfarçar a retirada de uma cláusula pétrea.

ATENÇÃO

O Brasil **não** admite o procedimento da dupla revisão em relação às emendas à Constituição.

e) Limitações temporais?

Não existem limitações temporais na Constituição atual sobre as ECs. Elas **já existiram**, na Constituição de 1824.

Aliás, **a Constituição de 1.824 era ao mesmo tempo imutável e semirrígida**.

Aragonê, como isso é possível?

É o seguinte: ela era **imutável** nos primeiros **quatro anos**.

Depois disso, poderia ser modificada, passando a ser **semirrígida**. Isso porque para alterar matérias realmente constitucionais se exigia procedimento mais rigoroso.

Já quanto os conteúdos que, embora estivessem no texto constitucional, não contivessem matéria realmente constitucional, a alteração seria pelo mesmo procedimento aplicável às leis.

Pronto! Agora que já falamos sobre os limites traçados pelo PCO ao PCD Reformador, é bom lembrar que **uma emenda à Constituição pode ser declarada inconstitucional caso ela contrarie a Constituição**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

De outro lado, **uma norma originária**, ou seja, aquela editada pelo PCO, **jamais será inconstitucional**, mesmo diante de (aparente) choque com outra norma também originária. Nessa hipótese, a solução passará pela **ponderação de interesses**, a ser feita caso a caso.

Posso resumir para você o essencial sobre as limitações ao Poder de Emenda?

Limitações ao Poder de emendar a Constituição	
Limitação	**Comentários**
Circunstancial	Não pode haver EC na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Formal	É necessária aprovação em dois turnos, por 3/5 de votos, em cada Casa do CN. Quem promulga são as mesas da CD + SF. Não há prazo entre 1º e 2º turno nem para promulgar. Não há sanção ou veto pelo Presidente. Aplica a irrepetibilidade absoluta.
Material	São as **cláusulas pétreas**. Proposta não pode sequer ser deliberada nas seguintes matérias: - forma federativa de Estado; - direitos e garantias individuais; - voto direto, secreto, universal e periódico; - separação de Poderes.
Implícita	Não pode haver mudança nos legitimados à propositura de PEC e não se admite procedimento da dupla revisão (primeiro mexe no artigo 60, retirando as limitações explícitas, e depois mexe o que elas protegiam).
Temporal	Não existe na Constituição atual.

Mas as cláusulas pétreas merecem um show à parte. Vamos?

Destaques sobre as cláusulas pétreas	
Forma Federativa de Estado	- Não se permite direito de secessão.
Direitos e garantias individuais	- Abrange os artigos 5º, 16 e 150.
Voto direto, secreto, universal e periódico	- Obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. - Voto impresso é inconstitucional por ser possível violar sigilo das votações.
Separação de Poderes	- Não há violação se o Judiciário impuser obrigação à Administração para realizar obras emergenciais em presídio. - É **inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário local.** - É inconstitucional lei estadual que condiciona todas as desapropriações feitas a prévia aprovação do Legislativo. - É inconstitucional lei estadual que exija a sabatina de nomes de lista tríplice ao cargo de Procurador-Geral de Justiça ou de candidatos ao quinto constitucional para o TJ.
Observações: 1) a doutrina cita a existência de cláusulas pétreas implícitas. Ex.: princípios fundamentais (Professor Gilmar Mendes). 2) Para barrar a tramitação de PEC violando cláusula pétrea, cabe MS impetrado por parlamentar (controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade).	

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Agora vou fazer dois quadros esquemáticos. No primeiro, com comparações entre o PCO e o PCD. No segundo, traçando as diferenças entre o PCD Reformador (EC) e o PCD Revisor (ECR).

Diferenças entre constituinte originário x constituinte derivado	
Originário	**Derivado**
Juridicamente ilimitado, inicial, autônomo, inaugural.	Obedece a limites e condicionamentos, que são colocados pelo PCO.
Normas do Constituinte Originário nunca são inconstitucionais. Caso estejam em choque, a solução passará pela **ponderação de interesses.**	Normas do Constituinte Derivado (Decorrente, Revisor ou Reformador) podem ser inconstitucionais, quando contrariem aquelas editadas pelo Originário.

Diferenças entre constituinte revisor x constituinte reformador	
Revisor (ECR)	**Reformador (EC)**
Aprovação por **maioria absoluta** de votos.	Aprovação pelo quórum qualificado de **três quintos** de votos.
Votação em sessão **unicameral.**	Votação em cada Casa do Congresso Nacional (**CD + SF**).
Uma única votação (**1x**).	Duas votações em cada Casa (**2x**).
Observação: ambas precisam respeitar as limitações previstas no artigo 60 da Constituição.	

ATENÇÃO

Vale lembrar que o presidente da República **não** promulga, **não** sanciona e **não** veta as **emendas à Constituição**. A única fase em que ele pode participar é na iniciativa, propondo a PEC.

1.8.3. NORMAS CONSTITUCIONAIS NO TEMPO

É hora de vermos o que acontece com a Constituição anterior quando a nova entra em cena.

Pois bem. Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, a situação é bem mais simples, uma vez que **a Constituição anterior será revogada pela nova**. Tem mais: **não importa se esse ou aquele trecho da Constituição anterior está de acordo com a Constituição atual**, na medida em que **ocorre a ab-rogação (revogação total), e não derrogação (revogação parcial)**.

Ou seja, a solução é *relativamente* simples. Mas é claro que as coisas sempre podem piorar, pois também aqui há exceções. É que, embora a regra seja a nova Constituição revogar completamente a anterior, há duas hipóteses nas quais o texto antigo ainda continuará sendo aplicado. É o que ocorre na desconstitucionalização e na recepção material.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vou explicar a seguir cada um desses fenômenos:

1.8.3.1. DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO

A desconstitucionalização acontece quando a nova Constituição, ao invés de revogar a anterior, opta por recebê-la com *status* de lei (infraconstitucional).

Essa técnica já foi utilizada no Estado de São Paulo, quando a CE/SP de 1967 trouxe a seguinte: "consideram-se vigentes, com o caráter de lei ordinária, os artigos da Constituição promulgada em 9 de julho de 1947 que não contrariarem esta Constituição".

Lembro que, em regra, a desconstitucionalização não é admitida; para que ela exista, deve haver uma ordem explícita na nova Constituição, o que não aconteceu com a Constituição de 1988.

1.8.3.2. RECEPÇÃO MATERIAL

Diferentemente do que ocorre na desconstitucionalização, na **recepção material,** as disposições da **Constituição anterior** são **recebidas** com **status de norma constitucional**.

Preste muita atenção, pois esse mecanismo é bem mais explorado nas provas, porque foi utilizado no art. 34 do ADCT, que trouxe a seguinte previsão:

> **Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967**, com a redação dada pela Emenda n. 1, de 1969, e pelas posteriores.
> § 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e 159, I, "c", revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.

Conforme adverte Pedro Lenza, "as referidas normas são recebidas por **prazo certo**, em razão de seu **caráter precário**, características marcantes no fenômeno da **recepção material das normas constitucionais**".[67]

Assim como a desconstitucionalização, a recepção material só será possível caso haja a **previsão expressa** na nova Constituição. Do contrário, volta-se para a regra da revogação total (ab-rogação).

1.8.3.3. *VACATIO CONSTITUCIONIS*

Vacatio legis pode ser conceituado como período vago da lei. Para mim, seria o período para você se acostumar com a nova norma. Seja como for, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, antiga LICC) diz que, salvo disposição em contrário, a lei entra em vigor no Brasil quarenta e cinco dias após a publicação. No exterior, esse intervalo sobe para três meses.

---

[67] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 169.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Será que podemos falar em *vacatio constitucionis*?

A resposta é **sim**, desde que conste previsão expressa na Constituição.

A título ilustrativo, a Constituição de 1967 e a EC n. 1/1969 – por muitos, considerada uma nova Constituição – estabeleceram um momento posterior para a entrada em vigor de ambas.

O mestre José Afonso da Silva, inclusive, destaca que a norma infraconstitucional editada no período de *vacatio constitucionis* deve ter sua constitucionalidade aferida de acordo com a Constituição que vigorava à época (a quase-morta).[68]

Tem mais: se a lei editada no período de *vacatio constitucionis* for incompatível com a nova Constituição, ela será revogada, por ausência de recepção.

ATENÇÃO

A desconstitucionalização e a recepção material são exceções à regra, segundo a qual a nova Constituição revoga totalmente a anterior, mesmo nos dispositivos compatíveis entre elas.

1.8.4. PODER CONSTITUINTE DIFUSO (MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL)

São vários os nomes que dizem a mesma coisa: **poder constituinte difuso**, **procedimento de mudança informal da Constituição ou mutação constitucional** (o mais conhecido).

Segundo parte da doutrina, seria um poder que decorre de fatores sociais, políticos e econômicos. Consiste na alteração informal de uma norma da Constituição.

Em outras palavras, seria a modificação da interpretação sem alteração no texto.

Pedro Lenza diz que:

> se por um lado a mudança implementada pelo poder constituinte derivado reformador se verifica de modo formal, palpável, por intermédio das emendas à Constituição, **a modificação produzida pelo poder constituinte difuso se instrumentaliza de modo informal e espontâneo, como verdadeiro poder de fato**, e que decorre dos fatores sociais, políticos e econômicos.[69]

1.8.5. PODER CONSTITUINTE SUPRANACIONAL

Seria o poder que cria uma Constituição, na qual cada Estado cede uma parcela de sua soberania para que uma Constituição comunitária seja criada. O titular deste Poder não é o povo, mas o cidadão universal.

Ele tem por fundamentos: a cidadania universal; pluralismo de ordenamentos jurídicos; vontade de integração e soberania remodelada. Talvez, a **União Europeia** seja hoje a realidade social mais próxima de ser influenciada e sofrer os efeitos concretos de um movimento de **constitucionalização do Direito Comunitário Europeu**.

[68] SILVA, José Afonso da. *Aplicabilidade das normas constitucionais*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 54.

[69] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 19. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 238.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Aliás, o tema muito se aproxima da tese do **transconstitucionalismo**, defendida por **Marcelo Neves**. Isso porque uma ordem supranacional teria mais mecanismos para solucionar os problemas de direitos fundamentais e ou humanos surgidos numa sociedade complexa e com barreiras cada vez mais fluidas.[70]

Outros autores falam em uma **globalização do direito constitucional**, ou ainda na **teoria da interconstitucionalidade**, como forma de resolver conflitos de várias constituições e de vários poderes constituintes no mesmo espaço político.[71]

Embora se possa cogitar choque entre o movimento transnacional e o patriotismo constitucional, Flávio Martins esclarece que não há incompatibilidade, e sim transformação. Isso porque o poder transformador da Constituição seria visto num contexto cosmopolita e supranacional. Aliás, essa consciência cosmopolita teria Habermas como um dos grandes entusiastas.[72]

1.9. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – A IDEIA DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO

Na minha prova oral de Juiz do TJDFT ainda lembro quando o Examinador me perguntou mais ou menos assim:

"Candidato, onde a norma busca sua validade?"

Eu, de pronto, respondi: "Na norma superior, Excelência".

A partir daí seguiu um bate-bola em que ele ia perguntando degrau a degrau da Pirâmide de Kelsen, até chegar onde ele queria:

"E a Constituição, busca validade onde?"

A resposta para essa pergunta não é tão simples! É que alguns poderiam dizer que ela busca validade no Direito Natural, nas outras ciências etc.

Contudo, o idealizador da pirâmide do ordenamento é Hans Kelsen, nada menos do que "o pai do Positivismo". Ou seja, ele não buscava a validade fora do juridiquês.

Ao contrário, **Kelsen afirma que a Constituição busca validade nela mesma, por ser a norma hipotética fundamental**.

Pois bem!

Avançando, não há dúvidas de que, **em virtude do princípio da supremacia da Constituição, as normas constitucionais estão no topo da pirâmide do ordenamento jurídico**.

E o que isso quer dizer?

[70] NEVES, Marcelo. *Transconstitucionalismo*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

[71] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional e teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 81.

[72] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 139.

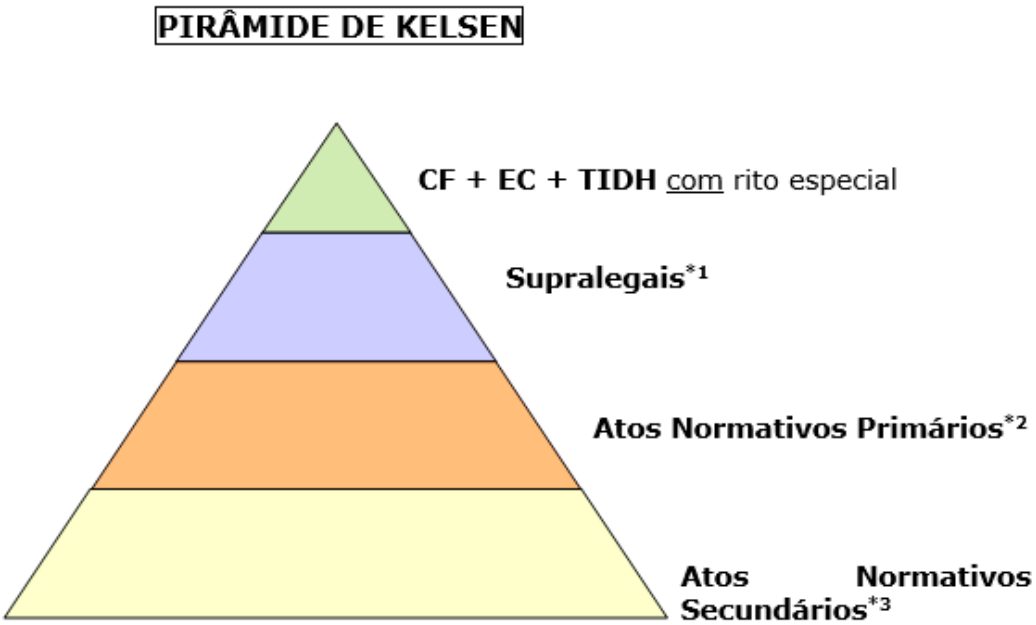
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Significa que todas as normas devem ser compatíveis formal e materialmente com o que está na Constituição!

Mas essa pirâmide conta com outros substratos...

Vou partir para a ilustração e depois explicarei mais detidamente.

Veja:



Obs.: ***1:** TIDH **antes** EC n. 45/2004 **ou após**, mas **sem** rito especial (dois turnos, três quintos em cada Casa do Congresso Nacional.

***2:** leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos, tratados internacionais (que **não** versam sobre direitos humanos), decretos autônomos e resoluções do CNJ e do CNMP.

***3:** portarias, decretos regulamentares, instruções normativas.

Agora é hora de decodificar! Lá no topo da pirâmide não está apenas a Constituição. Ao contrário, também estarão as emendas à Constituição (**ECs**) e os tratados internacionais sobre direitos humanos (**TIDH**) aprovados sob o rito das ECs (dois turnos, três quintos de votos, em cada Casa do Congresso Nacional).

Mas fique atento(a): as ECs são obra do Poder Constituinte Derivado Reformador. Logo, estão sujeitas às limitações impostas pelo Constituinte Originário. Em consequência, caso elas violem quaisquer das restrições, poderão ser declaradas inconstitucionais, tanto do ponto de vista formal quanto material.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ATENÇÃO

Em **09/07/2008**, foi aprovado o **Decreto Legislativo n. 186/2008, que é equivalente a emenda à Constituição**. O tratado internacional foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro a partir do **Decreto Presidencial n. 6.949/2009**. Ele trata sobre a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** e de seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em Nova Iorque no dia 30/03/2007.

Em 2015, o Congresso Nacional editou o **Decreto Legislativo n. 261/2015**, aprovando o **Tratado de Marraqueche**, tratado internacional sobre direitos humanos que nasceu para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. A internalização ocorreu com o **Decreto Presidencial n. 9.522/2018**.

Por sua vez, em 2021, o Congresso Nacional aprovou Projeto de Decreto Legislativo confirmando a adesão do Brasil à **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância**. A internalização se completou em janeiro de 2022, com o Decreto Presidencial n. 10.932/2022. Com isso, **as cotas raciais passaram a ser normas constitucionais**, uma vez que o TIDH foi aprovado com status equivalente ao das ECs.

Já no andar de baixo estão as **normas supralegais**, que **se situam acima das leis** (atos normativos primários) **e abaixo da Constituição** (topo da pirâmide). Elas também englobam os tratados internacionais sobre direitos humanos. A diferença para "o andar de cima" é que os **TIDH** que estão aqui **não** foram aprovados no rito especial das ECs.

Ah, lembre-se de que a equiparação de TIDH com rito especial às ECs foi uma novidade trazida pela EC n. 45/2004. Desse modo, **todos** os TIDH anteriores à referida emenda serão supralegais. Quanto aos que forem posteriores, quando a EC já estava em vigor, deve ser verificado o rito usado na incorporação da norma ao direito brasileiro.

Um parêntese: em 2.022, o STF entendeu que **tratados internacionais versando sobre direito ambiental são considerados TIDH**. Em consequência, possuem **status supralegal**, podendo ser usados para o controle de convencionalidade (STF, ADPF n. 708).

E mais: nada impede que eles sejam internalizados pela sistemática especial do § 3º do artigo 5º, situação em que terão status constitucional.

Descendo mais um degrau, temos os atos normativos primários, que são "o grosso" das normas que temos em nosso país. Aqui estão as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos e também as medidas provisórias. Ou seja, de todos os atos normativos descritos no artigo 59 da Constituição só ficarão faltando as ECs. Isso acontece porque elas ficam lá no topo da pirâmide, como você já viu.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mas os atos normativos primários vão além do rol descrito no artigo 59 da Constituição para também contemplar os decretos autônomos, os tratados internacionais em geral (que não versam sobre direitos humanos), os regimentos internos dos Tribunais e também as resoluções editadas pelo CNJ e pelo CNMP.

Repare num ponto importantíssimo: prevalece a orientação no sentido de que não há hierarquia entre os atos normativos primários, exceto as ECs.

Sobre o tema, a discussão principal que havia era em torno das leis ordinárias e das complementares. Para alguns doutrinadores (corrente minoritária que tem, entre outros, Manoel Gonçalves Ferreira Filho e de Alexandre de Moraes), as leis complementares estariam em patamar superior às ordinárias, pois o quorum para a sua aprovação, maioria absoluta, é mais rigoroso do que o exigido para as leis ordinárias, maioria simples ou relativa.

Porém, como eu já disse, o STF acabou decidindo pela inexistência de hierarquia entre LC e LO (STF, RE 509.300).

Mas há outra diferença entre LC e LO: **a distribuição material feita pela Constituição**. Dizendo com outras palavras, quando a Constituição quer LC ela 'pede'. Isso aparecerá mais ou menos assim: "na forma da lei complementar", "nos termos da lei complementar", "a lei complementar estabelecerá".

Quanto à LO, a Constituição reserva todas as demais matérias. Normalmente, aparecem as expressões "na forma da lei", "nos termos da lei" etc. Não se fala a expressão "lei **ordinária**".

Mas pense comigo: pode uma Constituição **Estadual** exigir a edição de lei complementar para matérias nas quais a Constituição Federal só pedia lei ordinária?

Analisando essa situação, o STF disse **não**.

Na ocasião, foi pontuado que a criação de reserva de lei complementar tem a finalidade minimizar a influência das maiorias parlamentares circunstanciais no processo legislativo referente a determinadas matérias. Isso porque a aprovação de leis complementares depende de mobilização parlamentar mais intensa para a criação de maiorias consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, bem como o gasto de capital político e institucional que propicie essa articulação.

Assim, a ampliação da reserva de lei complementar, para além daquelas hipóteses previstas no texto constitucional, geraria uma restrição indevida no arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal.

Para deixar ainda mais claro, nada melhor do que você entender de quais assuntos estamos tratando, né?

É que a Constituição do estado de Santa Catarina exigia a edição de lei complementar para o tratamento: (i) do regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; (ii) da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do regime jurídico de seus servidores; (iii) da organização do sistema estadual de educação; e (iv) do plebiscito e do referendo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Acontece que em nenhum desses casos a CF exigiu lei complementar. Basta pensar que a Lei (Ordinária) n. 8.112/1990 é a norma que traz o regime jurídico dos servidores civis da União, certo?

Sintetizando, **se a CF não exigiu LC para aquele assunto, não pode a CE exigir. Basta lei ordinária** (STF, ADI n. 5.003).

Seja como for, nada impede que o Congresso Nacional edite uma LC mesmo diante de matéria que deveria ser LO. O contrário é que gera inconstitucionalidade.

É dentro desse cenário que surgem algumas afirmações: uma LO pode revogar outra LO; uma LC pode revogar outra LC; **uma LC pode revogar uma LO**; e, **em regra**, **uma LO não pode revogar uma LC**.

Eu disse "em regra", porque, se a LC trouxer conteúdo de LO, ela será LC "na casca", mas LO "na essência". Desse modo, é verdadeira a afirmação segundo a qual "uma LO pode revogar uma LC".

Aliás, já me deparei com algumas questões de prova exatamente nesse sentido. O que o examinador perguntou foi a exceção, e não a regra. Fazendo uma comparação, seria o mesmo de um item de sua prova falar "existe pena de morte no Brasil".

Ora, nesse caso, você sabe que, em regra, a pena de morte é proibida. No entanto, em caso de guerra declarada, ela será possível, não é mesmo?

Voltando para as leis, essa situação – de LC com conteúdo de LO – chegou ao STF. Na ocasião, a Lei Complementar n. 70/1991 tratou de matéria não prevista para ser tratada por LC (instituição de contribuição social). Posteriormente, a Lei (Ordinária) n. 9.430/1996 revogou a referida LC.

Houve questionamento, mas o STF entendeu pelo cabimento da revogação, pois, repito, a LC tinha "casca" de LC, mas "essência" de LO. Ou seja, na prática, seria o mesmo de uma LO revogar outra LO (STF, RE n. 509.300).

ATENÇÃO

Prevalece a orientação segundo a qual **não** há hierarquia entre leis ordinárias e complementares.

Outra coisa: **os atos normativos primários são assim chamados por retirarem sua força normativa diretamente da Constituição**, o que implica dizer que eles **estão sujeitos a controle de constitucionalidade**.

Já a base da pirâmide traz os **atos normativos secundários**. Aqui encontramos os decretos regulamentares, as instruções normativas e as portarias.

Ao contrário dos primários, eles não retiram sua validade diretamente da Constituição, mas, sim, dos atos primários. É por isso que se fala em **controle de legalidade (e não de constitucionalidade)**.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pronto! Expliquei a você, ponto a ponto, dos andares da "Pirâmide de Kelsen". Para que não fique nenhuma dúvida, vou apresentar o mesmo conteúdo em forma de itens numerados a seguir. Acompanhe:

1. Pelo princípio da **supremacia da constituição**, a Constituição Federal é hierarquicamente superior às demais normas. Ou seja: se uma norma contrariar a Constituição Federal, ela será inconstitucional.

2. Não há hierarquia entre normas originárias da Constituição. Quando, no caso concreto, houver um conflito (na verdade, apenas aparente) entre as normas, deve-se recorrer a princípios interpretativos.

Assim, uma norma pode ceder espaço à outra, sem que isso implique sua inconstitucionalidade. Fala-se usualmente em ponderação de interesses no caso concreto.

EXEMPLO

A imprensa precisa noticiar, mas muitas vezes em sua atuação acaba invadindo a intimidade das pessoas. O problema é que ambos os valores (liberdade de expressão e intimidade da vida privada) estão na Constituição desde 1988.

Então, para resolver o embate, o intérprete, caso a caso, deverá analisar qual das normas prevalecerá. Não dá para se afirmar de antemão qual terá maior peso.

Seguindo, destaco que **o STF não admite a teoria da inconstitucionalidade de normas originárias** (editadas pelo Constituinte Originário), defendida pelos professores Otto Bachof e Jorge Miranda (STF, ADI 815).

3. Uma EC ou uma Constituição Estadual (CE) podem ser declaradas inconstitucionais, caso desrespeitem a Constituição Federal. Isso ocorre porque as ECs e as CEs fazem parte do Poder Constituinte Derivado – respectivamente, derivado reformador e derivado decorrente. Assim, elas devem estar de acordo com as limitações (formais, circunstanciais, materiais e implícitas) trazidas pela Constituição.

É comum a seguinte indagação nas provas: **EXISTE norma constitucional inconstitucional?. A resposta é... depende.**

Se a norma for originária, não haverá hipótese de inconstitucionalidade. Agora, se ela for fruto do Constituinte Derivado, poderá padecer de vício de inconstitucionalidade.

EXEMPLO

Pode uma EC ou um artigo de determinada CE serem declarados inconstitucionais por afrontarem a Constituição Federal.

4. Uma emenda à Constituição é hierarquicamente superior às leis, pois se incorpora ao texto constitucional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

5. Não existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais. O que existe são diferentes âmbitos de atuação (cada uma atua em sua esfera de competência, definida pela Constituição).

6. Prevalece o entendimento de que **não existe hierarquia entre lei ordinária** (**LO**) **e lei complementar** (**LC**). O que haveria, na verdade, são diferentes âmbitos de atuação.

7. Segundo a jurisprudência do STF, uma LC pode ser revogada por uma LO (desde que a LC tenha tratado de matéria própria de LO).

8. Excetuando as Emendas à Constituição, não há hierarquia entre os atos normativos primários, previstos no art. 59 da CF/1988.

9. Com relação aos tratados internacionais, devem ser feitas algumas considerações...

a) Em regra, os tratados internacionais têm status (força) de lei ordinária. Ou seja, encaixam-se entre os atos normativos primários.

b) A partir da **EC n. 45/2004**, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos (**TIDH**) que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às **emendas constitucionais**.

c) Os tratados internacionais sobre direitos humanos (**TIDH**) **que não tenham passado pelo rito especial de aprovação**, têm status de **norma supralegal**, ou seja, estão acima das leis e abaixo da Constituição.

d) A incorporação de tratados em nosso ordenamento é ato complexo, que conta com a manifestação do Executivo e do Legislativo. Tanto para tratado ingressar no ordenamento quanto para ele ser denunciado é necessária a participação do Presidente e do Congresso (ADI 1.625).

Espera aí! Eu já falei que atos primários se submetem a controle de constitucionalidade e que os secundários se sujeitam a controle de legalidade, certo? Mas **como se chama a verificação de compatibilidade entre os atos primários e as normas supralegais, que lhes são superiores?**

Nessa situação teremos o **controle de convencionalidade**. Estranhou o nome? É porque eles são tratados ou **convenções** sobre direitos humanos...

Opa, então fica claro que **os atos primários se sujeitam a duplo controle: tanto de constitucionalidade quanto de convencionalidade.**

Sistematizando, tratados internacionais podem ter três status diferentes. Veja:

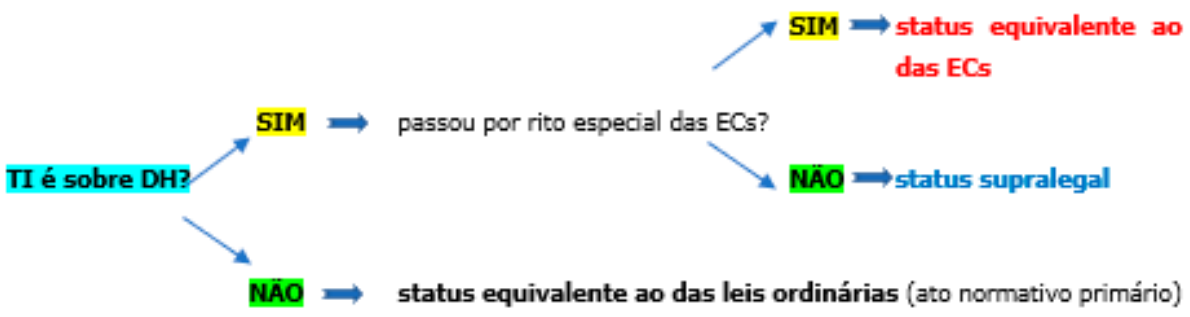
a) status constitucional: somente os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em dois turnos, por 3/5 de votos, passando por cada Casa do Congresso Nacional. Serão equivalentes às emendas à Constituição;

b) status supralegal: também são tratados internacionais sobre direitos humanos. No entanto, não passaram pelo rito especial descrito aí em cima;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) status legal: todos os tratados internacionais que NÃO versem sobre direitos humanos.

Vou colocar de modo diferente agora:



10. Os decretos **regulamentares** são considerados atos normativos **secundários**. A sua missão é a de **regulamentar as leis**. Daí se diz que eles se sujeitam a controle de **legalidade**, e não de constitucionalidade.

Em sentido contrário, os **decretos autônomos**, inseridos pela EC n. 32/2001, dando nova redação ao **artigo 84, VI, da Constituição** (**dispositivo exaustivamente cobrado nas provas!**), são considerados **atos normativos primários**, sujeitando-se a controle de **constitucionalidade**.

Sistematizando, temos o seguinte quadro:

Constituição	Constituição
Lei (ato primário)	- - - - - -
Decreto Regulamentar (ato secundário)	**Decreto Autônomo (ato primário)**

Por outro ângulo...

Espécie	Submissão	Classificação
Decretos regulamentares	À lei e à CF	Ato normativo **secundário**
Decretos autônomos	Somente à CF	Ato normativo **primário**

Agora você já tem munição suficiente para derrubar qualquer pergunta que venha em prova sobre princípio da hierarquia das normas ou sobre supremacia da Constituição.

1.10. EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Quando se fala em teoria da Constituição, dificilmente o edital do concurso deixa de cobrar a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O tema é recorrente e, na boa, não é lá um bicho papão. O que as Bancas mais fazem é trocar as bolas, confundindo você nas normas de eficácia contida e na limitada – uma é o contrário da outra!

Ah, mas como o tema é doutrinário, há mais de uma classificação para piorar as coisas um pouquinho...

A discussão sobre eficácia e aplicabilidade das normas foi trazida para o Brasil por Rui Barbosa, nascendo na doutrina norte-americana com Thomas Cooley, que dividia as normas em autoexecutáveis e não autoexecutáveis.

Nesse cenário, as autoexecutáveis (*self-executing*) teriam aptidão para gerar efeitos jurídicos desde a entrada em vigor da Constituição, sem depender do legislador ordinário. De outro giro, as não autoexecutáveis (*not self-executing*) precisariam da atuação do legislador ordinário, para que só assim viabilizassem os direitos nelas previstos.

Acontece que a tese de Cooley sofria críticas: por não conter normas programáticas, geralmente ligadas às constituições sociais; e porque a algumas normas constitucionais faltaria a imperatividade.

Avançando, surge a teoria italiana, que teve como expoente Vezio Crisafulli e teve como contribuição principal dar vida às normas programáticas.

No cenário brasileiro, segundo Bernardo Gonçalves Fernandes[73], o primeiro jurista a abordar o assunto teria sido J. H. Meirelles Teixeira, tendo distinguido as normas constitucionais entre as de eficácia plena e as de eficácia limitada.

No entanto, **a mais tradicional** delas – **e também a mais cobrada** (de longe) – **é aquela desenvolvida pelo grande Mestre José Afonso da Silva no ano de 1.967**[74].

É por ela que vou começar, trabalhando rapidamente com as variações referidas pelos professores Maria Helena Diniz[75], Michel Temer[76] (ele mesmo) e também por Celso Bastos e Ayres Britto[77].

Um alerta importante: na divisão de José Afonso da Silva, existiriam **três espécies** de norma, a saber, as de **eficácia plena**; as de **eficácia contida** e as de **eficácia limitada**. Estas últimas **eram desdobradas** em **limitadas de princípio institutivo** e **limitadas de caráter programático**.

É, meu(minha) amigo(a), mas seu negócio é fazer prova... então é importante você saber (o que se confirma olhando o edital) que **normalmente as Bancas colocam a norma programática como fosse uma quarta espécie**, desvinculada das limitadas. Pois é mais ou menos assim que a nossa banda vai tocar...

---

[73] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm. 2018, pág. 108.

[74] SILVA, José Afonso da. *Aplicabilidade das normas constitucionais*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

[75] DINIZ, Maria Helena. *Norma constitucional e seus efeitos*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1997.

[76] TEMER, Michel. *Elementos de direito constitucional*. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

[77] BASTOS, Celso Ribeiro; BRITTO, Carlos Ayres. *Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais*. São Paulo: Saraiva, 1982.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.10.1. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA

A norma de eficácia plena é a mais fácil e (não à toa) é a que menos cai em provas.

Elas possuem **aplicabilidade direta, imediata e integral**. São aquelas normas que, no momento de sua entrada em vigor, **já estão aptas a produzir todos os seus efeitos**, **não precisando** de norma integrativa infraconstitucional.

Os exemplos mais cobrados pelas Bancas são os **remédios constitucionais** e a norma que prevê **gratuidade de transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos** (art. 230, § 2º). Outros exemplos: art. 2º; 14, § 2º; 17, § 4º; 19; 20; 21; 22; 24; 30 etc.

É também essa a nomenclatura de Maria Helena Diniz.

1.10.2. NORMAS DE EFICÁCIA CONTIDA

Aqui e nas limitadas seu cuidado vai ser redobrado!

Eu falo sempre nas minhas aulas que as normas contidas nascem plenas até serem contidas (restringidas). Como assim?

É que **elas também possuem aplicabilidade direta e imediata**. A diferença ante as de eficácia plena é que a sua aplicabilidade **possivelmente não será integral**.

Isso porque, **embora elas tenham aptidão, desde o nascimento, para produzir todos os seus efeitos**, já que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos àquela matéria, **pode haver a restrição posterior**, seja pelo próprio Constituinte, seja pelo legislador ordinário ou ainda por força de norma supralegal.

Para explicar usando exemplos, vou para o dispositivo mais cobrado (de longe!) por todas as bancas: o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição diz que:

> **é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão**, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Veja que na primeira parte, quando disse ser "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, a norma nasceu plena, com aplicabilidade direta e imediata. Contudo, depois o dispositivo dá margem para que **a lei** estabeleça a exigência de qualificações profissionais.

É dentro desse contexto que eu posso entender que qualquer pessoa pode trabalhar como atendente numa padaria, num supermercado, num curso preparatório...

Agora eu pergunto a você: qualquer pessoa pode exercer a profissão de médico, de engenheiro, de dentista, de arquiteto, de educador físico, advogado?

Não! Para elas, há necessidade de o trabalhador ser graduado na respectiva área de conhecimento, ter registro no órgão de classe (Conselhos Regionais) e, em alguns casos, fazer provas seletivas mesmo depois da obtenção do título de bacharelado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

É o caso, por exemplo, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que exige a aprovação no exame da Ordem para que o Bacharel em Direito se torne advogado. Questionada no STF, a exigência foi confirmada como constitucional (STF, RE 603.583).

Interessante que os autores da ação falavam que não seria necessária a prova na OAB ao argumento de que para exercer a Medicina o profissional não se submete a nenhuma prova. Em resposta, o Tribunal disse que errado estava o pessoal da Medicina, que também deveria prever a realização de provas, que funcionariam como um filtro para afastar a atuação dos maus profissionais.

Fique atento(a), pois há um julgado do STF que cai com frequência em provas de concurso: a Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) exigia a inscrição profissional naquela entidade para que os músicos exercessem sua profissão.

O Tribunal, por sua vez, pontuou que a regra seria a liberdade e apenas diante de potencial lesivo da atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. Com isso, **afastou a obrigatoriedade da inscrição na OMB para o exercício da atividade de músico** (STF, RE 414.426).

Já sobre o exercício da **profissão de jornalista**, para o STF, a fim de assegurar a liberdade de expressão, **o exercício da profissão de jornalista é garantido a todas as pessoas**, e **não somente aos bacharéis em jornalismo** (STF, RE 511.961).

Avançando, repare que eu falei ali atrás que às vezes a restrição não vem do legislador ordinário, certo?

Pois é, é por essa razão que o Pacto de São José da Costa Rica restringiu (conteve) o alcance do dispositivo constitucional que prevê que "**não haverá prisão por dívida**, **salvo** a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia **e a do depositário infiel**".

Como você deve saber, na atualidade, **não é possível a prisão do depositário infiel e do alienante fiduciário** (Súmula Vinculante 25). Isso se deve porque a norma supralegal (o tratado internacional sobre direitos humanos – Pacto de São José) revogou as leis ordinárias que regulamentavam a prisão civil nesses casos.

Ou seja, **nada mudou na Constituição!** Assim, **é indevido falar que a prisão do depositário infiel se tornou inconstitucional**, até mesmo porque nós **não** aceitamos a figura das normas constitucionais inconstitucionais (ou inconstitucionalidade de normas originárias).

Toda a discussão girava em torno de ser uma norma contida, tendo o dispositivo do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição sofrido a restrição (redução, contenção) por outra norma (STF, HC 94.013).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Um ponto importante: Virgílio Afonso da Silva **critica a distinção feita entre normas de eficácia plena e contida**, ao argumento de que toda norma poderia ser restringida pela legislação ordinária. Segundo ele, a única forma de manter a distinção seria reconhecer que as normas plenas estariam sujeitas a limites que decorressem expressa ou implicitamente do texto constitucional. Por outro lado, as normas contidas poderiam ser limitadas/restringidas pelo legislador ordinário.

EXEMPLOS

Incisos VII, VIII, XV, XXIV, XXVI, XXVII, XXXIII do art. 5º; art. 15, IV etc.

ATENÇÃO

As normas de eficácia contida são chamadas de normas com **eficácia relativa restringível pela professora Maria Helena Diniz**. Por sua vez, **Michel Temer utiliza a expressão normas de eficácia redutível ou restringível**.

1.10.3. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA

Vou falar uma frase que você deve levar como um mantra, ok? Lá vai: **a norma limitada é o contrário da contida!**

Se você entender isso vai parar de errar nas provas! Veja:

Você já viu que a **norma contida** possui aplicabilidade **direta** e **imediata**, mas que **pode não ser integral caso haja a restrição** (redução, contenção) por outra norma.

Por sua vez, **a norma limitada possui aplicabilidade indireta, mediata e dependente de complementação**.

São aquelas que, **de imediato**, no momento em que a Constituição é promulgada, **não têm a possibilidade de produzir todos os seus efeitos**, **precisando de uma lei integrativa**. Ou seja, **será necessária a atuação do legislador infraconstitucional**.

Note que na eficácia contida a lei posterior viria para restringir, reduzir, conter o alcance da norma constitucional. Em sentido oposto, na eficácia limitada a lei vem para completar, concretizar a vontade do Constituinte.

Vou explicar por meio de exemplos: o artigo 37, inciso VII, da Constituição diz que:

> **o direito de greve de servidor público** será exercido **nos termos e nos limites definidos em lei específica**.

Ou seja, ao mesmo tempo em que deu o direito de greve, condicionou o seu exercício à edição de lei. Enquanto ela (a lei) não fosse promulgada, não poderia o servidor utilizar desse direito.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Idêntico raciocínio vale para **a aposentadoria especial dos servidores públicos**, prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição.

Nesse dispositivo se permite que pessoas com deficiência e aqueles que trabalham com atividades que traga risco à vida ou que prejudique a saúde sejam beneficiados por regras diferenciadas "**nos termos definidos em leis complementares**".

Abrindo um parêntese, embora não tenham sido editadas as leis regulamentando a greve no serviço público ou a aposentadoria especial para algumas atividades (exemplo: lidar com aparelhos de Raio X), o STF, ao julgar mandados de injunção, acabou permitindo que os servidores usassem leis específicas voltadas aos trabalhadores da iniciativa privada (STF, MI 608 e SV n. 33).

EXEMPLO

Outro exemplo frequente em provas quando o assunto é norma de eficácia limitada está no artigo 7º, XI, que trata da possibilidade de os trabalhadores terem **direito à participação nos lucros da empresa**.

Ah, **o cabimento do mandado de injunção está intimamente relacionado às normas de eficácia limitada**, pois o remédio constitucional vem exatamente para combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Dito de outro modo, na falta da norma regulamentadora, o particular acaba recorrendo à Justiça, como forma de concretizar o exercício do direito garantindo da Constituição.

Outra coisa para lá de importante: **é incorreto dizer que as normas de eficácia limitada, sem o complemento legislativo, não produzem nenhum efeito**!

Explico: **mesmo sem a edição da lei regulamentadora, as normas limitadas possuem eficácia jurídica imediata**. Isso significa que elas contam com a chamada **eficácia mínima** ou **efeito paralisante** e também o **efeito revogador**.

Trocando em miúdos, desde a promulgação da Constituição (e, repito, **sem** o complemento do legislador ordinário), elas impedem que leis inviabilizem direitos previstos na Constituição (eficácia paralisante) e revogam normas que sejam contrárias a seu texto (efeito revogador).

Vou exemplificar: considerando que o artigo 37, VII, da Constituição prevê o direito de greve aos servidores públicos, seria inconstitucional uma lei editada hoje dizendo que os servidores públicos em geral não teriam direito de fazer greve (eficácia paralisante).

Por outro lado, uma lei editada no ano de 1985 que proibisse a aposentadoria especial para servidores públicos que trabalham em atividades que prejudiquem a saúde não terá sido recepcionada (revogação por ausência de recepção) pela nova ordem constitucional, especialmente diante do direito assegurado no artigo 40, § 4º.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Só mais uma coisinha...

Como você viu, as normas de eficácia limitada demandam a integração por meio do trabalho do legislador ordinário.

A regra é que elas sejam **impositivas**, ou seja, chamando o legislador para atuar. Se ele for omisso, **caberá a impetração do MI** para compeli-lo a regulamentar o texto constitucional.

Porém, há normas de eficácia limitada **facultativas**. Nelas, o Constituinte previu algo, mas só será implementado se o legislador quiser. Ele não é obrigado a fazer. Daí, **não caberá MI**. Exemplo: o artigo 148, que trata da possibilidade de criação da figura do empréstimo compulsório (que nunca foi criado).

ATENÇÃO

Maria Helena Diniz chama as normas limitadas de **normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa**.

1.10.4. NORMAS PROGRAMÁTICAS

Antes de entrar em cada uma das espécies de normas, eu avisei que na obra do Professor José Afonso da Silva ele fazia um desdobramento dentro das limitadas, falando em **limitadas de princípio institutivo e** em **limitadas de caráter programático**.

Eu faço esse alerta, porque no item aí de cima eu tratei das limitadas de princípio institutivo, chamando-as simplesmente de limitadas. Agora, as limitadas de caráter programático serão referidas puramente como programáticas.

Seja como for, você não pode esquecer que as limitadas (de princípio institutivo ou de caráter programático) contam com aplicabilidade indireta, mediata e dependente de complementação.

Dentro desse cenário, repiso que as normas programáticas possuem aplicação diferida, e não aplicação ou execução imediata. Mais do que comandos-regras, elas trazem comandos-valores.

Um ponto importantíssimo que as diferencia das demais: **as programáticas têm como destinatário principal o legislador**, que deverá fazer a ponderação do tempo e dos meios em que vêm a ser revestidas de plena eficácia.

Para facilitar as coisas, **elas veiculam programas de governo, daí o nome de programáticas**.

Outra coisa: embora se diga que os cidadãos não podem invocá-las imediatamente após a entrada em vigor da Constituição, essas normas também não podem ser encaradas como uma "promessa vazia e inconsequente do Constituinte".

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa afirmação conduz à necessidade de o Estado buscar esforços para concretizar o texto da Constituição, que não poderia ser simplesmente ignorado com o pretexto de limitações financeiras (teoria da reserva do possível).

Veja alguns exemplos de normas programáticas: artigos 3º (objetivos da RFB); **4º** (princípios nas relações internacionais); **6º** (direitos sociais); **196** (direito à saúde); **e 205** (direito à educação).

1.10.5. OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Ao longo das classificações desenvolvidas pelo Professor José Afonso da Silva, eu pontuei as nomenclaturas utilizadas para as mesmas espécies por Maria Helena Diniz e por Michel Temer.

Contudo, é bom lembrar a existência de **outra espécie de norma**, segundo a visão de **Maria Helena Diniz**.

Vez por outra, as provas de concursos fazem referência às **normas de eficácia absoluta ou supereficazes**.

Segundo a professora, essas normas **são aquelas que não poderiam ser modificadas por meio de emenda** e que possuiriam **força paralisante total de qualquer legislação** que, explícita ou implicitamente, **vier a contrariá-las**. Ela cita como exemplo as cláusulas pétreas (artigo 60, § 4º, da Constituição).

Avançando, os juristas **Celso Bastos e Ayres Britto** usam uma divisão bastante peculiar: **eles distinguem as normas de aplicação das normas de integração**.

As normas de aplicação já estão aptas a produzir todos os seus efeitos, dispensando regulamentação ou até mesmo permitindo-a, mas sem qualquer restrição do conteúdo constitucional.

Por outro lado, **as normas de integração contam com a atuação do legislador infraconstitucional**, que pode vir para **completá-las** ou para **restringi-las**.

Sem muito malabarismo, dá para traçar um paralelo entre a classificação dos dois autores com aquela desenvolvida por José Afonso da Silva.

É que as **normas de aplicação** se aproximam das normas de **eficácia plena**, enquanto as **normas de integração** seriam semelhantes às normas de **eficácia contida** (quando viessem para restringir) **ou** de **eficácia limitada** (quando a atuação fosse para completá-las).

Por sua vez, Uadi Lammêgo fala nas **normas constitucionais de eficácia exaurida**, citando os dispositivos do ADCT que já cumpriram sua missão em nosso ordenamento jurídico. É o caso do artigo 2º, que previa a realização de plebiscito para escolha de forma e de sistema de governo no ano de 1993.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pontes de Miranda fala em normas bastantes em si e não bastantes em si, algo muito assemelhado às normas autoexecutáveis e as não autoexecutáveis.

Para finalizar, vamos para a classificação de Luís Roberto Barroso.[78] A divisão é a seguinte: a) **normas constitucionais de organização**: as direcionadas aos Poderes do Estado e aos seus agentes. Definem competências dos órgãos, criam órgãos públicos e regulam procedimento de alteração da Constituição; b) **normas constitucionais definidoras de direitos**: são as que estabelecem direitos subjetivos dos cidadãos; e c) **normas constitucionais programáticas**: as que indicam finalidades a serem alcançadas, veiculando programas de governo.

1.10.6. SISTEMATIZAÇÃO

Nesses muitos anos dando aulas, percebi a grande dificuldade dos alunos na identificação da norma constitucional. Em regra, a confusão existe principalmente entre as normas de eficácia contida e as de eficácia limitada.

Pensando nisso, vou usar o seguinte quadro, com o intuito de tornar menos árdua a resolução das provas:

[78] BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas.* 4. ed. São Paulo: Renovar, 2002. p. 84 e seguintes.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PRINCIPAIS ASPECTOS SOBRE EFICÁCIA E APLICABILIDADE			
Classificação	**Aplicabilidade**	**Detalhes**	**Exemplo**
Plena	**Direta, imediata e integral**	Desde a promulgação da CF pode produzir todos os seus efeitos. Não depende de edição de norma regulamentadora, seja ampliando ou restringindo.	Remédios constitucionais; gratuidade de transporte coletivo para idosos.
Contida	**Direta, imediata, mas possivelmente não integral**	Desde a promulgação da CF pode produzir todos os seus efeitos. Porém, norma posterior pode diminuir (restringir, conter) sua aplicação. Enquanto essa restrição não vier, valerá como plena.	Prisão civil por dívida; princípio da liberdade do exercício profissional.
Limitada	**Indireta, mediata e dependente de complementação**	Só com o dispositivo constitucional ainda não pode produzir **todos** os seus efeitos. Será necessária a elaboração de lei regulamentadora pelo legislador ordinário.	Formação de novos municípios; direito de greve de servidor público.
Programática	**Indireta, mediata e dependente de complementação**	São as que veiculam **programas de governo**, sendo dirigidas aos governantes.	Objetivos internos; direitos sociais; saúde e educação.

Observações:
1) mesmo sem o complemento, normas limitadas possuem **eficácia jurídica** imediata. Isso porque elas podem revogar as leis anteriores que sejam contrárias (eficácia revogadora) e impedem a edição de norma em sentido contrário (efeito paralisante).
2) Norma contida também pode ser chamada de relativamente restringível, redutível ou restringível.
3) Norma limitada também pode ser chamada de dependente de complementação legislativa ou de eficácia relativa complementável.
4) Maria Helena Diniz cita que as cláusulas pétreas seriam normas de eficácia absoluta ou supereficazes.
5) Celso Bastos e Ayres Britto dividem em normas de aplicação (aptas a produzir todos seus efeitos) e normas de integração (legislador infraconstitucional poderia completar ou restringir).

1.11. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

Interpretar as normas constitucionais não é uma tarefa nada fácil! Significa compreender, investigar o conteúdo semântico dos enunciados linguísticos que formam o texto constitucional.

A interpretação nasce da necessidade de se compatibilizar as normas constitucionais, de modo a afastar eventuais incompatibilidades. O intérprete deve buscar dar a maior efetividade possível ao texto da Lei Maior.

Tenha em mente que não se pode hierarquizar os vários métodos ou princípios, indicando que este ou aquele seja superior. Ao contrário, o intérprete deve combinar os cânones

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

interpretativos. Stern, citado por Paulo Gonet, diz que o sentido da lei é extraído da utilização sucessiva de todos os métodos de interpretação.[79]

Os referidos autores ainda citam que o papel do intérprete passa por enfrentar, no texto constitucional, **ambiguidades** (ex.: multifacetário conceito de casa, confundida como domicílio ou Casa Legislativa); **incoerências** (ex.: contraposição entre os artigos 61, § 1º, d, e 128, § 5º, relativos à iniciativa legislativa em matérias de interesse do Ministério Público); e **lacunas** (definidas por Jorge Miranda como situações constitucionalmente relevantes não previstas).

No caso das **lacunas**, deve-se buscar saber a razão da lacuna, pois ela pode ser proposital, deixando para o legislador ordinário dispor sobre aquele tema, sem a rigidez própria da Constituição. Atribuiu-se, pois, à **liberdade de conformação do legislador** (ex.: limite máximo de juros reais, antes tratado no artigo 192 da Constituição, mas depois dela retirado).

Outras hipóteses de omissão podem representar um **silêncio eloquente**. Na ilustração de Paulo Gonet, entraria o alcance do cabimento de ADI perante o STF, pois propositalmente se excluiu a análise de leis ou atos normativos municipais.

O autor fala em **lacuna de formulação**, com um verdadeiro esquecimento, exemplificando com a falta de menção a governador e Mesa da Casa Legislativa do DF no rol de legitimados do artigo 103, situação corrigida apenas com a EC n. 45/2004.

Por fim, há a **lacuna axiológica**, segundo a qual, apesar de haver no sistema jurídico uma solução para o caso, essa solução é considerada axiologicamente inadequada. São exemplos a interpretação que restringe o alcance do chamado conflito federativo (artigo 102, I, *f*) ou ainda a que entende pela extensão da imunidade tributária dos livros também ao formato eletrônico, mesmo diante da falta de previsão expressa da Constituição.[80]

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se valem de métodos e princípios de interpretação. A seguir, vou usar os mais importantes, compilados pelo mestre português J. J. Gomes Canotilho[81], referência usada pelas Bancas Examinadoras.

Também apresentarei outras contribuições, especialmente em relação à doutrina norteamericana.

Antes, um alerta: as questões de prova muitas vezes citam um método ou princípio, mas colocam a explicação que seria correspondente a outro. Qual a ideia? Como os conceitos são muito semelhantes, o candidato acaba pensando "eu já vi isso mesmo", sem se atentar para a troca.

Então, o conteúdo trabalhado neste item deve ser revisto periodicamente e, em especial, na véspera das provas. Funciona como um cara-crachá para evitar sua confusão!

---

[79] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 82.

[80] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 89.

[81] CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.11.1. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO

Nas palavras de Canotilho,

> **a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos**, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência, com base em critérios ou premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes, mas, em geral, reciprocamente complementares.

Ele aponta os seguintes métodos:

1.11.1.1. MÉTODO JURÍDICO OU HERMENÊUTICO CLÁSSICO

A Constituição deve ser encarada como uma lei. Em consequência, deve **o intérprete seguir diferentes elementos tradicionalmente usados** (genético, gramático ou filológico, lógico, sistemático, histórico, teleológico ou sociológico, popular, doutrinário e evolutivo) **para descobrir o verdadeiro significado e sentido da norma**.

1.11.1.2. MÉTODO TÓPICO-PROBLEMÁTICO

Este e o seguinte são, de longe, os mais cobrados! Um é o inverso do outro. Daí, com muito mais razão, é feita a troca que eu falei no comecinho de nossa conversa.

No tópico-problemático o intérprete deve partir de um problema concreto para a norma. Procura-se dar à interpretação um caráter prático, facilitando a solução dos problemas.

1.11.1.3. MÉTODO HERMENÊUTICO-CONCRETIZADOR

Aqui, como eu já anunciei, acontece o contrário do método tópico-problemático, que parte do caso concreto para a norma.

Em outras palavras, **no método hermenêutico-concretizador o intérprete parte da Constituição para o problema**, valendo-se de diferentes pressupostos interpretativos.

Os pressupostos são **subjetivos** (relativo ao papel criador do intérprete) e **objetivos** (inerentes às circunstâncias e o contexto no qual se desenvolve tal atividade). Vem daí a ideia de **círculo hermenêutico**, decorrente da relação entre o texto e o contexto.

Porém, tendo em vista que esse processo é contínuo e nunca se esgota ou se estabiliza, ele ocorre numa progressão sem fim, e acaba sendo representado por um formato espiral. Daí se fala na **espiral hermenêutica** de Gadamer.

Bernardo Gonçalves Fernandes pontua que não se perde de vista o texto constitucional, o qual ficaria ancorado como objeto principal em face do problema, um limite na concretização da norma constitucional. Assim, existiria uma primazia da norma sobre o problema.[82]

---

[82] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 202.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.11.1.4. MÉTODO CIENTÍFICO-ESPIRITUAL

Rudolf Smend desenvolveu o método científico-espiritual, segundo o qual a análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas **parte da realidade social** e dos valores subjacentes do texto da Constituição.

Nas palavras de Pedro Lenza[83], "a Constituição deve ser interpretada como **algo dinâmico** e que se renova constantemente, no compasso das modificações da vida em sociedade".

1.11.1.5. MÉTODO NORMATIVO-ESTRUTURANTE

Segundo seu criador (Friederich Müller), **não haveria identidade entre a norma jurídica e o texto normativo.**

Como defendem Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, "**a norma constitucional abrange um 'pedaço da realidade social'**; ela é conformada não só pela atividade legislativa, mas também pela jurisdicional e pela administrativa".[84]

1.11.1.6. MÉTODO DA COMPARAÇÃO CONSTITUCIONAL

Mais fácil, impossível! No método da **comparação constitucional**, a interpretação deve partir da **comparação de institutos jurídicos**, normas e conceitos nos vários ordenamentos jurídicos.

A partir dessa comparação, seriam alcançados diferentes critérios aplicáveis na busca da melhor solução para problemas concretos.

1.11.2. PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO

Além dos métodos acima listados, a interpretação da Constituição também é feita a partir da análise de alguns princípios, convencionalmente admitidos na doutrina.

1.11.2.1. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO

De acordo com essa regra, as normas constitucionais devem ser vistas não de maneira isolada, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios.

Deve-se, assim, afastar as **aparentes** antinomias. Canotilho ensina que o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar **harmonizar os espaços de tensão**.

Vou além! O professor Eros Grau sempre usava uma expressão genial, segundo a qual "a Constituição não pode ser interpretada em tiras".

---

[83] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 12. ed. São Paulo: Saraiva. p. 133.

[84] Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. *Direito constitucional descomplicado*. 3. ed. São Paulo: Método, 2008. p. 69.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXEMPLO

Quer um exemplo? Qual a idade para ser Presidente da Câmara dos Deputados?
Não há tratamento explícito na Constituição, mas a resposta só pode ser 35 anos. Isso porque, se por um lado é exigida a idade mínima de 21 anos para ser Deputado Federal, por outro o candidato deve lembrar que a Presidência da Câmara está na linha sucessória.

Em consequência, o ocupante da cadeira precisa preencher todos os requisitos para ser presidente da República, entre os quais se destaca a idade mínima de 35 anos.

1.11.2.2. PRINCÍPIO DO EFEITO INTEGRADOR (OU EFICÁCIA INTEGRADORA)

Significa que, para resolver os problemas jurídico-constitucionais, **deve o intérprete dar primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política**.

1.11.2.3. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE (OU INTERPRETAÇÃO EFETIVA OU EFICIÊNCIA)

Está ligado ao princípio da força normativa da Constituição. No princípio da máxima efetividade, os aplicadores do direito são orientados para que **interpretem as normas constitucionais de maneira a que elas tenham a mais ampla efetividade social**, sem alterar o conteúdo.

Nasceu junto às normas programáticas, mas hoje é também aplicado a todas as outras.

1.11.2.4. PRINCÍPIO DA JUSTEZA (OU CONFORMIDADE FUNCIONAL OU CORREÇÃO FUNCIONAL)

Estabelece que **o órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório-funcional estabelecido pelo constituinte originário**.

Classifica a Constituição como um **sistema coerente** e previamente ponderado de repartição de competências.

1.11.2.5. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA (OU DA HARMONIZAÇÃO)

O princípio da concordância prática está ligado ao princípio da unidade. Ele exige que **os bens jurídicos constitucionalmente protegidos possam coexistir de maneira harmoniosa**, sem predomínio de uns sobre os outros. Tem por fundamento a inexistência de hierarquia entre os princípios.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Seria uma recomendação para que o aplicador das normas constitucionais, ao se deparar com situações de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a solução que otimize a realização de todos eles, sem que isso acarrete a negação de nenhum[85].

1.11.2.6. PRINCÍPIO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO

Seria uma imposição (ou conselho) para que **os intérpretes da Constituição**, na solução dos problemas jurídico-constitucionais, **procurem dar preferência aos pontos de vista que, ajustando historicamente o sentido das suas normas, confiram-lhes maior eficácia**.

Não pode o intérprete reduzir a eficácia do texto constitucional, devendo, em verdade, conferir-lhe a máxima aplicabilidade.

1.11.2.7. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO

No caso de **normas plurissignificativas ou polissêmicas** (as que admitem mais de uma interpretação), deve-se dar preferência à interpretação que lhes compatibilize o sentido com o conteúdo da Constituição.

Se um dos sentidos da norma é compatível com a Constituição, deve o intérprete 'salvá-la'. Gilmar Mendes diz que **não pode o intérprete ser conduzido a salvar a lei à custa da Constituição**, nem tampouco a contrariar o seu sentido inequívoco, para constitucionalizá-la de qualquer forma[86].

Pela presunção de constitucionalidade das leis, deve o intérprete buscar a conservação da norma, sempre que possível.

Para Lenza, "não se aceita a interpretação conforme a Constituição quando, pelo processo de hermenêutica, se obtiver uma regra nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória, em seu sentido literal ou objetivo".[87]

A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é próxima à interpretação conforme, possuindo as seguintes semelhanças: podem ser utilizados tanto no controle difuso quanto no concentrado (art. 28, parágrafo único, da Lei 9868/99); ambas são técnicas de manipulação situadas dentro das sentenças intermediárias (subdivisão: sentenças normativas interpretativas); em ambas o texto permanece intocado; há uma redução do âmbito de aplicação da norma.

---

[85] Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 114.

[86] Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 119.

[87] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 12. ed. São Paulo: Saraiva. p. 137.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mas há diferenças: a interpretação conforme é um princípio interpretativo, do qual se extrai um **juízo positivo de constitucionalidade**. Já na declaração de **inconstitucionalidade** parcial sem redução de texto, como se pode ver, é feito um **juízo negativo de constitucionalidade**.

Daí se extrai uma importante consequência, muito explorada em provas de concursos: **a cláusula de reserva de plenário**, prevista no artigo 97 da Constituição, **só precisa ser observada na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto**.

Em sentido contrário, **para se aplicar a interpretação conforme à Constituição não há a necessidade de submeter o julgamento ao Plenário ou ao órgão especial do Tribunal**. A decisão pode partir de órgãos fracionários (turmas, câmaras ou seções).

A razão para isso está no fato de que as normas nascem com presunção (relativa) de constitucionalidade. Assim, para se afirmar a constitucionalidade de uma lei – lembre que a interpretação conforme faz um juízo positivo –, o órgão fracionário estaria 'chovendo no molhado'.

1.11.2.8. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (OU DA RAZOABILIDADE)

Muito cobrado nas provas e muito utilizado na prática, o princípio da proporcionalidade serve para fazer a ponderação de interesses no caso concreto quando duas normas constitucionais estiverem em choque.

Isso porque no Brasil não se aceita a teoria de inconstitucionalidade de normas originárias. Assim, havendo um choque entre duas normas constitucionais, uma cederá espaço para a outra, sem que se declare sua inconstitucionalidade.

É bom lembrar que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Em consequência, não dá para se estabelecer uma regra em que determinada norma sempre prevalecerá sobre a outra.

EXEMPLO

É comum que haja choque entre a liberdade de expressão e a intimidade da vida privada, até porque no seu papel constitucional de noticiar a imprensa por vezes invade a intimidade das pessoas.

Então, nessa situação, caso a caso será decidido qual dos dois valores constitucionais deverá prevalecer.

Avançando, **o princípio da proporcionalidade conta com três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito**.

Por outro lado, há doutrina **minoritária** defendendo que razoabilidade e proporcionalidade são princípios sinônimos, pois ambos seriam usados na ponderação de interesses.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Pois bem, embora eles sejam realmente usados na ponderação de interesses, existem diferenças entre eles. ***A primeira*** é que a razoabilidade é originária do direito norte-americano, enquanto a proporcionalidade vem do direito alemão.

A segunda é no sentido de que **a razoabilidade seria apenas um dos três subprincípios da proporcionalidade**, a proporcionalidade em sentido estrito.

Ah, é sempre bom lembrar que, mesmo sendo importantíssimos, **os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não constam explicitamente no texto constitucional**, sendo **princípios implícitos**.

1.11.3. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EM MATÉRIA DE HERMENÊUTICA

Alguns editais têm ido além, cobrando mais do que os princípios e métodos acima apresentados. Então, para você não ser pego de surpresa, vou organizar pontos importantes, com precisão cirúrgica, sem grandes divagações, na busca por otimizar sua preparação.

1.11.3.1. INTERPRETATIVISMO E NÃO INTERPRETATIVISMO

O **interpretativismo** congrega uma **visão mais conservadora** em matéria de interpretação constitucional, baseada na vontade originária do constituinte (**originalismo**) ou nos elementos contidos no texto constitucional (**textualismo**).

Citado por Marcelo Novelino, Frank Easterbrook defende que o Judiciário deve adotar o originalismo e o Legislativo deveria se pautar por uma visão mais pragmática.[88]

Acontece que uma parte dos interpretativistas vai na direção de que o juiz deve se limitar à aplicação do texto da Constituição, sem inovar perseguindo fins mais amplos do que aqueles previstos na literalidade do texto.

Por sua vez, o **não interpretativismo** opta por um **viés progressista**, baseado na adaptação do direito à realidade do seu tempo. O Judiciário teria papel de protagonista, acompanhando as mudanças sociais e a chegada de novos direitos.

1.11.3.2. PROCEDIMENTALISMO E SUBSTANCIALISMO

De saída, é importante lembrar que o Judiciário tem assumido importante protagonismo no cenário atual, tendo cada vez mais posição de destaque na solução de controvérsias que antes ficavam somente na esfera política.

Isso acontece, segundo Mônia Clarissa Hening Leal, porque dentro da teoria da Constituição Dirigente, surge o receio em deixar a concretização da Constituição a cargo da discricionariedade do legislador.[89]

---

[88] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 153.

[89] LEAL, Mônia Clarissa Hening. Dworkin x Habermas. Uma discussão acerca da legitimidade da jurisdição constitucional entre substancialismo e procedimentalismo: Novas Perspectivas. *A&C R. de Dir. Administrativo e Constitucional*, Belo

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Usarei como ponto de partida os pensamentos de Ronald Dworkin, expoente do substancialismo, e de Jünger Habermas, representando o procedimentalismo.

As duas teorias se prestam a explicar os diferentes graus de dirigismo que uma Constituição poderia adotar quando em jogo a implementação de direitos elencados na Constituição, em especial, os de 2ª geração/dimensão, que envolvem direitos sociais, de cunho prestacional.

Sempre que se fala nas possibilidades e nos limites da jurisdição constitucional, abrem-se duas frentes de atuação: na primeira, denominada de **substancialismo**, tem-se o modelo de Constituição Dirigente, desenvolvido por Canotilho. O professor português acredita num modelo constitucional no qual **o Judiciário exerceria papel mais amplo na consolidação dos direitos fundamentais**, zelando pela efetiva implementação dos direitos sociais.

A partir daí, seria legítima a **atuação mais incisiva do Judiciário**, inclusive na **determinação de implementar políticas públicas**, diante da inércia do Executivo em dar concretude às promessas da Constituição.

Na atualidade, vemos que são comuns decisões judiciais assegurando leitos em UTI, vagas em creches e pré-escola e até determinando a realização de reformas emergenciais em presídios.

Para justificar a atuação do Judiciário, Dworkin rebate as críticas de que o acesso ao Judiciário seria caro, restrito aos ricos. Ele diz o acesso ao Legislativo é ainda mais restrito, de modo que transferir algumas decisões retirando-as do Legislativo poderia ser mais valioso para os pobres.

Por outro lado, **os procedimentalistas acentuam o papel instrumental da Constituição e são mais avessos à ideia do ativismo judicial**, de modo que a implementação de políticas públicas não deve ficar a cargo do Judiciário. Ao contrário, **as deliberações ficariam na esfera de decisão política do Legislativo e do Executivo**, até mesmo diante do déficit democrático próprio do Poder Judiciário.

Surge daí a contestação relacionada a como seria possível que juízes, não eleitos pelo voto popular, poderiam controlar e anular leis elaboradas por um poder eleito para esse fim (Legislativo) e aplicadas por outro poder também eleito (Executivo).

Nesse cenário, **ao Judiciário caberia a função de garantir a observância das "regras do jogo democrático"**, cabendo à própria sociedade – por meio dos dirigentes eleitos – escolher quais direitos sociais implementar naquele momento (lembrando sempre que os recursos são finitos.

Porém, **mesmo no procedimentalismo, o Judiciário age na feição contramajoritária**, evitando que direitos de minorias sejam massacrados pela maioria.

Horizonte, ano 4, n. 17, p. 1-255, jul./set. 2004.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Avançando, é importante pontuar que os dois modelos não são excludentes entre si. Ao contrário, seriam interdependentes, enquanto espaços voltados para o exercício e a ampliação da democracia.

1.11.3.3. TEORIA DO REFORÇO DA DEMOCRACIA

Baseia-se na ideia do jurista **John Hart** Ely, no livro *Democracy and distrust.* O autor segue a **corrente procedimentalista**, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito das escolhas feitas pelos poderes públicos, eleitos democraticamente.

A atuação, ao contrário, seria para **evitar desvirtuamentos**, assegurando a participação de todos. Os representantes eleitos devem ditar os rumos do Estado, **com a interferência judicial autorizada sempre que houver violação das regras democráticas**.

1.11.3.4. CÍRCULO OU ESPIRAL HERMENÊUTICA DE GADAMER

Na sua obra principal, *Verdade e Método*, Hans-Georg **Gadamer** pontua que não seria possível isolar o intérprete do objeto hermenêutico.

Em suas palavras, "não existe compreensão que seja livre de todo pré-conceito, por mais que a vontade do nosso conhecimento tenha de estar sempre dirigida, no sentido de escapar ao conjunto de nossos pré-conceitos".[90]

Fernando Ribeiro e Bárbara Braga pontuam que a compreensão que se realiza mediante um diálogo hermenêutico implica fundir o horizonte do intérprete com o horizonte daquele que é interpretado. Eles ainda destacam que **a verdade de um texto não estaria na submissão incondicionada à opinião do autor, nem apenas nos preconceitos do intérprete**, mas na fusão dos horizontes de ambos.[91]

Ao fim e ao cabo, texto e intérprete passam a dividir um horizonte comum, a partir de uma fusão de horizontes.

Mas em provas não é incomum se ouvir alusão ao círculo ou espiral hermenêutica de Gadamer. O que seria isso?

Rodolfo Viana Pereira define que:

> o **círculo hermenêutico** ocorre no instante em que **o sujeito**, através de sua pré-compreensão, **participa na construção do sentido do objeto** (moldado por tais preconceitos), a passo que **o próprio objeto**, no desenrolar do processo hermenêutico, **modifica a compreensão do intérprete**.[92]

---

[90] GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método*. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 709.

[91] BRAGA, B. G. A.; Ribeiro, F.J.A. A aplicação do Direito na perspectiva hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. *Revista de Informação Legislativa*, v. 45, p. 272.

[92] PEREIRA, Rodolfo Viana. *Hermenêutica filosófica e constitucional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 35.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Porém, tendo em vista que esse processo é contínuo e nunca se esgota ou se estabiliza, ocorrendo numa progressão sem fim, acaba sendo representado por um formato espiral. Daí se fala na **espiral hermenêutica** de Gadamer.

1.11.3.5. MINIMALISMO E MAXIMALISMO

Cass Sunstein divide as decisões judiciais em dois tipos: **minimalistas** e **maximalistas**.

As primeiras seriam mais superficiais e estreitas (sem formulação de regras gerais e teorias abstratas), voltadas a solucionar litígios particulares, sem a pretensão de salvar o planeta a partir de teses discutidas em suas sentenças.

Bernardo Gonçalves lembra que, segundo a lição de Sunstein, os magistrados deveriam entender que não possuem necessidade ou legitimidade em discutir questões que não possam ser consideradas essenciais para a resolução do caso sob sua análise.[93]

Reunindo as vantagens do minimalismo, Novelino aponta, entre outras, a redução dos encargos das decisões judiciais, a diminuição do risco de erro judicial, a maior flexibilidade para decisões futuras.[94]

Por outra via, no maximalismo, teríamos decisões marcadas pela profundidade e amplitude. As decisões maximalistas estabeleceriam regras gerais para o futuro, sendo carregadas de justificativas teóricas ambiciosas.

Quando proferidas por uma corte constitucional, esse tipo de decisão tornaria o direito mais previsível, reduzindo decisões equivocadas ou contraditórias nas outras instâncias.

A decisão maximalista seria apropriada para situações nas quais o funcionamento do processo democrático não estivesse adequado, ou ainda quando houvesse desconfiança nas outras instituições e naquelas marcadas pela necessidade de antecipado planejamento.

Deixando clara sua **preferência pelo minimalismo judicial**, Cass Sunstein indica que ele seria a proposta de retomada do papel que o Judiciário deveria ocupar em um Estado que se considera democrático.[95]

1.11.3.6. TEORIA DA INTEGRIDADE

Certamente você já ouviu falar sobre **Ronald Dworkin** em assuntos variados, como na distinção entre regras e princípios.

Aqui, vou falar um pouquinho de sua **Teoria da Integridade**. Usando a metáfora de um romance, cada decisão judicial seria um capítulo da obra, de modo que o direito poderia ser visto como um empreendimento coletivo.

---

[93] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 202.

[94] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 154.

[95] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 201.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Decisões passadas influenciam a de hoje, assim como estas influenciarão as que estão por vir. Isso leva à constatação de que "o juiz está não apenas vinculado ao passado, àquilo que já foi decidido sobre o tema, mas tem a responsabilidade de influenciar as decisões futuras".[96]

1.12. HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

História, Política e o Direito Constitucional andam sempre de mãos dadas. Aliás, é bem verdade que, entre o fato histórico e a repercussão no Direito Constitucional pode haver um *delay*, algo que varia entre meses e poucos anos.

Exemplificando, quando em 2013, em meio à Copa das Confederações, foram deflagradas inúmeras manifestações Brasil afora, especialmente nas grandes Capitais.

Se você bem lembra, o motivo que deu início às manifestações era o descontentamento popular com o anúncio de aumento de R$ 0,20 no preço das passagens de ônibus e de trens/metrôs – ou seja, **transporte coletivo urbano**, certo?

Àquela altura se dizia que "o gigante acordou", lembra? **Mas afinal, quem é esse gigante?**

Não há dúvidas de que **o gigante é o povo**, o dono do Poder (todo poder emana do povo).

Voltando às manifestações, elas giravam em torno da redução do custo do transporte coletivo. Entre o início dos movimentos (meados de 2013) e a promulgação da EC n. 90/2015 se passaram cerca de dois anos.

E o que fez a **EC n. 90/2015? Inseriu o transporte entre os direitos sociais elencados no artigo 6º da Constituição**.

É óbvio que não houve mera coincidência. A partir das queixas generalizadas, o Legislativo movimentou-se e promulgou a **PEC do Transporte**, buscando atender ao anseio popular.

Está bem, mas agora é hora de fazer algumas pontuações entre os contextos históricos e políticos relacionados a cada uma das Constituições brasileiras. Vou começar lá na Constituição de 1824, chegando ao cenário social que deu ensejo à promulgação da Constituição Cidadã.

Vamos lá!

1.12.1. CONSTITUIÇÃO DE 1824

No ano de **1822**, mais precisamente no dia 7 de setembro, foi **proclamada a independência** de nosso país.

Levando-se em conta que a Constituição é a norma de maior envergadura no ordenamento jurídico, era necessário que os detentores do poder buscassem se legitimar, escrevendo a Carta Magna de nossa nação, agora independente.

É nesse contexto que nasce, em **1824**, a **primeira Constituição brasileira**, a "Constituição Política do Império do Brazil".

---

[96] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 422.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A Constituição de 1.824 foi **outorgada** e nela se previa a **existência de quatro Poderes:** Executivo, Legislativo, Judiciário **e Moderador**.

Àquela época, adotávamos a **Monarquia** como forma de governo e o **Estado unitário**, como forma de Estado.

Quanto ao sistema de governo, **num primeiro momento** (D. Pedro I), foi adotado o **presidencialismo**. Mais à frente, como D. Pedro II ainda era muito jovem – o Príncipe Regente – **passou-se para o parlamentarismo**.

A **religião católica** era tida como "a Religião do Império", embora todas as outras religiões fossem permitidas, com seu culto doméstico, ou particular em casas destinadas a esse fim, desde que não houvesse representação exterior de templo.

As capitanias hereditárias foram transformadas em províncias. O Rio de Janeiro, município neutro, era a Capital do Império.

Naquela época a nossa **Constituição era semirrígida**, ou seja, a parte materialmente constitucional previa procedimento mais rigoroso de alteração. Já as normas apenas formalmente constitucionais eram modificadas por um procedimento mais simples, equivalente às normas infraconstitucionais.

Mas aí vai uma informação importante: **nossa primeira Constituição também era imutável**. Como assim? A imutabilidade era dentro dos **primeiros quatro anos** de seu nascimento.

Àquela época, **nada se falou em controle de constitucionalidade**, seja difuso ou concentrado.

Quanto aos remédios constitucionais, não havia previsão do *habeas corpus* (inserido em 1830, com o Código Criminal de Império). Por outro lado, lá estava a ação popular, quando se previu que "**qualquer do povo**" poderia movê-la com a fim de reprimir abusos de poder ou prevaricação.

O artigo 157 da Constituição de 1824 previa o seguinte: **"**Por suborno, peita, peculato e concussão **haverá contra eles a ação popular**, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecido na lei".

As eleições para o Legislativo eram indiretas.

Foi então que, no ano de **1889**, se **proclamou a República**. Em consequência, havia a necessidade de se elaborar uma nova Constituição. Nesse diapasão, foi promulgada, em **1891**, a "Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil".

1.12.2. CONSTITUIÇÃO DE 1891

Muita atenção para esta Constituição. Ela é a mais importante, afora a Constituição de 1988.

Escrita sob a influência de Rui Barbosa, o maior jurista brasileiro de todos os tempos, **a Constituição de 1891 foi promulgada** e promoveu grandes modificações no Brasil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Ah, um ponto importante: Rui Barbosa estudou nos Estados Unidos, trazendo de lá todas as ideias para serem aqui implementadas. Não entendeu? Veja:

A **segunda** Constituição brasileira adotou a **Federação** como Forma de Estado e também a **República** como forma de governo.

Além disso, o sistema de governo voltou a ser o **Presidencialismo** e foi **extinto o Poder Moderador**.

As antigas províncias foram transformadas em estados, enquanto o antigo município neutro deu lugar ao **Distrito Federal**, definido como **Capital da União** – mas situado no Rio de Janeiro – a primeira Lei Orgânica do DF é de 1892.

O texto de 1891 também **rompeu com a ideia de religião oficial**, dissociando o Estado da Igreja. Havia expressa previsão no sentido de que nenhum culto ou Igreja gozaria de subvenção oficial.

Àquela época, foi **introduzido o controle difuso de constitucionalidade** (concebido nos EUA, em 1.803, no caso Marbury vs Madison). No mundo, o controle concentrado só nasceria muito tempo depois, com a Constituição da Áustria, de 1.920.

Falando no Judiciário, há seu fortalecimento, com a criação da Justiça Federal e da Justiça dos Estados, além do Supremo Tribunal Federal, a quem se dava a competência para a declaração de inconstitucionalidade das leis.

Com inspiração democrática, ela é promulgada trazendo uma ampliação do rol dos direitos individuais.

O remédio constitucional do **habeas corpus** foi incorporado à Constituição. Como você viu, ele nasceu com o Código Criminal do Império, de 1830 – portanto, após a Constituição de 1824.

1.12.3. CONSTITUIÇÃO DE 1934

A **Revolução de 1930** depôs o então presidente da República, Washington Luís, e alçou Getúlio Vargas à chefia do Governo Provisório. Como consequência histórica, foi **promulgada**, em **1934**, a **terceira** Constituição brasileira.

Ela foi marcada pela introdução dos **direitos sociais**, de segunda dimensão/geração. Isso inegavelmente é fruto do movimento internacional, iniciado com a Constituição do México de 1917 e continuado com as Constituições da Áustria e da Alemanha (Weimar).

A Constituição também previa o voto indireto para **parlamentares classistas**.

Nessa época também nasceu o **quinto constitucional**. Houve a **introdução do mandado de segurança e da ação popular**, somando-se ao habeas corpus.

Houve uma reaproximação entre o Estado e a Igreja, com o reconhecimento do casamento religioso com efeitos civis e a incorporação do ensino religioso nas escolas.

O Distrito Federal, por sua vez, deixa de ser tratado como Município para receber autonomia equivalente à dos Estados.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Outro ponto importante foi a extensão do voto também às mulheres. No Legislativo, tínhamos um bicameralismo desigual, com o Senado em um papel menor diante da Câmara.

No âmbito do controle de constitucionalidade, **surge a primeira ferramenta do controle concentrado, a ADI Interventiva**.

Houve ainda um **fortalecimento do controle difuso**, com a incorporação de ferramentas hoje verificadas nos artigos 52, X, e 97 da Constituição – respectivamente, possibilidade de o Senado suspender no todo ou em parte norma declarada inconstitucional pelo STF e a cláusula de reserva de plenário.

A Constituição de 1934 marca a introdução do mandado de segurança e o retorno da ação popular, em roupagem mais semelhante à atual.

1.12.4. CONSTITUIÇÃO DE 1937

A Constituição de 1934 teve vida curta. Isso porque, em **1937**, Getúlio, inspirado no modelo fascista de Antônio Salazar, implanta a **ditadura do Estado Novo**, **outorgando** a **quarta** Constituição de nosso país.

A sua principal característica era a grande concentração de poderes nas mãos do Chefe do Executivo. Essa Constituição é também conhecida pelo nome de **Polaca**, em virtude de ter-se baseado na autoritária Constituição da Polônia.

Nessa época, Vargas promove uma **série de medidas ditatoriais**, decretando estado de sítio e estado de guerra em alguns momentos.

Além disso, houve o **fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas**. Por outra frente, ele instituiu os **decretos-leis**, acumulando funções de Executivo e do Legislativo.

Enfraquecendo o Poder Judiciário, ele previu a possibilidade de o presidente da República enviar as decisões judiciais para serem revistas pelo Legislativo (já reaberto).

O artigo 96 da referida Constituição dizia que no caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei, o presidente da República, considerando "o bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta", poderia submeter a decisão novamente ao exame do parlamento, o qual poderia sustar a decisão do Tribunal por 2/3 dos votos de cada uma das Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Conselho Federal = Senado).

Essa regra é também chamada de "**Cláusula não Obstante**" (ou *notwithstanding clause,* ou *non-obstante,* ou *override clause*), originária da experiência constitucional canadense.

Dentro do controle de constitucionalidade, some a ADI Interventiva.

O controle difuso até foi mantido, mas sem a cláusula de reserva de plenário e a possibilidade de o Senado suspender norma declarada inconstitucional pelo STF (aliás, nem havia Senado, substituído pelo Conselho Federal).

Não para por aí: os Estados tiveram sua autonomia reduzida, e os direitos de greve e de *lockout* foram proibidos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Mandado de segurança e ação popular saem da Constituição, mas retornam em 1946 e permanecendo nos demais textos, incluindo o de 1988, quando teve seu objeto alargado.

1.12.5. CONSTITUIÇÃO DE 1946

Com a **queda de Getúlio** e o fim do Estado Novo, em **1945**, foram realizadas eleições e a Assembleia Nacional Constituinte finda por **promulgar**, em **1946**, a **quinta** Constituição brasileira. Esta Constituição, com forte avanço democrático, trouxe de volta direitos e garantias suprimidos pela Constituição de 1937.

No âmbito do Legislativo, há o retorno para o **bicameralismo igual**. O vice-presidente da República exercia as funções de Presidente do Senado, previsão equivalente à que constava na Constituição de 1891, em clara inspiração ao modelo norteamericano.

Dentro dos direitos fundamentais, é instituída a proibição de pena de morte (salvo guerra), de banimento, de confisco e de caráter perpétuo.

No tocante ao controle de constitucionalidade, ela restaurava em larga medida as regras da Constituição de 1934, **acabando com a revisão constitucional que você viu anteriormente na Constituição Polaca** (apelido "carinhoso" da Constituição de 1937, inspirada na Constituição da Polônia).

Deu nova roupagem à representação interventiva (ausente no texto anterior), aproximando-a ainda mais ao que conhecemos hoje. A decretação de intervenção estava subordinada à declaração de inconstitucionalidade do ato pelo STF.

Voltam a cláusula de reserva de plenário e o poder de o Senado suspender, no todo ou em parte, normas declaradas inconstitucionais pelo STF.

O ponto alto da Constituição de 1946 está em uma emenda... é que **a EC n. 16/1965 introduz no cenário brasileiro a Ação Direta de Inconstitucionalidade**, **principal ferramenta do controle concentrado de constitucionalidade**. Àquela época (e até 1.988) somente o PGR era legitimado para ingressar com a ADI.

Uma curiosidade: havia a previsão de eleição para Vice-Presidente (não era o esquema do "pague um e leve dois"). João Goulart, conhecido como Jango, era o Vice de Juscelino Kubistchek.

Com o fim do mandato de JK, Jânio Quadros se torna Presidente e Jango novamente é eleito como Vice. Contudo, com a renúncia de Jânio Quadros, Jango assume a Presidência da República.

Nesse período, buscando enfraquecer a figura do Presidente, é instalado o sistema **parlamentarista** de governo, com a figura do Primeiro-ministro, papel exercido por Tancredo Neves.

Jango, muito querido pelo povo, realiza **plebiscito em 1963**, sendo escolhido **o retorno do presidencialismo** na ocasião.

Insatisfeitos, alguns grupos se aliam aos Militares e decretam o Golpe de 1964.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1.12.6. CONSTITUIÇÃO DE 1967

O **Golpe Militar** de **1964** derrubou o governo de João Goulart e instituiu nova ditadura em nosso país, desta vez inspirada nos modelos latino-americanos. Foi elaborada, então, a **sexta** Constituição brasileira, no ano de **1967**.

Ela foi **outorgada**, muito embora tenha sido submetida ao Congresso Nacional. O que aconteceu na prática é que o Congresso não tinha liberdade para alterar substancialmente o texto, atuando como figurante para legitimar o regime ditatorial implantado.

Recheado de Atos Institucionais, verdadeiros mecanismos de demonstração de força do regime, o período contou com uma restrição a direitos e garantias fundamentais.

No campo político, houve um enfraquecimento da Federação, que mais se aproximava de um Estado Unitário. Havia apenas dois partidos políticos: a ARENA e o MDB.

O Judiciário e o Legislativo tiveram suas competências enfraquecidas. O DF continuou sendo a Capital do Brasil, mas já funcionando no local de hoje em dia.

1.12.7. CONSTITUIÇÃO DE 1969 (EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 1/1969)

Há certa divergência doutrinária se a **Emenda Constitucional n. 1/1969** seria, de fato, uma emenda ou uma nova Constituição.

Isso porque ela tem forma de EC, mas foi uma mudança tão profunda que teria significado uma nova Constituição.

Partindo-se da premissa de que seria uma Constituição, não há dúvidas de que, quanto à origem, ela seria classificada como **outorgada**, uma vez que é fruto do AI-5, maior demonstração de força do regime ditatorial.

Aliás, havia a previsão segundo a qual **os atos praticados com base no AI-5 não poderiam ser questionados perante o Judiciário**.

Nesse período houve uma restrição ainda maior dos direitos fundamentais, com a possibilidade de suspensão de direitos políticos por até dez anos, além de cassação de mandatos eletivos.

No Parlamento, havia Senadores biônicos, nomeados e não eleitos.

Em 1977 o "Pacote de Abril" trouxe novidades, como era o caso da exigência de apenas maioria absoluta para emendar a Constituição – antes, o quórum era de 2/3.

Mas a decadência do regime militar começou a se desenhar mais fortemente com o "**Pacote de 1978**". Nele houve a revogação total do AI-5 e também a suspensão das medidas tomadas com base nele, como é o caso da cassação de direitos políticos.

Seguiu-se, em **1979**, a **Lei da Anistia** (Lei n. 6.683/1979). Ela anistiava todos os crimes políticos e conexos praticados entre 1961-1979.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Um parêntese: não há dúvidas de que durante o regime militar foram praticados, de parte a parte, diversos crimes, destacando-se homicídios qualificados e tortura, entre outros hediondos ou equiparados.

Em razão disso, no ano de 2010, o STF foi chamado a julgar uma ADPF que questionava a anistia conferida no ano de 1979, **aparentemente** contrária ao texto constitucional em vigor – o nosso artigo 5º diz que os crimes hediondos ou equiparados são insuscetíveis de graça ou anistia.

Julgando a ação, o Tribunal entendeu pela **validade da anistia, que seria ampla, geral e irrestrita**. Na ocasião, firmou-se a tese de que a lei de anistia era considerada uma "lei-medida", que deve ter sua constitucionalidade aferida de acordo com o contexto político da época de sua edição (STF, ADPF 153).

Fecho o parêntese.

Com a anistia, certamente muitas das cabeças pensantes no cenário político-jurídico brasileiro, que estavam asiladas em outros países, puderam retornar. Seguiram-se, então, intensas movimentações.

Ainda em 1979, a **Reforma Partidária** permitiu o **pluripartidarismo partidário**, acabando com a dicotomia "Arena-MDB". Surgem aí outras legendas, como PSDB, PL, PDT, PT, PP, PTB etc.

No período de 1984-85 ganhou força no Brasil o movimento que pedia a realização de eleições diretas para a escolha de presidente da República ("**Diretas já!**"). No entanto, a "PEC Dante de Oliveira" (eleições diretas) foi rejeitada.

Foi, então, eleito indiretamente **Tancredo Neves**. Porém, ele **morreu** dias antes de tomar posse. Em seu lugar, **assumiu José Sarney**, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, por meio da EC n. 26/1985.

Talvez em suas provas (objetiva, subjetiva ou até mesmo a oral), você se depare com o **questionamento se a Constituição de 1988 seria mesmo manifestação do PCO**.

Isso se deve ao fato de a convocação da Assembleia Nacional Constituinte ter acontecido por meio da **EC n. 26/1985**, proposta pelo então presidente José Sarney. Ele havia elaborado um anteprojeto a partir dos trabalhos da chamada **Comissão Afonso Arinos**, composta por grandes personalidades da época. Porém, esse anteprojeto não chegou a ser apresentado ao Congresso, ante a manifestação de contrariedade de Ulysses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte.

Outra objeção colocada seria o fato de o trabalho ter sido feito por **parlamentares não eleitos exclusivamente** para elaborar a nova Constituição. Tem mais: o poder constituído poderia convocar a manifestação do poder constituinte?

Seja como for, **esse entendimento é minoritário**. Quando o assunto foi discutido no STF, o ministro Gilmar Mendes pontuou que o Congresso Nacional de 1985 atuou como um poder constituinte especial, pois colocou no mesmo texto a convocação da constituinte e

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

suas condições de realização. Seria, pois, um peculiar ato constitucional, não tendo natureza própria de emenda constitucional. Ao contrário, deveria ser considerado um ato político que rompeu com a Constituição anterior, dela não fazendo parte, material ou formalmente (STF, ADPF 153).

Assim, para as provas **prevalece a orientação de que a Constituição de 1988 é fruto legítimo e autêntico do poder constituinte originário**, rompendo com a ordem constitucional anterior, fruto do regime militar.

A Assembleia Nacional Constituinte elaborou o texto que veio a ser promulgado em 5/10/1988 e recebeu o nome de **Constituição Cidadã**.

Está aí, meu(minha) amigo(a), uma passagem rápida pela nossa história, mas que certamente vai ajudá-lo nas provas que você venha a fazer!

1.13. CONCEITOS QUE VOCÊ PRECISA SABER

Na doutrina moderna, nós vemos uma série de conceitos que vez ou outra rondam os editais para concursos jurídicos. Vou tentar sintetizá-los e apresentá-los de uma forma mais didática.

Fala-se em **Constitucionalismo do Futuro**. Embasado na doutrina do professor argentino José Roberto Dromi, Marcelo Novelino pontua que "o constitucionalismo do futuro está no equilíbrio entre as concepções dominantes do constitucionalismo moderno e os excessos praticados no constitucionalismo contemporâneo".[97] Ele ainda aponta alguns valores fundamentais que devem permear as Constituições daqui para a frente: verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalidade. A título ilustrativo, o valor verdade excluiria das constituições promessas impossíveis de serem realizadas.

Pedro Lenza destaca, de outro giro, que o constitucionalismo do futuro terá de trabalhar na consolidação dos direitos de terceira geração/dimensão, "incorporando à ideia de constitucionalismo social os valores do constitucionalismo fraternal e de solidariedade, avançando e estabelecendo um equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e alguns excessos do contemporâneo".[98]

Temos também o **Constitucionalismo Popular**, dentro do qual se busca limitar a supremacia judicial, colocando o povo como protagonista da doutrina constitucional. Parte-se da ideia de tirar do Judiciário o papel de dar a palavra final em relação à interpretação da Constituição. A ideia foi originalmente desenvolvida por Mark Tushnet, crítico do *judicial review.*

[97] NOVELINO. Marcelo. *Curso de direito constitucional.* 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pág. 60.

[98] LENZA, Pedro. *Direito constitucional esquematizado*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 53.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Em contraponto ao Constitucionalismo Popular, nasce o **Constitucionalismo Popular Mediado**, que tem como expoente Barry Friedman. Para ele, o poder exercido pelas Cortes Constitucionais – ou Suprema Corte, no caso dos EUA – não seria exercido de forma isolada ou distante da opinião pública. Ao contrário, como bem lembra Eduardo dos Santos[99], o controle de constitucionalidade teria limites que são impostos pela opinião pública e pela política, de modo que as decisões judiciais não são alheias à sociedade, sendo por ela pressionadas e ajustadas.

Há ainda o **Constitucionalismo Autoritário**. Nele, os ocupantes do poder o exercem de forma autoritária, despistando seus atos com um discurso constitucionalista, dando aparência de democracia constitucional[100].

Como uma coisa puxa a outra, vem o **Constitucionalismo Abusivo**, no qual há o uso de **mecanismos de mudança constitucional para fazer um Estado menos democrático**. Flávio Martins[101] indica que esse fenômeno tem sido frequente em alguns **países que vivenciam uma crise democrática e institucional**. Ele aponta exemplos como a Rússia, que prolongou até 2036 a possibilidade de Vladimir Putin se perpetuar no poder. Na América Latina, temos o exemplo da Venezuela de Hugo Chavez. Dentro da realidade brasileira, o autor descreve a EC n. 16/1997, que permitiu a reeleição de FHC numa época em que o chefe do Executivo só tinha direito a um mandato.

O conceito de **Patriotismo Constitucional** está ligado a uma leitura contemporânea da Teoria do Poder Constituinte e ao abandono do nacionalismo arcaico (carregado de xenofobia), passando a desenvolver o **reconhecimento inclusivo**, de união entre cidadãos, mesmo que sejam diferentes étnica e culturalmente.

Ao contrário do que o nome possa sugerir, patriotismo não tem nada de nacionalismo. Ao contrário, ele busca se afastar do nacionalismo extremado, exatamente aquele ligado à xenofobia e que levou ao holocausto. Pode-se aliar o nacionalismo a uma visão excludente de minorias culturais.

A ideia do patriotismo vem para superar as marcas deixadas pelo nazismo na memória do próprio povo alemão. Nas palavras de Vinícius Silva Bonfim, o patriotismo vem como uma forma de legitimar a democracia a partir de uma consciência histórica, a qual possibilita conflitos de interpretação sem excluir qualquer cidadão.[102]

Assim, haveria uma substituição do nacionalismo pelo patriotismo, passando-se do Estado-nação para o Estado democrático de direito.

---

[99] SANTOS, Eduardo dos. Manual de direito constitucional. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2025.

[100] MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 124.

[101] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, 125.

[102] BONFIM, Vinícius Silva. O patriotismo constitucional na efetividade da Constituição. *Revista CEJ*, Brasília, ano XIV, n. 50, p. 11-17, 2010.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Bernardo Gonçalves Fernandes pontua que nas sociedades plurais a identidade coletiva está mais ligada à convivência sob os mesmos valores do Estado democrático de direito e menos a questões como homogeneidade cultural (própria dos conceitos anteriores acerca do poder constituinte).[103]

Outro grande estudioso do tema, Álvaro Ricardo de Souza Cruz defende que o **sistema de direitos** decorrente do patriotismo constitucional garantiria as autonomias pública e privada dos cidadãos, abarcando uma cultura política pluralista.[104]

Porém, Flávio Martins pontua que o cenário atual, permeado por crises econômicas, crises migratórias decorrentes da guerra e da pobreza, enfraqueceram o patriotismo constitucional. Gerou-se a partir daí uma crescente onda conservadora, protecionista e em alguma medida xenofóbica.

O autor ainda defende que devemos aplicar, em nosso país, o patriotismo republicano, considerando nossas peculiaridades históricas, marcadas por multiculturalismo e pela diversidade cultural, religiosa, lembrando que o pluralismo político é um dos fundamentos de nossa República.

Embora se possa cogitar choque entre o movimento transnacional contemporâneo e o patriotismo constitucional, Martins esclarece que não há incompatibilidade, e sim transformação. Isso porque o poder transformador da Constituição seria visto num contexto cosmopolita e supranacional. Aliás, essa consciência cosmopolita teria Habermas como um dos grandes entusiastas.[105]

Há, ainda, o **Constitucionalismo termidoriano, *whig* ou gerondino.**

Flávio Martins lembra que o constitucionalismo termidoriano (expressão de origem francesa) tinha caráter conservador e reacionário, procurando proteger a grande propriedade privada e conter os reclamos das maiorias populares. Esse movimento foi liderado pelos girondinos na França, daí o nome de "constitucionalismo girondino".[106]

Por sua vez, o Constitucionalismo Whig estaria ligado aos limites dos poderes do governante e à tentativa de limitar a monarquia, dando papel de destaque à Assembleia Legislativa.

Ainda segundo Martins[107], há doutrinadores que entendem haver pontos de interseção entre os Constitucionalismos Whig e Termidoriano, na medida em que em ambos o processo de mudança de regime político-constitucional seria lento e evolutivo, mais do revolucionário e radical, dando ensejo ao que hoje conhecemos como transições constitucionais.

---

[103] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 48.

[104] SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo de. Poder Constituinte e patriotismo constitucional. *In*: GALUPP, Marcelo Campos. *O Brasil que queremos: reflexões sobre o Estado Democrático de Direito.* Belo Horizonte: PUC Minas, 2006. p. 90.

[105] MARTINS, Flávio. *Curso de direito constitucional*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 139.

[106] MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 108.

[107] Op. cit. p. 109.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Avançando, Christine Peter da Silva trata do **Constitucionalismo Feminista**, pontuando ser ele uma teoria constitucional que oferece os conceitos e ferramentas jurídicas necessárias para a efetivação de uma Constituição que seja "de e para" mulheres.[108]

A ideia central é tratar de isonomia e de inclusão, com respeito ao papel da mulher, assegurando-lhe o exercício pleno de sua cidadania constitucional.

Parte-se do pressuposto de que o constitucionalismo deve poder refletir acerca da máxima efetividade dos direitos fundamentais de todas as cidadãs e cidadãos, inserindo-as no centro das decisões de grande repercussão social.

Christine ainda associa a teoria do impacto desproporcional às premissas do constitucionalismo feminista, por entender que, em situações específicas, a concretização de uma lei acaba por atingir negativamente alguns grupos específicos, causando-lhes prejuízos. A autora cita decisões do STF, a exemplo da que entendeu pelo descabimento de incidência do IR nas pensões alimentícias (ADI 5.422), destacando que no mais das vezes, diante da dissolução da sociedade conjugal, a guarda dos filhos fica a cargo da mãe. Antes da decisão judicial, as mães acabavam sendo prejudicadas por ter o valor da pensão alimentícia diminuído ante a incidência da pesada carga tributária[109].

No que se refere ao **Constitucionalismo Negro**, citado em principalmente em editais de concursos para Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, tem-se a busca por colocar o negro como sujeito ativo da história. Eduardo dos Santos[110] lembra que o marco inicial seria a Revolução Haitiana, que teria influenciado as lutas por liberdade e igualdade racial. Aqui, as lutas principais são contra o racismo estrutural e o colonialismo.

Já o conceito de **Constitucionalismo Ambiental ou Ecológico** diz respeito à necessidade de se incluir o debate ambiental dentro da Constituição, conferindo maior proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. A Constituição de 1988 deu um passo nessa direção, quando regulou o Meio Ambiente em capítulo próprio da Ordem Social. De igual modo, o STF, quando reconheceu que todos tratados internacionais versando sobre direito ambiental devem ser considerados de direitos humanos e, consequentemente, gozando de status superior (supralegal ou constitucional, a depender da forma de incorporação ao direito brasileiro) – ADPF n. 718.

Da professora Catarina Santos Botelho veio a expressão **Narcisimo Constitucional**, segundo a qual os fundadores da Constituição seriam como pais superprotetores ("pais helicóptero"). Partindo da premissa de que a sua obra seria perfeita e acabada, inserem um número exagerado de cláusulas pétreas, a fim de impedir que aqueles temas sejam

---

108 SILVA, Christine Peter da. Constitucionalismo feminista pressupõe teoria do impacto desproporcional. Revista Consultor Jurídico, 17 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-dez-17/observatorio-constitucional-constitucionalismo-feminista-igualdade-substancial-genero>.

109 MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 108.

110 SANTOS, Eduardo dos. Manual de direito constitucional. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2025, pág. 140.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

alcançados por reformas constitucionais. Ela vai além, dizendo que o número excessivo de cláusulas pétreas pode ser nocivo ao Estado de Direito, gerando instabilidade institucional[111] .

Lênio Streck fala em um **Panconstitucionalismo**, movimento caracterizado pela constitucionalização em excesso, com a inclusão, na Constituição, de um grande plexo de matérias que deveriam ser reguladas pelo legislador, como é o caso do tratamento atinente a infância e adolescência, sistema tributário, direitos econômicos e empresariais etc.[112]

Ele cita também o panprincipiologismo, destacando a existência de uma usina de produção de princípios sem normatividade, exemplificando com os princípios "da cooperação processual", da "proibição do atalhamento constitucional", do "deduzido e do dedutível", da "proibição do desvio de poder constituinte", da "parcelaridade", da "verticalização das coligações partidárias", "da felicidade", entre outros.

Em sua visão, a existência de um grande leque de princípios é natural, mas não a sua vulgarização. É aí que reside a crítica do doutrinador. Em sua obra *Verdade e Consenso*, é feito um apanhado com mais de quarenta princípios, segundo ele, construídos de forma voluntarista por juristas descomprometidos, em sua maioria, com a deontologia do direito.

De Marcelo Neves – também responsável pelo conceito de Transconstitucionalismo – vem a expressão **Constituição Simbólica**, usada para definir aquela marcada pelo predomínio ou hipertrofia da função simbólica (caráter essencialmente político-ideológico) em detrimento da função jurídico-instrumental (de caráter normativo-jurídico).[113]

Haveria **dois sentidos no simbolismo**, um negativo e outro positivo. No negativo, haveria uma deficiência de concretização jurídico-normativa do texto constitucional, perdendo a capacidade de orientação generalizada das expectativas normativas. Por outro lado, no sentido positivo, ela serve para mascarar problemas sociais, impedindo transformações verdadeiras na sociedade.

Daí vem também o conceito de **legislação-álibi**, surgida para responder a um determinado problema, dando a impressão de que o poder público está capacitado para prontamente resolvê-lo.

Daniel Sarmento e Cláudio Neto acrescentam que a Constituição Simbólica **não corresponde minimamente à realidade**, não conseguindo subordinar as relações políticas e sociais subjacentes. Fazendo um paralelo com a classificação ontológica de Constituição, desenvolvida por Karl Lowestein, indicam a proximidade com a Constituição nominal ou nominalista.[114]

---

[111] MARTINS, Flávio. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 160.

[112] STRECK, Lenio Luiz. O problema da decisão jurídica em tempos pós-positivistas. *Revista Eletrônica – Novos Estudos Jurídicos*, v. 14, n. 2, 2º quadrimestre de 2009, p. 3-26.

[113] NEVES, Marcelo. *Constitucionalização Simbólica*. São Paulo: Acadêmica, 1994.

[114] SARMENTO, Daniel; NETO, Cláudio Pereira de Souza. *Direito Constitucional. Teoria, Tópicos e Métodos de Trabalho*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 65.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vou falar um pouquinho sobre **Solipsismo Judicial**. Segundo Dhenis Cruz Madeira, o solipsismo judicial é uma forma de sacralização da atividade judicante, fundada na crença de que o julgador, por características que lhes são subjetivas e imanentes, seja capaz de dizer o que é bom, justo, certo e verdadeiro para o restante da sociedade.[115]

Ele alerta que a postura solipsista é adotada no ambiente forense com frequência, representada por meio de frases como minha íntima convicção, minha compreensão, conforme minha convicção ou outras que denotem uma subjetividade exacerbada e desacompanhada de rigor metodológico.

Dhenis pontua que aceitar que a decisão judicial esteja fundamentada em critérios subjetivos e metajurídicos é o mesmo que adotar o anarquismo metodológico no discurso processual, na medida em que o juízo solipsista abandonaria o devido processo, a necessidade de contraditório e o próprio modelo constitucional de processo.

Lênio Streck aponta como sinônimo de solipsismo as decisões conforme a consciência do julgador, pontuando que as decisões judiciais não devem ser tomadas a partir de critérios pessoais, isto é, a partir da consciência psicologista.[116]

O CPC de 2015 seria um marco contra o solipsismo, porque valoriza o princípio do contraditório, **impedindo as chamadas decisões-surpresa**. Em efetiva aplicação dos princípios do contraditório e da cooperação, prevê-se que ao magistrado é proibido julgar sem ter ouvido e levado em conta os argumentos e provas produzidos pelas partes.

Agora vamos para outro nome esquisitão... você certamente já ouviu falar no movimento do terraplanismo (pessoal defendendo que a Terra é plana, e não redonda). Então, vem do STF o chamado **Terraplanismo Constitucional**. O Ministro Luís Roberto Barroso o conceitua como uma interpretação constitucional absurda, ignorando os valores e princípios da Constituição e da teoria constitucional (STF, MI n. 7.311).

---

[115] MADEIRA, Dhenis Cruz. O que é solipsismo judicial? *Revista Jurídica da Presidência*, Brasília, v. 22, n. 126, p. 191-210, fev./maio 2020.

[116] STRECK, Lênio Luiz. *O que é isto – decido conforme minha consciência?* Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 106 e 107.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

QUESTÕES DE CONCURSO

FGV
PODER CONSTITUINTE

001. (PGM/PROCURADOR/2023) Determinada região do país teve a ordem pública ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, decorrente da insatisfação dos integrantes de certas estruturas orgânicas com a política remuneratória adotada e com decisões administrativas dos chefes dos Poderes Executivos dos Estados inseridos na referida região. Em razão desse fato, um grupo de vinte e oito senadores apresentou a proposta de emenda constitucional n. X (PEC n. X) dispondo sobre medidas emergenciais a serem adotadas em situações dessa natureza. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a PEC n. X:
a) não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade;
b) afronta um limite material para a reforma da Constituição;
c) afronta um limite circunstancial para a reforma da Constituição;
d) apresenta vício de iniciativa e afronta um limite material para a reforma da Constituição;
e) apresenta vício de iniciativa e afronta um limite circunstancial para a reforma da Constituição.

002. (ALE-MA/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) Em uma gincana jurídica, os dois grupos envolvidos deveriam indicar, na perspectiva prevalecente no direito brasileiro, as características do poder constituinte originário. O grupo Alfa argumentava se tratar de um poder de direito, de caráter permanente, e ao qual não são oponíveis direitos adquiridos. O grupo Beta, por sua vez, ressaltava a característica da iniciabilidade e o seu caráter incondicionado na perspectiva formal, sendo-lhe possível constitucionalizar o direito pré-constitucional de natureza infraconstitucional. Os jurados, ao avaliarem os posicionamentos dos dois grupos, concluíram corretamente que
a) os dois grupos estão totalmente certos.
b) os dois grupos estão parcialmente certos.
c) o grupo Alfa está parcialmente certo e o grupo Beta, totalmente certo.
d) o grupo Alfa está totalmente errado e o grupo Beta, totalmente certo.
e) o grupo Alfa está totalmente certo e o grupo Beta, parcialmente certo.

003. (CD/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) Um grupo de vinte e cinco Senadores apresentou proposta de Emenda à Constituição, que tinha por objeto a instituição de um Estado de Direito regional, nos qual as competências legislativas seriam centralizadas na União e

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

exercidas pelas regiões nos termos da delegação que viessem a receber. Essa proposta foi aprovada por cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Ao final, foi sancionada e promulgada pelo Presidente da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa narrativa

a) não apresenta irregularidade.

b) somente apresenta irregularidades em relação à iniciativa da proposta, ao objeto e à sanção e promulgação.

c) somente apresenta irregularidades em relação à aprovação e à sanção e promulgação.

d) somente apresenta irregularidades em relação à iniciativa e ao objeto.

e) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação.

004. (CÂMARA DOS DEPUTADOS/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) João, professor de direito constitucional, questionou Maria, sua aluna, em relação a alguns aspectos relacionados ao exercício do poder reformador, mais especificamente quanto à legitimidade para a apresentação de proposta, aos limites materiais ao exercício do poder reformador e à possibilidade de a matéria inserida em proposta havida por prejudicada ser objeto de nova proposta. À luz da sistemática constitucional, Maria respondeu corretamente que

a) é admitida a iniciativa popular nessas propostas.

b) a forma de governo não está inserida entre os limites materiais.

c) a matéria constante de proposta havida por prejudicada somente pode ser objeto de nova proposta na legislatura seguinte.

d) a proposta havida por prejudicada, não propriamente rejeitada, pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

e) a iniciativa das Assembleias Legislativas exige que a manifestação, em cada uma delas, se dê por maioria absoluta de seus membros.

005. (PC-AM/DELEGADO/2022) Em um período no qual a região norte do País estava sendo atingida por uma calamidade de grandes proporções da natureza, um grupo de vinte Senadores subscreveu uma proposta de emenda constitucional, visando a alterar a sistemática afeta à estruturação dos órgãos de segurança pública. Acresça-se que proposta idêntica fora apresentada e rejeitada pelo Senado Federal na mesma legislatura, mais especificamente no ano anterior. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa proposta afronta

a) os limites formais, materiais, circunstanciais e temporais de reforma constitucional.

b) apenas os limites formais, circunstanciais e temporais de reforma constitucional.

c) apenas os limites circunstanciais e temporais de reforma constitucional.

d) apenas os limites formais e materiais de reforma constitucional.

e) apenas os limites formais de reforma constitucional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONSTITUCIONALISMO/NEOCONSTITUCIONALISMO

001. (DPE-RJ/DEFENSOR PÚBLICO/2023) A Constituição da República de 1988 é fruto de movimentos político-jurídicos após o período autoritário de regime militar, que estabeleceram novos parâmetros interpretativos, novas dinâmicas jurisdicionais e novos desafios para o Brasil. Sobre essa pauta político-ideológica da Constituição da República de 1988 e a doutrina neoconstitucionalista, é correto afirmar que:
a) a Constituição da República de 1988 estabeleceu nova sistemática de jurisdição constitucional, o que reduziu o processo de judicialização da política e da vida social no país, favorecendo a participação democrática no Brasil;
b) a tendência de constitucionalização do Direito favorece a liberdade de conformação do legislador e dos governantes para realizar opções políticas em nome do povo;
c) a Constituição da República de 1988 realiza escolhas políticas e morais na esfera pública, isto é, faz deliberadas escolhas de valores que passam a compor o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro a partir de sua promulgação;
d) a Constituição da República de 1988 elege como objetivos secundários da República a redução da desigualdade e a garantia dos direitos fundamentais;
e) a ordenação jurídica do Brasil, assim como os atos concretos do poder público interferentes com a ordem econômica e social poderão flexibilizar a realização da justiça social.

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

001. (SEFAZ-MG/AUDITOR/2023) Ernesto e Antônio travaram intenso debate a respeito da classificação de duas normas constitucionais quanto à eficácia e à aplicabilidade. A norma estudada por Ernesto determina que a lei infraconstitucional deve delinear os contornos gerais e detalhar a composição de um órgão colegiado responsável pela definição e pela implementação de determinado plano nacional de natureza assistencial. Já a norma analisada por Antônio detalhava certo direito, passível de ser fruído pela generalidade dos brasileiros, mas ressaltava que a lei infraconstitucional poderia excluir do seu alcance determinadas situações fáticas. À luz da narrativa, é correto afirmar que Ernesto estudou uma norma de eficácia
a) imediata e aplicabilidade indireta, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia restringível e de aplicabilidade reduzida.
b) limitada e de princípio institutivo, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade imediata.
c) limitada e de princípio programático, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia plena e de aplicabilidade não integral.
d) contida e de aplicabilidade indireta, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata.
e) plena e de princípio integrativo, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade restringível.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL (INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO)

001. (PGE-SC/PROCURADOR/2022) Bruna, estudiosa da interpretação constitucional, apresentou em um grupo de estudo três críticas comumente direcionadas a uma determinada teoria da interpretação e, ao final, solicitou que fosse indicada que teoria seria esta.
As críticas são as seguintes:
(1) Desconsidera a existência de um nítido hiato entre o pensamento e a linguagem que o representa e exterioriza;
(2) Visão distorcida do princípio democrático, somente atribuindo legitimidade à Assembleia Constituinte, não ao Tribunal Constitucional; e
(3) A dificuldade epistêmica em delinear o paradigma no qual se situa o sentido do texto constitucional.
O grupo de estudos concluiu, corretamente, que a teoria da interpretação à qual são direcionadas as críticas referidas por Bruna é:
a) a tópica;
b) a axiológica;
c) a originalista;
d) a concretista;
e) o realismo jurídico norte-americano.

002. (PC-RN/DELEGADO/2022) No processo de interpretação constitucional, a pré-compreensão do intérprete não pode ocupar uma posição hegemônica e incontrastável, de modo a tornar esse processo uma encenação que busque tão somente justificar conclusões prévias, indiferentes aos limites do texto constitucional, aos aspectos circunstanciais e às exigências de ordem metódica. Na interpretação constitucional, a narrativa acima se mostra:
a) errada, pois a pré-compreensão não pode ser utilizada na interpretação constitucional, sob pena de consagrar o subjetivismo em detrimento do caráter objetivo da norma;
b) correta, pois o conhecimento adquirido pelo intérprete é apenas condição de desenvolvimento da compreensão, que resulta na atribuição de significado ao texto;
c) correta, pois a interpretação evidencia uma total separação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscido, de modo que a compreensão é da alçada do legislador;
d) errada, pois o intérprete, em sua atividade intelectiva, deve se limitar a conhecer o sentido imanente ao texto, não participando da construção do significado;
e) contraditória, pois a pré-compreensão e a compreensão apresentam uma relação de sobreposição, não ocupando planos sucessivos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

001. (RFB/ANALISTA TRIBUTÁRIO/2023) Em determinado País, o grupo político que assumiu o poder com o uso da força solicitou que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de Constituição. Ato contínuo, após realizar os ajustes que lhe pareciam necessários, submeteu-o a um plebiscito, com o objetivo de lhe conferir uma aparente legitimidade, o que resultou na sua aprovação popular. Ato contínuo à aprovação, o texto constitucional foi publicado e sua observância se tornou obrigatória. Essa Constituição, no entanto, foi moldada pelo grupo político dominante com o intuito de atender aos seus objetivos. A Constituição do referido País se compatibiliza com a classificação como

a) dogmática e compromissória.
b) promulgada e plebiscitária.
c) heterodoxa e normativa.
d) cesarista e semântica.
e) outorgada e nominal.

HIERARQUIA DAS NORMAS

001. (RFB/AUDITOR FISCAL/2023) A República Federativa do Brasil celebrou três tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. O primeiro deles foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros. O segundo foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto da maioria absoluta dos respectivos membros. O terceiro, por sua vez, foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto da maioria simples dos respectivos membros. João, estudante de direito, constatou que os três tratados internacionais colidiam materialmente com o Art. X da Constituição da República, que dispõe sobre a organização de um colegiado do Poder Executivo, e com o Art. Y da Lei federal n. 123, que integrou a eficácia de um direito fundamental. A partir dessa constatação, questionou o seu professor a respeito dos efeitos da incorporação desses tratados à ordem interna. O professor respondeu corretamente que, com a sua incorporação à ordem interna,

a) apenas o primeiro e o segundo tratados revogaram o Art. X da Constituição da República e o Art. Y da Lei n. 123.
b) os três tratados revogaram o Art. X da Constituição da República e não recepcionaram o Art. Y da Lei n. 123.
c) apenas o primeiro tratado revogou o Art. X da Constituição da República, mas não recepcionou o Art. Y da Lei n. 123.
d) nenhum dos três tratados pode ser aplicado na ordem interna, já que colidem com o Art. X da Constituição da República.
e) os três tratados têm natureza infraconstitucional, mas supralegal, de modo que não afetaram a eficácia do Art. X da Constituição da República e revogaram o Art. Y da Lei n. 123.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

002. (TJ-AP/JUIZ DE DIREITO/2022) Joana e sua família contrataram com a companhia aérea ZZ o serviço de transporte aéreo internacional do Brasil para a Espanha, com passagens de ida e volta. Ao desembarcarem no destino, juntamente com os demais passageiros, constataram que sua bagagem tinha se extraviado. Assim que retornaram ao Brasil, Joana e sua família ajuizaram ação de reparação de danos em face da companhia aérea ZZ, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em sua defesa, a companhia argumentou com a existência de convenção internacional (CI), devidamente ratificada pelo Estado brasileiro antes da promulgação da Constituição da República de 1988, cuja aplicação resultaria na fixação de indenização em patamares sensivelmente inferiores. Acresça-se que a sede da multinacional está situada em país que igualmente ratificou a convenção.

À luz da sistemática constitucional, o juiz de direito, ao julgar a causa, deve aplicar, nas circunstâncias indicadas:

a) o CDC, que somente não prevaleceria sobre a CI caso fosse mais favorável ao consumidor, o que não é o caso;

b) a CI, que, por expressa previsão constitucional, sempre prevalece sobre as normas infraconstitucionais afetas à temática;

c) o CDC, que tem a natureza de lei ordinária e foi editado em momento posterior à CI, afastando a sua eficácia no território brasileiro;

d) o CDC, pois a proteção do consumidor consubstancia direito fundamental, insuscetível de ser restringido por CI;

e) a CI, desde que a sua recepção pela Constituição da República de 1988 tenha sido reconhecida em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos seus membros.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO

PODER CONSTITUINTE

1. a
2. c
3. b
4. b
5. e

CONSTITUCIONALISMO/NEOCONSTITUCIONALISMO

1. c

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

1. b

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL (INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO)

1. c
2. b

CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

1. d

HIERARQUIA DAS NORMAS

1. c
2. b

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

GABARITO COMENTADO

PODER CONSTITUINTE

001. (PGM/PROCURADOR/2023) Determinada região do país teve a ordem pública ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, decorrente da insatisfação dos integrantes de certas estruturas orgânicas com a política remuneratória adotada e com decisões administrativas dos chefes dos Poderes Executivos dos Estados inseridos na referida região. Em razão desse fato, um grupo de vinte e oito senadores apresentou a proposta de emenda constitucional n. X (PEC n. X) dispondo sobre medidas emergenciais a serem adotadas em situações dessa natureza. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a PEC n. X:

a) não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade;
b) afronta um limite material para a reforma da Constituição;
c) afronta um limite circunstancial para a reforma da Constituição;
d) apresenta vício de iniciativa e afronta um limite material para a reforma da Constituição;
e) apresenta vício de iniciativa e afronta um limite circunstancial para a reforma da Constituição.

Pegadinha recorrente da Banca, falar que está havendo uma grave crise, uma instabilidade institucional, catástrofes da natureza... o que você precisa procurar é se houve – ou não – a decretação de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Não havendo, você não pode presumir a existência de limitações circunstanciais. Só isso já afasta as alternativas C e E.

Avançando, no âmbito federal, qualquer um dos legitimados pode tratar de qualquer tema previsto na CF. Em consequência, não se fala em vício de iniciativa, o que torna erradas as letras D e E.

Inexiste qualquer violação aos limites materiais e formais, razão pela qual a letra A tem a resposta esperada.

Letra a.

---

002. (ALE-MA/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) Em uma gincana jurídica, os dois grupos envolvidos deveriam indicar, na perspectiva prevalecente no direito brasileiro, as características do poder constituinte originário. O grupo Alfa argumentava se tratar de um poder de direito, de caráter permanente, e ao qual não são oponíveis direitos adquiridos. O grupo Beta, por sua vez, ressaltava a característica da iniciabilidade e o seu caráter incondicionado na

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

perspectiva formal, sendo-lhe possível constitucionalizar o direito pré-constitucional de natureza infraconstitucional. Os jurados, ao avaliarem os posicionamentos dos dois grupos, concluíram corretamente que

a) os dois grupos estão totalmente certos.

b) os dois grupos estão parcialmente certos.

c) o grupo Alfa está parcialmente certo e o grupo Beta, totalmente certo.

d) o grupo Alfa está totalmente errado e o grupo Beta, totalmente certo.

e) o grupo Alfa está totalmente certo e o grupo Beta, parcialmente certo.

Olhando para o grupo Alfa, está errada a afirmação de que o PCO seria um poder de fato, e não de direito. Porém, é verdadeira a afirmação de que o PCO não precisa respeitar direitos adquiridos em outra ordem constitucional.

Por outro lado, em relação ao grupo Beta, é certo que o PCO tem a característica da iniciabilidade, pois inicia a ordem jurídica, rompendo com a anterior. Também é autônomo e incondicionado, sendo ilimitado juridicamente. Pode ab-rogar a legislação pretérita ou até mesmo (se for feito de modo expresso) fazer a desconstitucionalização ou a recepção material.

Assim, a resposta esperada está na letra C.

Letra c.

---

003. (CD/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) Um grupo de vinte e cinco Senadores apresentou proposta de Emenda à Constituição, que tinha por objeto a instituição de um Estado de Direito regional, nos qual as competências legislativas seriam centralizadas na União e exercidas pelas regiões nos termos da delegação que viessem a receber. Essa proposta foi aprovada por cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Ao final, foi sancionada e promulgada pelo Presidente da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa narrativa

a) não apresenta irregularidade.

b) somente apresenta irregularidades em relação à iniciativa da proposta, ao objeto e à sanção e promulgação.

c) somente apresenta irregularidades em relação à aprovação e à sanção e promulgação.

d) somente apresenta irregularidades em relação à iniciativa e ao objeto.

e) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação.

Vamos por partes. 1/3 dos integrantes do Senado corresponde a 27 membros, o que torna insuficiente a assinatura de apenas 25 senadores. Avançando, não há sanção ou veto presidencial, além de que a promulgação das ECs é feita pelas mesas da CD e do SF, com o respectivo número de ordem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Avançando, o objeto também tem problemas, com a criação de um Estado de Direito regional, com o desbalanceamento na repartição constitucional de competências, divergindo do modelo hoje vigente.
Assim, a resposta esperada está na letra B.
Letra b.

---

004. (CÂMARA DOS DEPUTADOS/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) João, professor de direito constitucional, questionou Maria, sua aluna, em relação a alguns aspectos relacionados ao exercício do poder reformador, mais especificamente quanto à legitimidade para a apresentação de proposta, aos limites materiais ao exercício do poder reformador e à possibilidade de a matéria inserida em proposta havida por prejudicada ser objeto de nova proposta. À luz da sistemática constitucional, Maria respondeu corretamente que
a) é admitida a iniciativa popular nessas propostas.
b) a forma de governo não está inserida entre os limites materiais.
c) a matéria constante de proposta havida por prejudicada somente pode ser objeto de nova proposta na legislatura seguinte.
d) a proposta havida por prejudicada, não propriamente rejeitada, pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
e) a iniciativa das Assembleias Legislativas exige que a manifestação, em cada uma delas, se dê por maioria absoluta de seus membros.

As emendas à Constituição são fruto do Poder Constituinte Derivado Reformador. Portanto, estão sujeitas a limitações impostas pelo Constituinte Originário – circunstanciais, formais, materiais e implícitas.
Olhando para a questão, erradas as letra A e E, uma vez que o povo não pode propor PEC em relação à CF (poderá em relação à CE se houver previsão nesse sentido). Os legitimados são apenas: 1) Presidente da República; 2) 1/3 da Câmara ou do Senado; 3) Mais da ½ das Assembleias Legislativas, reunidas em maioria relativa cada uma.
Também erradas as letras C e D, porque em relação às ECs e às MPs vigora a irrepetibilidade absoluta, de modo que a proposta rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa (não é na mesma legislatura).
Sobra como correta a letra B. As limitações materiais, também chamadas de cláusulas pétreas, são: forma federativa de Estado; direitos e garantias individuais; voto direto, secreto, universal e periódico e a separação de poderes. A forma de governo não está nesse rol.
Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

005. (PC-AM/DELEGADO/2022) Em um período no qual a região norte do País estava sendo atingida por uma calamidade de grandes proporções da natureza, um grupo de vinte Senadores subscreveu uma proposta de emenda constitucional, visando a alterar a sistemática afeta à estruturação dos órgãos de segurança pública. Acresça-se que proposta idêntica fora apresentada e rejeitada pelo Senado Federal na mesma legislatura, mais especificamente no ano anterior. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa proposta afronta

a) os limites formais, materiais, circunstanciais e temporais de reforma constitucional.
b) apenas os limites formais, circunstanciais e temporais de reforma constitucional.
c) apenas os limites circunstanciais e temporais de reforma constitucional.
d) apenas os limites formais e materiais de reforma constitucional.
e) apenas os limites formais de reforma constitucional.

Vamos por partes. Vinte senadores não podem propor PEC, sendo exigido o quórum de 1/3, que equivale a 27 membros. Avançando, o fato de haver uma região atingida por calamidade de grandes proporções, por si só, não impede que seja proposta PEC, pois não se falou em estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal decretados. Ausente, pois, violação a limitações circunstanciais. EC e MP possuem a chamada irrepetibilidade absoluta, não podendo haver a reedição de proposta rejeitada na mesma sessão legislativa. Note, porém, que na situação descrita a PEC foi rejeitada no ano anterior. Ainda que dentro da mesma legislatura, não haveria objeção.

Assim, a resposta esperada está na letra E.

Letra e.

CONSTITUCIONALISMO/NEOCONSTITUCIONALISMO

001. (DPE-RJ/DEFENSOR PÚBLICO/2023) A Constituição da República de 1988 é fruto de movimentos político-jurídicos após o período autoritário de regime militar, que estabeleceram novos parâmetros interpretativos, novas dinâmicas jurisdicionais e novos desafios para o Brasil. Sobre essa pauta político-ideológica da Constituição da República de 1988 e a doutrina neoconstitucionalista, é correto afirmar que:

a) a Constituição da República de 1988 estabeleceu nova sistemática de jurisdição constitucional, o que reduziu o processo de judicialização da política e da vida social no país, favorecendo a participação democrática no Brasil;
b) a tendência de constitucionalização do Direito favorece a liberdade de conformação do legislador e dos governantes para realizar opções políticas em nome do povo;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) a Constituição da República de 1988 realiza escolhas políticas e morais na esfera pública, isto é, faz deliberadas escolhas de valores que passam a compor o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro a partir de sua promulgação;
d) a Constituição da República de 1988 elege como objetivos secundários da República a redução da desigualdade e a garantia dos direitos fundamentais;
e) a ordenação jurídica do Brasil, assim como os atos concretos do poder público interferentes com a ordem econômica e social poderão flexibilizar a realização da justiça social.

Errada a letra A, pois a expansão da jurisdição constitucional ampliou exponencialmente o acesso à justiça, aumentando o processo de judicialização da política.
O erro das letras B e E está no fato de a liberdade de conformação dos governantes e legisladores ser reduzida pelas normas programáticas, que dirigem a sua atuação. A CF, nas palavras do Ministro Celso de Mello, não poderia ser uma promessa vazia e inconsequente. Isso também reduz a margem de realização da justiça social.
A letra D está errada, na medida em que são objetivos fundamentais, listados desde os Títulos I e II, portanto, no carro abre-alas da CF.
Sobra como correta a letra C, cabendo ressaltar que um dos pontos marcantes do neoconstitucionalismo é a reaproximação entre direito e moral e direito e a ética.
Letra c.

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

001. (SEFAZ-MG/AUDITOR/2023) Ernesto e Antônio travaram intenso debate a respeito da classificação de duas normas constitucionais quanto à eficácia e à aplicabilidade. A norma estudada por Ernesto determina que a lei infraconstitucional deve delinear os contornos gerais e detalhar a composição de um órgão colegiado responsável pela definição e pela implementação de determinado plano nacional de natureza assistencial. Já a norma analisada por Antônio detalhava certo direito, passível de ser fruído pela generalidade dos brasileiros, mas ressaltava que a lei infraconstitucional poderia excluir do seu alcance determinadas situações fáticas. À luz da narrativa, é correto afirmar que Ernesto estudou uma norma de eficácia
a) imediata e aplicabilidade indireta, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia restringível e de aplicabilidade reduzida.
b) limitada e de princípio institutivo, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade imediata.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

c) limitada e de princípio programático, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia plena e de aplicabilidade não integral.
d) contida e de aplicabilidade indireta, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata.
e) plena e de princípio integrativo, enquanto Antônio analisou uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade restringível.

Começando pela norma de Ernesto. Se a lei vem para delinear os contornos gerais e definir a composição significa que ela vem para completar o texto constitucional. Logo, é norma de eficácia limitada. Tratando-se da formatação de um órgão, é limitada de princípio institutivo. Por outro lado, a norma de Antônio viria para reduzir o alcance do dispositivo constitucional, o que aponta para norma de eficácia contida.
Assim, a resposta esperada está na letra B.
Letra b.

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL (INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO)

001. (PGE-SC/PROCURADOR/2022) Bruna, estudiosa da interpretação constitucional, apresentou em um grupo de estudo três críticas comumente direcionadas a uma determinada teoria da interpretação e, ao final, solicitou que fosse indicada que teoria seria esta.
As críticas são as seguintes:
(1) Desconsidera a existência de um nítido hiato entre o pensamento e a linguagem que o representa e exterioriza;
(2) Visão distorcida do princípio democrático, somente atribuindo legitimidade à Assembleia Constituinte, não ao Tribunal Constitucional; e
(3) A dificuldade epistêmica em delinear o paradigma no qual se situa o sentido do texto constitucional.
O grupo de estudos concluiu, corretamente, que a teoria da interpretação à qual são direcionadas as críticas referidas por Bruna é:
a) a tópica;
b) a axiológica;
c) a originalista;
d) a concretista;
e) o realismo jurídico norte-americano.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A resposta esperada está na letra C.

É que a teoria da interpretação que sofre as críticas citadas é a do originalismo, surgida a partir dos pensamentos do jurista norteamericano Robert Bork. Segundo ele, os princípios constitucionais devem ser lidos de forma literal, resgatando a intenção original do legislador, não cabendo ao Judiciário fazer interpretações mais elásticas. O papel do Judiciário seria o de declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, sempre olhando para a visão inicial (original) do Parlamento. Não caberia aos tribunais assegurar direitos que não estivessem previsto na CF. Bork está mais ligado aos constitucionalistas conservadores. No Brasil, sua corrente é defendida por Ives Gandra. Já Luís Roberto Barroso, um dos expoentes do neoconstitucionalismo (que traz em seu bojo um papel mais relevante da jurisdição constitucional), defende que o originalismo hoje tenderia a ser superado por uma visão mais liberal, que dá mais visibilidade ao papel do intérprete.

Letra c.

---

002. (PC-RN/DELEGADO/2022) No processo de interpretação constitucional, a pré-compreensão do intérprete não pode ocupar uma posição hegemônica e incontrastável, de modo a tornar esse processo uma encenação que busque tão somente justificar conclusões prévias, indiferentes aos limites do texto constitucional, aos aspectos circunstanciais e às exigências de ordem metódica. Na interpretação constitucional, a narrativa acima se mostra:

a) errada, pois a pré-compreensão não pode ser utilizada na interpretação constitucional, sob pena de consagrar o subjetivismo em detrimento do caráter objetivo da norma;

b) correta, pois o conhecimento adquirido pelo intérprete é apenas condição de desenvolvimento da compreensão, que resulta na atribuição de significado ao texto;

c) correta, pois a interpretação evidencia uma total separação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscido, de modo que a compreensão é da alçada do legislador;

d) errada, pois o intérprete, em sua atividade intelectiva, deve se limitar a conhecer o sentido imanente ao texto, não participando da construção do significado;

e) contraditória, pois a pré-compreensão e a compreensão apresentam uma relação de sobreposição, não ocupando planos sucessivos.

Indo direto ao ponto, a pré-compreensão do intérprete se soma ao objeto a ser estudado. É daí que sai o resultado final do processo, no giro ou espiral hermenêutico defendido por Hans Gadamer.

Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E ELEMENTOS DAS CONSTITUIÇÕES

001. (RFB/ANALISTA TRIBUTÁRIO/2023) Em determinado País, o grupo político que assumiu o poder com o uso da força solicitou que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de Constituição. Ato contínuo, após realizar os ajustes que lhe pareciam necessários, submeteu-o a um plebiscito, com o objetivo de lhe conferir uma aparente legitimidade, o que resultou na sua aprovação popular. Ato contínuo à aprovação, o texto constitucional foi publicado e sua observância se tornou obrigatória. Essa Constituição, no entanto, foi moldada pelo grupo político dominante com o intuito de atender aos seus objetivos. A Constituição do referido País se compatibiliza com a classificação como

a) dogmática e compromissória.
b) promulgada e plebiscitária.
c) heterodoxa e normativa.
d) cesarista e semântica.
e) outorgada e nominal.

Primeira coisa: quando o examinador falar que um texto constitucional foi elaborado sem a participação popular, mas que no meio do caminho houve um plebiscito para ratificar o texto, você já sabe que estamos diante de Constituição cesarista, que também pode aparecer com o nome de bonapartista. Avançando, repare que o examinador colocou que a Constituição foi feita pelo grupo dominante com o intuito de atender aos seus objetivos. Ou seja, foi uma constituição de fachada (palavras do professor português JJ Gomes Canotilho). Assim, em relação à correspondência com a realidade (ou critério ontológico), ela é semântica.

Assim, a resposta esperada está na letra D.

Letra d.

HIERARQUIA DAS NORMAS

001. (RFB/AUDITOR FISCAL/2023) A República Federativa do Brasil celebrou três tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. O primeiro deles foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros. O segundo foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto da maioria absoluta dos respectivos membros. O terceiro, por sua vez, foi aprovado, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto da maioria simples dos respectivos membros. João, estudante de direito, constatou que os três tratados internacionais colidiam materialmente com o Art. X da Constituição da República, que dispõe sobre a organização de um colegiado

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

do Poder Executivo, e com o Art. Y da Lei federal n. 123, que integrou a eficácia de um direito fundamental. A partir dessa constatação, questionou o seu professor a respeito dos efeitos da incorporação desses tratados à ordem interna. O professor respondeu corretamente que, com a sua incorporação à ordem interna,

a) apenas o primeiro e o segundo tratados revogaram o Art. X da Constituição da República e o Art. Y da Lei n. 123.

b) os três tratados revogaram o Art. X da Constituição da República e não recepcionaram o Art. Y da Lei n. 123.

c) apenas o primeiro tratado revogou o Art. X da Constituição da República, mas não recepcionou o Art. Y da Lei n. 123.

d) nenhum dos três tratados pode ser aplicado na ordem interna, já que colidem com o Art. X da Constituição da República.

e) os três tratados têm natureza infraconstitucional, mas supralegal, de modo que não afetaram a eficácia do Art. X da Constituição da República e revogaram o Art. Y da Lei n. 123.

Questãozinha mal formulada essa aí, hein?

Vamos decodificar as informações. Dos três tratados, apenas o primeiro tem status constitucional, pois foi aprovado sob a sistemática prevista no artigo 5º, § 3º, da CF. Os demais podem ser internalizados na ordem jurídica brasileira, mas terão status supralegal – acima das leis, mas abaixo da CF.

Considerando que norma posterior revoga norma anterior, é possível que o primeiro tratado revogue o artigo X da CF, pois ambos têm a mesma hierarquia. Só isso já exclui as demais alternativas, conduzindo à letra C por exclusão.

Todos os tratados, por sua vez, estão hierarquicamente em posição superior à Lei 123. Havendo choque, ela será revogada por ausência de recepção (ou não recepcionada).

Letra c.

---

002. (TJ-AP/JUIZ DE DIREITO/2022) Joana e sua família contrataram com a companhia aérea ZZ o serviço de transporte aéreo internacional do Brasil para a Espanha, com passagens de ida e volta. Ao desembarcarem no destino, juntamente com os demais passageiros, constataram que sua bagagem tinha se extraviado. Assim que retornaram ao Brasil, Joana e sua família ajuizaram ação de reparação de danos em face da companhia aérea ZZ, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em sua defesa, a companhia argumentou com a existência de convenção internacional (CI), devidamente ratificada pelo Estado brasileiro antes da promulgação da Constituição da República de 1988, cuja aplicação resultaria na

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

fixação de indenização em patamares sensivelmente inferiores. Acresça-se que a sede da multinacional está situada em país que igualmente ratificou a convenção.
À luz da sistemática constitucional, o juiz de direito, ao julgar a causa, deve aplicar, nas circunstâncias indicadas:
a) o CDC, que somente não prevaleceria sobre a CI caso fosse mais favorável ao consumidor, o que não é o caso;
b) a CI, que, por expressa previsão constitucional, sempre prevalece sobre as normas infraconstitucionais afetas à temática;
c) o CDC, que tem a natureza de lei ordinária e foi editado em momento posterior à CI, afastando a sua eficácia no território brasileiro;
d) o CDC, pois a proteção do consumidor consubstancia direito fundamental, insuscetível de ser restringido por CI;
e) a CI, desde que a sua recepção pela Constituição da República de 1988 tenha sido reconhecida em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos seus membros.

Nos contratos de transporte aéreo internacional de passageiros, há alguns detalhes que você precisa conhecer para não escorregar nas provas. Vamos lá?

RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS NOS VOOS INTERNACIONAIS	
SITUAÇÃO	**NORMA APLICÁVEL**
Danos materiais	Afasta-se o CDC. Aplicam-se a Convenção de Montreal e Pacto de Varsóvia (RE 636.331).
Danos morais (extrapatrimoniais)	Aplica-se o CDC, não incidindo os tratados internacionais, pois regulam apenas os danos materiais. Nesse caso, o prazo prescricional é de 5 anos (RE 1.394.401).

Qual, então, a razão de prevalência da CI sobre as regras de direito interno? Simples. É que aquelas são tratados internacionais versando sobre direitos humanos, possuindo status de norma supralegal. Por sua vez, o CDC é ato normativo primário.
Ah, mas nos danos morais (extrapatrimoniais) prevalece o CDC por falta de previsão semelhante nos tratados internacionais indicados.
Assim, a resposta esperada está na letra b.
Letra b.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra

caminhos

crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Benjamim Bueno - 38911306860, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.